課程名稱：刑法08

00:00:01 - 00:00:06
好，我們就繼續回來上課，講最後一段關於反面的容許構成要件錯誤。

00:00:07 - 00:00:11
那個同學你們經過七月門口，有沒有看到那個櫃臺上放了一隻灰色的吉娃娃？

00:00:12 - 00:00:13
應該有嘛，對不對，很可愛，對不對？

00:00:14 - 00:00:15
那隻我提供的啦，急訓班的吉祥物。

00:00:17 - 00:00:21
真的，因為急訓班我們要取諧音集訓嘛。

00:00:21 - 00:00:23
對啊，所以急訓的話，我們就用一隻吉娃娃。

00:00:24 - 00:00:26
那我買的啊，我去臺中那個變種吉娃娃店買的啊，很可愛嘛，大家都喜歡。

00:00:28 - 00:00:29
我今天也穿吉娃娃。

00:00:30 - 00:00:33
很可愛嘛，對不對，這一次看起來是不是非常的聰明睿智。

00:00:33 - 00:00:35
上面還寫了一句話寫「奇奇如律令」。

00:00:36 - 00:00:37
真的啦。

00:00:37 - 00:00:42
你們喜歡的話上網可以買奇奇如律令，大家也有出手機殼，只是我沒有用殼的習慣。

00:00:45 - 00:00:49
所以我就買這個T恤，然後買了好幾件不同的顏色啊，奇奇如律令，非常的可愛。

00:00:49 - 00:00:51
牠看起來很聰明，有沒有這種感覺？

00:00:51 - 00:00:53
跟那個七月門口那隻一樣，看起來非常的聰明睿智，活潑可愛。

00:00:56 - 00:00:58
那個急訓班的同學聽說都很喜歡他。

00:00:59 - 00:01:02
這個我講過吧，吉娃娃人見人愛，大家都喜歡。

00:01:04 - 00:01:09
我們接著來看到138頁這個第三點，反面容許構成要件錯誤。

00:01:10 - 00:01:10
好。

00:01:11 - 00:01:14
我剛剛說啊，你不要覺得容許構成要件錯誤。

00:01:14 - 00:01:19
你不要覺得說反面容許構成要件錯誤是什麼很清新、全新很難的東西，沒有。

00:01:20 - 00:01:21
我剛剛講了。

00:01:21 - 00:01:25
容許構成要件錯誤，如果你會的話。

00:01:25 - 00:01:28
那反面容許構成要件錯誤，它就是一模一樣的結構。

00:01:28 - 00:01:30
只是把它反過來而已。

00:01:30 - 00:01:31
過來而已。

00:01:31 - 00:01:31
他真的沒有很難喔。

00:01:31 - 00:01:33
所以我們這邊來看一下。

00:01:33 - 00:01:37
反面容許構成錯誤，就是我們說偶然的系列，偶然的系列。

00:01:38 - 00:01:42
客觀上有阻卻違法的前提事實存在。

00:01:42 - 00:01:46
可是行為人主觀上卻不知道有這個事實的存在。

00:01:47 - 00:01:51
這個叫做反面的容許構成要件錯誤。

00:01:51 - 00:01:53
偶然的系列，像我說的。

00:01:53 - 00:01:58
你把仇人家的窗戶打破了，你原本是純粹的報復心態。

00:01:58 - 00:02:00
結果打破就真的來了。

00:02:00 - 00:02:00
哇，原來仇人將瓦斯漏氣，你這麼做，反而救了仇人一命。

00:02:04 - 00:02:08
這個案例呢，就是我們講的偶然避難，反面的容許構成要件錯誤，這裡的學說啊，會比正面的容許構成要件錯誤簡單很多，好，為什麼呢？

00:02:14 - 00:02:19
反面容許構成要件錯誤，首先，我們先看到古典犯罪體系之下的說法。

00:02:20 - 00:02:24
我們講啊，在古典犯罪體系之下，構成要件純客觀。

00:02:26 - 00:02:27
違法性純客觀。

00:02:28 - 00:02:32
罪責是主觀，故意過失在罪責做判斷。

00:02:32 - 00:02:33
各位啊，你記得一件事喔。

00:02:34 - 00:02:38
古典犯罪體系的違法性是什麼呢？純客觀。

00:02:38 - 00:02:46
也就是客觀上只要有阻卻違法的事由存在，手段沒有過當，兩個都過，他就阻卻違法了。

00:02:46 - 00:02:48
行為人有沒有主觀的認知，不重要啊。

00:02:49 - 00:02:54
所以反面容許構成要件錯誤在古典犯罪體系之下會怎麼樣？

00:02:54 - 00:02:56
十七主確違法，對不對？

00:02:56 - 00:02:58
對啊，因為他的違法性只看客觀啊。

00:02:58 - 00:03:07
所以在古典犯罪體系之下呢，反面容許構成要件錯誤，必然會直接得出主確違法的結論，這個是古早的看法。

00:03:09 - 00:03:11
這個看法現在應該沒有人踩，因為現在應該學者沒有人在踩這個體繫了。

00:03:11 - 00:03:14
應該沒有人踩，所以這一說不寫沒有關係，現在主流的說法是二跟三。

00:03:21 - 00:03:24
三期論之下的計罪說，還有未遂說。

00:03:24 - 00:03:25
我們講啊。

00:03:25 - 00:03:28
對於反面容許構成要件錯誤。

00:03:28 - 00:03:32
現在最主流，最多數的看法就是三期論之下的計罪說。

00:03:32 - 00:03:34
其實那個計罪說，嚴格來講的意思是這樣。

00:03:35 - 00:03:40
計罪說的意思就是反面容許構成要件錯誤，沒有任何的法律效果。

00:03:40 - 00:03:42
原本論什麼罪，就論什麼罪。

00:03:42 - 00:03:43
夠簡單吧，對，他就是沒有效果。

00:03:44 - 00:03:51
因為學者會覺得說，這種反面容許構成要件錯誤的行為人，雖然他偶然之間做的好事沒有錯。

00:03:52 - 00:03:55
可是呢，他的法理都一直是存在的嘛。

00:03:56 - 00:03:57
我們沒什麼好寬待他的嘛。

00:03:57 - 00:03:58
是啊。

00:03:58 - 00:04:00
所以照多數的說法，反面

00:04:00 - 00:04:00
容許構成要件錯誤就是，還抱效沒有什麼效果啊。

00:04:00 - 00:04:00
原本論什麼罪

00:04:04 - 00:04:05
就論什麼罪

00:04:05 - 00:04:07
所以計罪說就是這個意思，夠簡單吧，就沒有效果啊

00:04:08 - 00:04:14
好，那我們來看未遂說之前，我們先來講一下二期論怎麼看這個問題

00:04:15 - 00:04:16
我們剛說啊

00:04:16 - 00:04:18
二期論的操作就是，再講一次喔

00:04:19 - 00:04:23
他認為構成要件該當性跟違法性，這兩者並沒有區分的意義

00:04:24 - 00:04:28
構成要件該當性跟違法性，兩者我們都合成叫做不法，都叫做不法

00:04:29 - 00:04:32
這兩者並沒有區分的意義，他們都叫做不法

00:04:33 - 00:04:38
好，那都叫做不法的話呢，原本的構成要件該當性

00:04:38 - 00:04:41
二期論叫他正面不法

00:04:41 - 00:04:47
原本的違法性,在二期論叫做負面不法,或者叫做阻卻不法的事實

00:04:48 - 00:04:53
所以我們看哦,反面容許構成要件在二期論會怎麼去看他呢

00:04:53 - 00:05:00
我們以剛剛這一個,打破人家家的窗戶啊,結果卻意外的拯救仇人家的性命的這個

00:05:00 - 00:05:00
案例來說

00:05:02 - 00:05:05
這個案例當中，有沒有客觀不法的存在？

00:05:06 - 00:05:12
正面不法確實存在，沒有錯，因為他確實打破人家家窗戶嘛，對不對？

00:05:12 - 00:05:13
行為、結果、因果規則都具備。

00:05:13 - 00:05:15
可是負面不法不存在喔。

00:05:15 - 00:05:21
為什麼？因為客觀上確實存在一個緊急避難的情狀，對不對？

00:05:21 - 00:05:23
所以負面不法是不存在的

00:05:23 - 00:05:28
那行為人主觀上第一個，他對負面不法的存在有認知

00:05:29 - 00:05:32
行為人有沒有覺得無主卻不法的事實

00:05:32 - 00:05:33
有，他確實是這樣覺得的

00:05:33 - 00:05:35
因為他不知道他們家受困嘛

00:05:35 - 00:05:38
你想那個例子,如果行為人知道仇人家瓦斯漏氣

00:05:39 - 00:05:40
他就不會去砸啦

00:05:40 - 00:05:41
他當然希望他仇人死掉啊,對不對

00:05:42 - 00:05:46
所以行為人他主觀上當然對無阻卻違法事實這一塊

00:05:48 - 00:05:48
是有認知的

00:05:49 - 00:05:52
他確實以為沒有阻卻違法的事實

00:05:52 - 00:05:54
所以這個圖看下來,各位你看哦

00:05:55 - 00:05:57
客觀一個打勾一個打叉,結果是什麼

00:05:58 - 00:05:59
打叉嘛

00:05:59 - 00:06:00
客觀沒有吧

00:06:00 - 00:06:00
對不對？

00:06:00 - 00:06:03
主觀上行為人有沒有覺得有？

00:06:03 - 00:06:04
主觀上有沒有故意？

00:06:04 - 00:06:04
有。

00:06:04 - 00:06:07
所以你看喔，客觀打叉主觀打勾。

00:06:07 - 00:06:08
所以叫什麼呢？

00:06:09 - 00:06:10
未遂啊

00:06:10 - 00:06:11
對不對，他就是未遂啊

00:06:12 - 00:06:15
所以你看喔，如果採二階論的話

00:06:15 - 00:06:18
反面容許構成要件錯誤

00:06:18 - 00:06:21
本來就會得出未遂的結論

00:06:22 - 00:06:23
你不用套用任何的學說

00:06:23 - 00:06:24
知道吧

00:06:24 - 00:06:28
如果你採取二階論的話,反面容許構成要件錯誤

00:06:28 - 00:06:31
本來就會得出未遂的結論

00:06:32 - 00:06:32
好

00:06:32 - 00:06:35
那三階論者看到這個結論覺得好像還不錯

00:06:36 - 00:06:38
三階論者也希望得到這個結論啊

00:06:39 - 00:06:41
三階論要怎麼得出未遂的結論

00:06:42 - 00:06:43
我們就畫個圖來看一下

00:06:44 - 00:06:46
一樣延續著剛剛這個偶然必然的案例

00:06:48 - 00:06:49
好，你看喔

00:06:50 - 00:06:51
在這個偶然必然的案例當中

00:06:52 - 00:06:55
行為人確實該當毀損罪的構成要件

00:06:55 - 00:06:55
沒有疑問

00:06:55 - 00:06:57
那違法性的層次呢

00:06:57 - 00:06:59
這裡可不可以起避難阻卻違法

00:07:00 - 00:07:01
不行啊

00:07:01 - 00:07:06
客觀上雖然有一個避難情狀沒有錯，可是行為人主觀上沒有認知啊

00:07:06 - 00:07:07
對不對

00:07:07 - 00:07:07
好

00:07:07 - 00:07:09
於是三階論者提出一個想法

00:07:10 - 00:07:12
三階論者會覺得說

00:07:12 - 00:07:15
客觀上有一個避難的情狀存在

00:07:16 - 00:07:21
而行為人，他也確實消滅了這個危難

00:07:22 - 00:07:25
從結果上來講，他是不是一件好事？

00:07:26 - 00:07:27
是嗎？

00:07:27 - 00:07:27
對不對？

00:07:27 - 00:07:28
他拯救了一家人嘛。

00:07:28 - 00:07:31
那從結果上來說，他是一件好事的話...

00:07:32 - 00:07:34
這一個好的結果

00:07:34 - 00:07:36
就足以抵銷掉

00:07:37 - 00:07:40
他打破人家窗戶的那一個壞的結果

00:07:40 - 00:07:41
所以呢

00:07:42 - 00:07:42
他們認為說

00:07:43 - 00:07:44
這個結果

00:07:44 - 00:07:45
足以把原本呢

00:07:48 - 00:07:49
原本

00:07:49 - 00:07:53
已經存在這個打破人家窗戶

00:07:53 - 00:07:55
窗戶的壞結果把它抵消掉

00:07:55 - 00:07:55
好

00:07:55 - 00:07:59
然後這邊有一個學理的名字出現了，所謂結果不法跟行為不法

00:08:00 - 00:08:04
這個東西我稍微帶一下，不然這個東西我會講不下去。

00:08:04 - 00:08:05
我們講喔。

00:08:05 - 00:08:11
一個行為之所以不對，在刑法上可以分成行為不法跟結果不法這兩個面向。

00:08:12 - 00:08:14
你無故把一個人給打傷。

00:08:14 - 00:08:19
行為不法的部分，是你違反了不可以傷害別人身體的規範。

00:08:20 - 00:08:22
而結果不法的部分是什麼呢？

00:08:23 - 00:08:26
你造成了別人身體受傷的結果。

00:08:26 - 00:08:27
這個叫結果不法。

00:08:28 - 00:08:34
一般的故意既遂犯，是不是兩個東西具備，既有行為不法，也有結果不法，對不對？

00:08:35 - 00:08:36
那未遂犯的話呢？

00:08:37 - 00:08:39
殺人未遂的情況。

00:08:39 - 00:08:40
有啊，有行為不法啊。

00:08:40 - 00:08:41
有沒有結果不法？

00:08:42 - 00:08:43
沒有啊,又沒有事,對不對?

00:08:43 - 00:08:47
所以未遂發生怎麼樣,只有行為不法,而沒有結果不法。

00:08:48 - 00:08:51
好,那這一種反面容許構成要素。

00:08:51 - 00:08:56
如果你認為他客觀上消滅了一個違法的這個事實。

00:08:57 - 00:09:04
這個事實足以抵消掉原本毀損他人財產所形成的結果不法。

00:09:04 - 00:09:05
那你看喔。

00:09:05 - 00:09:10
毀損罪的結果不法被抵銷掉了。

00:09:10 - 00:09:12
這時候只剩什麼？

00:09:12 - 00:09:12
行為不法。

00:09:13 - 00:09:15
那只有行為不法，沒有結果不法。

00:09:15 - 00:09:15
這個叫什麼呢？

00:09:16 - 00:09:16
就未遂犯啊。

00:09:16 - 00:09:18
所以這個是三階論的未遂說。

00:09:19 - 00:09:20
三階論的未遂說啊。

00:09:21 - 00:09:24
你旁邊可以括號寫一個關鍵字，叫做結果不法的抵銷。

00:09:26 - 00:09:28
因為我剛剛講的這個說明很抽象。

00:09:29 - 00:09:32
你就算理解，在考試上你要寫出來，可能會遇到一些困難。

00:09:32 - 00:09:36
所以它的關鍵字叫做結果不法之抵銷。

00:09:36 - 00:09:39
這個說法聽下來會覺得轉得有點硬啊。

00:09:39 - 00:09:41
至少我自己是這樣覺得啦。

00:09:41 - 00:09:44
就覺得二階論的結論還不錯，又不想踩二階論怎麼辦？

00:09:44 - 00:09:46
三階論裡面動手腳，對啊，就只好這樣做哈。

00:09:47 - 00:09:49
所以這個叫做結果不法的抵銷。

00:09:49 - 00:09:52
結論上來說呢，還是對行為人未遂犯。

00:09:54 - 00:09:55
好。

00:09:55 - 00:09:56
那二階論我剛剛講過了。

00:09:57 - 00:10:00
踩二階論的話，本來就會得出未遂

00:10:00 - 00:10:00
一般的結論。

00:10:01 - 00:10:06
所以各位啊，我們在面臨反面容許構成要件錯誤這個問題的時候，我們要怎麼來寫作？

00:10:07 - 00:10:09
通常來講，你就是列兩說。

00:10:10 - 00:10:11
氣稅說，還有未遂說。

00:10:12 - 00:10:13
氣稅說我剛剛講的嘛，很簡單。

00:10:13 - 00:10:17
氣稅說的意思就是反面容許構成要件錯誤，不會有任何的效果。

00:10:18 - 00:10:21
而未遂說的關鍵是叫結果不法的抵銷，所以論未遂犯。

00:10:22 - 00:10:24
那你說二階段未遂說要怎麼講？

00:10:24 - 00:10:25
哎呀，更簡單，二階段稅說。

00:10:26 - 00:10:29
你就在未遂說的後面括號寫一句話。

00:10:29 - 00:10:30
如果才二階段，本來就會得出未遂犯的結論。

00:10:33 - 00:10:36
中間這些推導的流程，我不建議各位去寫，因為很難寫。

00:10:38 - 00:10:40
真的啦，這些流程你能理解你就很棒了。

00:10:41 - 00:10:43
你要能寫出來,那又是一般的功夫。

00:10:43 - 00:10:44
它真的不好寫。

00:10:44 - 00:10:50
所以在考試時間有限的情況之下,你要寫二階段的話,你直接寫在三階段的未稅說後面。

00:10:51 - 00:10:55
直接寫說呢,如果才二階段,本來就會得出未遂犯的結論,就好了,知道嗎?

00:10:55 - 00:10:59
所以反面容許構成要素,它沒有那麼難嘛,對不對?

00:10:59 - 00:11:02
正面的你懂，三階段的結構你懂。

00:11:02 - 00:11:04
反面容許構成要素，那你當然就會懂，所以

00:11:06 - 00:11:07
這部分大概就是這樣。

00:11:07 - 00:11:10
那考試的趨勢來說，我大概跟各位講一下。

00:11:11 - 00:11:14
我大學的時候啊，容許構成要件錯誤，超愛考。

00:11:16 - 00:11:21
所有各類大大小小的考試，一天到晚都在考這個東西，都在考那個容許構成錯誤。

00:11:21 - 00:11:23
誤想防衛啊，誤想避難什麼的。

00:11:23 - 00:11:24
我大學的時候超愛考。

00:11:25 - 00:11:27
現在啊，容許構成要件錯誤，不是不會考。

00:11:27 - 00:11:29
但機率降低，因為十幾年前就被考爛了。

00:11:32 - 00:11:35
所以現在反而愛考什麼呢？反面容許構成要件錯誤。

00:11:36 - 00:11:38
所以真的，在以前我大學那個時候，比較喜歡考正面系列，就是誤想系列。

00:11:42 - 00:11:43
因為誤想系列考十幾年考爛了。

00:11:43 - 00:11:46
所以現在呢，反而流行考反面的系列，偶然的系列。

00:11:48 - 00:11:55
所以這幾年我統計下來發現，反面容許構成要件錯誤的出題機率，比正面的誤想系列還要來得高。

00:11:55 - 00:11:59
所以這幾年的考試，各位多注意這個東西，反面的容許構成。

00:12:00 - 00:12:01
構成要件錯誤。

00:12:01 - 00:12:01
好。

00:12:01 - 00:12:04
那同樣是考試的解題技巧，

00:12:05 - 00:12:09
不管是正面的或者是反面的容許構成要件錯誤。

00:12:10 - 00:12:11
不管是哪一類喔,

00:12:11 - 00:12:16
我們記得寫作的位置都放在違法性

00:12:16 - 00:12:17
知道是吧?

00:12:17 - 00:12:18
都放在違法性。

00:12:18 - 00:12:20
因為它是違法性的問題嘛,

00:12:20 - 00:12:20
很簡單對不對？

00:12:20 - 00:12:21
它是違法性的問題。

00:12:22 - 00:12:23
其實嚴格來講是這樣，

00:12:24 - 00:12:27
容許構成要件錯誤就是誤想的類型，

00:12:27 - 00:12:29
你要寫在罪責也可以。

00:12:30 - 00:12:31
因為其實有點尷尬，

00:12:31 - 00:12:33
誤想系列它是違法性的問題，

00:12:33 - 00:12:36
可是你發現它的癥結在哪裡處理？

00:12:36 - 00:12:37
在罪責處理，

00:12:37 - 00:12:37
對不對？

00:12:37 - 00:12:39
所以這個問題你寫在違法性或罪責都可以。

00:12:40 - 00:12:42
只是這樣記很麻煩啦。

00:12:43 - 00:12:46
我講得太多太細，同學到後面會產生記憶的混淆。

00:12:46 - 00:12:51
所以你就乾脆記得，反正這些錯誤，它是違法性的錯誤嘛，所以寫哪裡？就寫違法性嘛，這樣記最簡單。

00:12:52 - 00:12:52
知道嗎？

00:12:53 - 00:12:55
我們記憶，不要去記那個複雜的東西。

00:12:57 - 00:12:58
你當下能記得能理解，

00:12:59 - 00:13:01
不代表你一年後也一定記得理解。

00:13:01 - 00:13:03
人的記憶會混淆，

00:13:03 - 00:13:03
真的。

00:13:03 - 00:13:06
當你記得很多東西之後,到後面,記憶會亂掉,

00:13:06 - 00:13:07
相信我,

00:13:07 - 00:13:11
所以我這邊呢,就記得一個簡單的說法,這樣就好了。

00:13:31 - 00:13:34
我之前我在臺中上那個刑訴的課程,

00:13:34 - 00:13:36
每次講傳聞法則的時候,

00:13:37 - 00:13:40
我很喜歡講人的記憶會混淆，會被編造這一段。

00:13:41 - 00:13:42
有一本書很好看，

00:13:43 - 00:13:46
這一本書叫做《記憶如何對你說謊》，這是一本很棒的書。

00:13:46 - 00:13:48
它在講的就是人類的心理學，

00:13:48 - 00:13:52
從這個心理學的觀點來講，為什麼人的記憶會錯誤。

00:13:53 - 00:13:55
叫記憶如何對你說謊

00:13:55 - 00:13:57
大概10年前的一本書吧

00:13:57 - 00:13:58
有點久了。

00:13:59 - 00:14:00
這一本

00:14:00 - 00:14:02
書他開頭引了一個案例很有趣。

00:14:03 - 00:14:04
它是一本美國的書。

00:14:04 - 00:14:06
這本書在講述，

00:14:06 - 00:14:08
他就做了一個實驗。

00:14:08 - 00:14:10
這個實驗啊，

00:14:10 - 00:14:11
是主持人，

00:14:11 - 00:14:14
他就隨機地去訪問路人。

00:14:15 - 00:14:18
先問他們小時候有沒有跟家人去過迪士尼樂園，

00:14:18 - 00:14:19
這是第一個，

00:14:19 - 00:14:21
因為這個是美國小朋友很多共同的回憶。

00:14:21 - 00:14:24
第一個就問說呢，有沒有去過迪士尼樂園？

00:14:24 - 00:14:27
如果這題的答案是肯定的話，

00:14:28 - 00:14:29
接著第二個問題很有趣喔。

00:14:30 - 00:14:31
第二個問題，

00:14:31 - 00:14:33
這個實驗者就問說，

00:14:33 - 00:14:35
那你在迪士尼樂園裡面，

00:14:35 - 00:14:39
有沒有跟那隻灰色的兔寶寶人偶擁抱過或合照過？

00:14:40 - 00:14:41
他這樣問。

00:14:41 - 00:14:43
說你們在迪士尼樂園裡面，

00:14:43 - 00:14:46
跟灰色的那一隻兔寶寶擁抱或合照過。

00:14:48 - 00:14:48
結果，

00:14:48 - 00:14:50
有大概一半的人都說是

00:14:50 - 00:14:51
有這樣的經驗。

00:14:52 - 00:14:53
這問題很怪啊。

00:14:54 - 00:14:55
你們發現問題在哪裡？

00:14:56 - 00:14:58
灰色的兔寶寶是華納的卡通人物欸

00:14:58 - 00:15:00
怎麼會出現在迪士尼樂園？

00:15:01 - 00:15:02
這就好像，

00:15:03 - 00:15:05
你在摩斯漢堡裡面，

00:15:06 - 00:15:07
不可能吃過麥香魚，

00:15:08 - 00:15:09
這是一樣的意思。

00:15:09 - 00:15:10
對,

00:15:10 - 00:15:10
真的不可能。

00:15:10 - 00:15:12
結果竟然有一半多的美國人都說,

00:15:12 - 00:15:13
有啊有啊,

00:15:13 - 00:15:16
我有在裡面跟那個兔寶寶的人偶合照過。

00:15:17 - 00:15:18
剩下大概六成，

00:15:18 - 00:15:21
剩下大概四成左右說沒有的，

00:15:21 - 00:15:23
實驗者就故意誘導他。

00:15:23 - 00:15:25
就說你確定真的沒有嗎？

00:15:26 - 00:15:29
你在迪士尼樂園裡面有沒有遇過那個米老鼠的人偶？

00:15:29 - 00:15:31
米老鼠有嗎,對不對?

00:15:31 - 00:15:32
唐老,唐老鴨有沒有?

00:15:33 - 00:15:34
好像也有。

00:15:34 - 00:15:35
高飛狗有沒有?

00:15:35 - 00:15:36
好像也有。

00:15:36 - 00:15:37
那你再仔細想一想，

00:15:37 - 00:15:38
有沒有兔寶寶？

00:15:39 - 00:15:40
好像有欸。

00:15:40 - 00:15:40
對啊，

00:15:40 - 00:15:42
所以很多人經過適度的引導之後，

00:15:42 - 00:15:44
剩下那些說不確定的,

00:15:44 - 00:15:46
有兩三成也倒戈的就說有。

00:15:47 - 00:15:48
人的記憶是可以被編造的。

00:15:49 - 00:15:49
真的啦,

00:15:49 - 00:15:51
相信我是可以被編造的。

00:15:51 - 00:15:51
所以我才說，

00:15:52 - 00:15:53
我們有時候在學習的時候啊，

00:15:53 - 00:15:55
有些太複雜的理論，

00:15:55 - 00:15:57
我不會建議同學去記，

00:15:57 - 00:15:57
就是這樣子。

00:15:58 - 00:15:59
你當下會記得,

00:15:59 - 00:16:00
但是後面

00:16:00 - 00:16:03
你學的其他東西,學的其他理論,到最後有可能會攪在一起,

00:16:04 - 00:16:06
就產生了一個不存在的理論,真的會這樣哦。

00:16:08 - 00:16:10
好,然後我們剛剛有一個題目沒有特別去看,

00:16:10 - 00:16:12
來137頁這一題，我們來看一下。

00:16:40 - 00:16:42
好，137這一題。

00:16:43 - 00:16:47
這一題當中在考的就是誤想的依法令行為，

00:16:48 - 00:16:49
誤想的依法令。

00:16:50 - 00:16:52
或者是說誤想的公務員上級命令，也可以。

00:16:53 - 00:16:54
就是21條的問題了。

00:16:55 - 00:16:55
我們記得喔,

00:16:56 - 00:17:02
誤想系列或偶然系列,所有的阻卻違法事由都有適用的空間。

00:17:03 - 00:17:05
所以不要以為只有正當防衛緊急避難才有,不是喔,

00:17:06 - 00:17:09
所有的阻卻違法事由當然都會有誤想,

00:17:10 - 00:17:13
當然也都會有偶然，這個是必然的喔。

00:17:13 - 00:17:14
所以這邊我們講說嘛，

00:17:15 - 00:17:18
正當防衛有誤想，緊急避難有誤想。

00:17:18 - 00:17:20
業務上正當行為會誤想，會啊。

00:17:21 - 00:17:22
21條會誤想。

00:17:22 - 00:17:23
當然也會啊,

00:17:24 - 00:17:27
甚至超法規阻卻違法，是有被害人承諾會不會誤想？

00:17:27 - 00:17:28
會，當然也會，知道吧？

00:17:28 - 00:17:32
所以這一題是什麼呢？誤想的公務員以上級命令。

00:17:33 - 00:17:36
因為你看嘛，實際上拆的那一棟根本就不是違建。

00:17:37 - 00:17:38
他搞錯了，對不對？

00:17:38 - 00:17:46
所以對於他實際上所執行拆除的那一棟建築來講，客觀上根本沒有一個上級命令存在。

00:17:47 - 00:17:51
可是行為人主觀上呢，卻覺得有那個命令存在。

00:17:51 - 00:17:53
所以就誤想的上級命令啊，

00:17:53 - 00:17:54
就這麼簡單啊，對不對？

00:17:54 - 00:17:55
所以這一題就是這樣子喔。

00:17:57 - 00:17:59
好，然後我這邊再跟同學補充一件事喔。

00:18:00 - 00:18:02
誤想系列當中，多數說的結論是什麼？

00:18:04 - 00:18:10
阻卻故意是情況改動，過失犯，對不對，我們一直強調嘛，阻卻故意是情況改動的過失犯。

00:18:10 - 00:18:18
那我這邊要跟同學講的是啊，這裡所謂的阻卻故意是情況改動，過失犯。

00:18:18 - 00:18:24
各位，這裡的過失啊，並不是說行為人對實現構成要件有沒有過失。

00:18:25 - 00:18:25
過失。

00:18:26 - 00:18:28
因為實現構成要件都已經有故意了，怎麼可能沒過失，對不對？

00:18:29 - 00:18:34
所以我們這裡講的過失是指什麼呢？行為人對於發生誤想有沒有過失？

00:18:35 - 00:18:35
記得喔。

00:18:35 - 00:18:45
所以誤想防衛這邊改「頓」的過失，你怕忘記的話可以寫一下，誤想防衛這邊改「頓」的過失，看的不再是行為人對構成要件的結果有沒有過失。

00:18:46 - 00:18:48
你講對構成要件的結果有沒有過失，那個沒有意義。

00:18:49 - 00:18:51
因為他對構成要件的結果已經有故意的，他不可能沒有過失。

00:18:51 - 00:18:58
所以這裡的過失指的是呢，行為人對於會發生誤想的這一件事有沒有過失。

00:18:58 - 00:18:59
變成這個東西。

00:18:59 - 00:19:02
行為人對於發生誤想這件事有沒有過失。

00:19:04 - 00:19:06
好，所以容許構成要件錯誤這個東西，這個我們就看到這邊。

00:19:09 - 00:19:11
那我這邊也跟同學分享一下了，就是我剛剛說的。

00:19:13 - 00:19:17
我們法律這種科目啊，它的單元之間

00:19:18 - 00:19:23
比較不會有這一種一層一層往上疊，前面簡單，後面難，比較沒有這樣的概念。

00:19:23 - 00:19:29
所以像我剛剛講的，容許構成要件錯誤跟反面容許構成要件錯誤這一段。

00:19:30 - 00:19:35
如果有同學是你第一次學法律，第一次學刑法，覺得哎呀，這一段怎麼那麼昏啊，看不太懂。

00:19:36 - 00:19:38
沒關係，你不要一直卡在這邊。

00:19:38 - 00:19:43
你就接著往下看，接著往下上，上正當防衛及避難。

00:19:43 - 00:19:45
剛剛我講了那些那一系列的錯誤。

00:19:45 - 00:19:48
你把整個違法性學完再回來看，那也OK，那也沒有不行。

00:19:51 - 00:19:52
我的習慣是這樣的。

00:19:52 - 00:19:54
在律師司法官的課程當中，因為大部分的同學都是法律系畢業的，都有經驗，都有這個法律的基礎。

00:19:59 - 00:20:00
所以

00:20:00 - 00:20:00
我就順著這樣上下來。

00:20:02 - 00:20:11
可是我在一般國考的課程，尤其是四等的課程當中，這些的時候，我反而會等主觀違法事由講完，再回來說。

00:20:11 - 00:20:18
因為對於一般四等同學第一次學法律的同學來講，還沒有講各種主觀違法事由，我就先講錯誤。

00:20:19 - 00:20:20
同學反而會覺得太硬，所以這個東西沒有一定的順序問題。

00:20:22 - 00:20:24
真的啦，學法律就是這樣。

00:20:24 - 00:20:27
它的單元之間關聯性沒有那麼強烈。

00:20:27 - 00:20:32
所以如果你這個東西不懂,你看第二遍還不懂,沒關係,你就先略過。

00:20:32 - 00:20:35
也許整部刑法看完之後,你再回來看,你就可以懂了,所以不要一直卡在這個地方。

00:20:39 - 00:20:43
好,接下來我們來看到140頁,我們就來看到各種不同的阻卻違法事由。

00:20:43 - 00:20:46
這裡呢,我們先來看到。

00:20:47 - 00:20:48
正當防衛。

00:20:48 - 00:20:52
其實照法條的順序啊，是21、22、23、24。

00:20:52 - 00:20:54
可是我們這裡先來講正當防衛。

00:20:54 - 00:20:58
理由在於什麼？正當防衛，這一種阻卻違法事由。

00:20:59 - 00:21:01
第一個他最常見，考試最常出現，這是第一個。

00:21:02 - 00:21:08
再來第二個的話呢，這一種阻卻違法事由，他所涉及到的爭議最多。

00:21:09 - 00:21:11
所以涉及到這種主觀想法事由的話。

00:21:11 - 00:21:17
我們可以藉此來把整個違法性的體系學得更好、更完整，就我們這邊呢，先講正當防衛。

00:21:19 - 00:21:20
好，正當防衛啊，條文說：

00:21:21 - 00:21:29
對於現在不法侵害呢，出於防衛自己或第三人權利的行為，這是不罰的。

00:21:30 - 00:21:32
所以正當防衛基本的想法是這樣。

00:21:33 - 00:21:40
你是一個合法的人，那麼對於不法侵害來臨的時候，你沒有義務要向那個侵害者低頭，這個是正當防衛的想法。

00:21:41 - 00:21:45
所以在正當防衛之下，當你面臨一個現在不法侵害的時候。

00:21:46 - 00:21:49
你不用先躲避，你也不用先報警。

00:21:50 - 00:21:52
你有權力直接打回去，這個是正當防衛基本的想法。

00:21:54 - 00:21:56
它就是一種個人權力的保護行為。

00:21:58 - 00:22:00
那左邊的圖，我們大概可以對照一下。

00:22:00 - 00:22:01
我們再想一次喔，

00:22:01 - 00:22:04
所有的主權違法是有，

00:22:04 - 00:22:06
一定都是這三個，

00:22:06 - 00:22:09
前提事實，手段適當。

00:22:09 - 00:22:11
還有主觀上要有認知,

00:22:12 - 00:22:13
三者都要具備,

00:22:13 - 00:22:14
你看正當防衛也是,

00:22:15 - 00:22:17
正當防衛的前提事實是什麼呢?

00:22:17 - 00:22:18
現在不法侵害,

00:22:19 - 00:22:20
手段的話是什麼呢?

00:22:21 - 00:22:21
不能過當,

00:22:22 - 00:22:23
然後主觀上要有什麼呢?

00:22:23 - 00:22:24
要有防衛意識,

00:22:24 - 00:22:25
一樣嘛,

00:22:25 - 00:22:25
對不對?

00:22:25 - 00:22:28
好，所以我們這邊就來看到142頁這邊喔。

00:22:28 - 00:22:30
我們這裡就來看到正當防衛的前提事實。

00:22:31 - 00:22:32
現在不法侵害。

00:22:34 - 00:22:35
要成立正當防衛。

00:22:36 - 00:22:38
要有一個現在的不法侵害存在,

00:22:39 - 00:22:40
所以我們講第一個,

00:22:40 - 00:22:42
侵害要具有現在性,

00:22:43 - 00:22:45
侵害也要具有不法性,

00:22:46 - 00:22:49
同時它要是一個人所為的侵害,

00:22:49 - 00:22:50
所以這個是我們講三大要件,

00:22:51 - 00:22:52
現在不法侵害,

00:22:52 - 00:22:53
所以首先第一個,

00:22:53 - 00:22:57
我們就照文字的順序,來看第一個叫做現在的侵害,

00:22:58 - 00:22:59
所謂的現在侵害,

00:23:00 - 00:23:03
我們通常會用一個反面的方式去做剔除

00:23:03 - 00:23:04
什麼意思呢?

00:23:05 - 00:23:07
好,我這邊畫一個圖喔

00:23:42 - 00:23:44
我們會這樣區分

00:23:44 - 00:23:46
現在,過去還有將來

00:23:47 - 00:23:50
我們在判斷到底是不是現在侵害的時候啊,

00:23:50 - 00:23:52
我們通常會用一個反面剔除的方式,

00:23:53 - 00:23:55
我們先去講什麼叫將來的侵害,

00:23:56 - 00:23:58
再去講什麼叫過去的侵害,

00:23:58 - 00:23:59
只要這個

00:24:00 - 00:24:01
侵害

00:24:01 - 00:24:01
不是將來的

00:24:01 - 00:24:02
不是過去的

00:24:03 - 00:24:05
那它就是現在的侵害。

00:24:05 - 00:24:07
我們通常會用這種反面剔除的方式去做認定。

00:24:09 - 00:24:09
先講，

00:24:10 - 00:24:13
為什麼我們不正面地去定義什麼叫「現在侵害」？

00:24:14 - 00:24:16
這是一個有點技術面的問題。

00:24:16 - 00:24:20
因為你要正面地去定義「現在侵害」，

00:24:20 - 00:24:21
很困難。

00:24:21 - 00:24:24
甚至如果你要去精確的講什麼叫現在的話,

00:24:25 - 00:24:29
嚴格意義的現在，根本就不存在。

00:24:30 - 00:24:31
你們有沒有想過一個問題？

00:24:32 - 00:24:34
嚴格意義的現在，真的不存在。

00:24:35 - 00:24:36
真的啦！

00:24:36 - 00:24:37
真的不存在，為什麼？

00:24:38 - 00:24:39
先講第一個例子。

00:24:41 - 00:24:45
其實我們講中文的人啊，經常很不精確地使用「現在」這兩個字。

00:24:46 - 00:24:47
真的啊。

00:24:48 - 00:24:51
如果我跟我們的同事說，

00:24:51 - 00:24:53
那個，幫我拿一瓶水進來。

00:24:54 - 00:24:55
同事說，好好好，我現在去拿給你。

00:24:56 - 00:24:58
他說我現在去拿給你，

00:24:58 - 00:24:59
這句話是有問題的。

00:25:00 - 00:25:02
真的啊，這句話當然有問題啊。

00:25:02 - 00:25:04
他說我現在去拿給你。

00:25:04 - 00:25:04
他什麼時候拿給你？

00:25:05 - 00:25:07
他五秒之後拿給你。

00:25:07 - 00:25:08
五秒之後怎麼會是現在？

00:25:09 - 00:25:10
五秒後就是將來啊。

00:25:11 - 00:25:12
文法應該不能講現在吧,

00:25:12 - 00:25:14
應該說好，我馬上拿給你。

00:25:14 - 00:25:15
其實這樣講才對吧。

00:25:16 - 00:25:21
對啊，所以其實我們日常生活當中講的現在，很多其實不是現在。

00:25:21 - 00:25:22
那是將來。

00:25:22 - 00:25:22
對吧？

00:25:23 - 00:25:23
這是第一個。

00:25:24 - 00:25:25
還有再來，

00:25:25 - 00:25:26
那我們想一想，所以什麼叫現在？

00:25:27 - 00:25:30
為什麼我說嚴格意義的現在根本就不存在？

00:25:31 - 00:25:32
你們想啊,

00:25:32 - 00:25:34
此時此刻,你們坐在位置上,

00:25:35 - 00:25:38
眼睛看到我站在黑板前,

00:25:38 - 00:25:40
耳朵聽到我講話。

00:25:41 - 00:25:42
你沒想過啊,

00:25:42 - 00:25:45
你感受到一切的時候,其實一切都過去了。

00:25:46 - 00:25:46
真的啊。

00:25:47 - 00:25:50
因為聲音要經過空氣,進到你的耳朵。

00:25:50 - 00:25:53
你的大腦要產生聽覺的反應。

00:25:53 - 00:25:55
這中間可能是0.00幾秒的時間。

00:25:56 - 00:25:56
對吧？

00:25:57 - 00:25:58
看也是啊。

00:25:58 - 00:25:59
當你看到我

00:26:00 - 00:26:01
我站在講臺上，

00:26:01 - 00:26:03
看到我的影像，

00:26:03 - 00:26:05
光進到你的眼睛需要時間。

00:26:06 - 00:26:10
眼睛的這個視覺傳導到大腦,

00:26:10 - 00:26:14
大腦產生出看到的感受，也需要時間。

00:26:14 - 00:26:17
雖然這個時間非常非常的短,

00:26:17 - 00:26:20
可是其實當你感受到一些的時候，一切都已經過去了。

00:26:20 - 00:26:20
對吧？

00:26:21 - 00:26:26
所以我說，正當防衛的現在，如果你要拘泥於文字字這個嚴格的意義，

00:26:26 - 00:26:28
那完蛋了，現在根本就不存在嘛。

00:26:28 - 00:26:31
所以我們怎麼辦？只好用反面提出的方式。

00:26:31 - 00:26:35
反正，不是將來，不是過去，就可以正當防衛。

00:26:35 - 00:26:36
好，那我們接著再來說，

00:26:38 - 00:26:39
那為什麼對將來的侵害，

00:26:40 - 00:26:44
為什麼對過去的侵害不可以正當防衛呢？

00:26:44 - 00:26:46
對啊，為什麼對將來對過去不能正當防衛？

00:26:46 - 00:26:48
來，第一個，將來的侵害。

00:26:49 - 00:26:52
為什麼一個將來的侵害，你不可以拿它正當防衛？

00:26:53 - 00:26:54
哎呀，你想嘛，

00:26:55 - 00:26:56
如果你在醫院的美食街，

00:26:57 - 00:27:16
看到隔壁桌坐的

00:27:16 - 00:27:41
一群詐騙集團的成員

00:27:41 - 00:27:46
這些詐騙集團的成員，他們在美食街裡面啊，高聲談話。

00:27:46 - 00:27:49
他們在講說等一下要怎麼去騙老人的錢

00:27:50 - 00:27:51
你坐在他們旁邊

00:27:52 - 00:27:53
你非常有正義感

00:27:53 - 00:27:55
你希望他們不要去做詐騙

00:27:55 - 00:27:58
於是呢，你就過去把他們狂打一頓

00:27:59 - 00:28:00
讓他們變得斷手斷腳的，全部都進了急診室，沒辦法去做詐騙了。

00:28:00 - 00:28:00
去把它踹到水溝裡面。

00:28:02 - 00:28:03
同學啊，這個不叫防衛，這個叫報復。

00:28:05 - 00:28:07
對，這個叫報復，這個不叫防衛。

00:28:08 - 00:28:09
他揍完你要離開了。

00:28:10 - 00:28:11
他已經要離開了。

00:28:11 - 00:28:13
結果你把他踹到水溝裡面。

00:28:14 - 00:28:17
這對於你原本被打傷的那個部分來說有什麼幫助？

00:28:18 - 00:28:18
沒有。

00:28:19 - 00:28:20
你就是報復他覺得爽而已。

00:28:21 - 00:28:23
在法律上來講，報復不會是一種權利。

00:28:24 - 00:28:25
因為報復於事無補。

00:28:25 - 00:28:28
我常講，報復是我們人類的一種很野蠻的本能。

00:28:29 - 00:28:33
這種本能，除了讓我們爽之外，沒有其他更積極的功能存在。

00:28:34 - 00:28:35
所以報復不會是一種權利，知道吧？

00:28:35 - 00:28:38
所以為什麼對過去現在不能防衛？

00:28:38 - 00:28:40
侵害過去的你防衛沒有意義啊，那個叫報復啊。

00:28:41 - 00:28:44
好，所以我們接著就來看到下面這邊。

00:28:45 - 00:28:46
（一）

00:28:46 - 00:28:50
那未來跟現在的侵害，我們要怎麼區分呢？

00:28:51 - 00:28:53
所以啊，關於來我這邊畫線哈。

00:28:54 - 00:28:57
綠色的這一條線，它的界線在哪裡？

00:28:58 - 00:29:00
你來看下面有各種不同的說法。

00:29:01 - 00:29:01
你看喔。

00:29:02 - 00:29:03
左手標準說。

00:29:04 - 00:29:05
有效防衛說。

00:29:06 - 00:29:07
預備最後階段說。

00:29:08 - 00:29:10
還有具體危險說。

00:29:11 - 00:29:13
圈圈是那個具體危險說啊。

00:29:14 - 00:29:17
那個，這個是比較少數說了，虛之老師個人的看法。

00:29:17 - 00:29:19
這一說不會沒有關係。

00:29:19 - 00:29:25
我們主要要記得的是123這三說，因為這三說是比較主流的說法。

00:29:27 - 00:29:27
我們看好。

00:29:28 - 00:29:32
最早以前有一種說法叫做左手標準說。

00:29:33 - 00:29:35
這個左手標準說的意思呢，就是說啊。

00:29:37 - 00:29:44
我們要成立正當防衛的話，必須這個侵害者的行為已經達到了未遂犯的著手階段。

00:29:46 - 00:29:47
那才可以正當防衛喔。

00:29:48 - 00:29:51
如果還沒有到著手階段的話，他

00:29:51 - 00:29:55
就不是正當防衛的對象，這是第一個說法，叫著手標準說。

00:29:56 - 00:29:58
再來第二說是最寬鬆的，它叫做有效。

00:30:00 - 00:30:01
範圍說。

00:30:01 - 00:30:02
這一說啊，

00:30:02 - 00:30:03
最寬。

00:30:03 - 00:30:03
為什麼？

00:30:03 - 00:30:07
因為它完全不管這個侵害行為的時空密集性。

00:30:07 - 00:30:07
他不管,

00:30:08 - 00:30:09
他只問一件事:

00:30:10 - 00:30:16
錯過這個時間點，會不會讓防衛變得困難或不切實際？

00:30:16 - 00:30:21
如果錯過這個時間點，就會讓防衛變得困難或不切實際的話，

00:30:21 - 00:30:25
這個時間點就是最後有效的防衛時點。

00:30:25 - 00:30:30
至於這個時點跟侵害的發生有沒有具有時空的密集性，它一點都不重要。

00:30:31 - 00:30:31
這是第二說，

00:30:31 - 00:30:32
叫做預備，

00:30:32 - 00:30:34
這個是第二說叫有效防衛說。

00:30:35 - 00:30:38
最後第三說啊，叫做預備的最後階段說。

00:30:38 - 00:30:40
這個是目前實務採的看法。

00:30:42 - 00:30:44
我講一下什麼叫預備最後階段。

00:30:44 - 00:30:46
先講什麼叫預備。

00:30:46 - 00:30:48
我們刑法上很多犯罪都有罰預備,

00:30:48 - 00:30:49
像殺人罪啊,

00:30:49 - 00:30:50
放火罪啊什麼的,

00:30:50 - 00:30:50
都有罰預備。

00:30:51 - 00:30:52
我們講什麼叫預備。

00:30:53 - 00:30:56
預備的意思是犯罪的準備階段,

00:30:56 - 00:30:57
那個叫預備。

00:30:57 - 00:30:59
那同學你要知道一件事,

00:30:59 - 00:31:02
預備啊,其實範圍很廣。

00:31:02 - 00:31:03
比如說我問各位,

00:31:03 - 00:31:05
什麼叫殺人的預備行為?

00:31:07 - 00:31:08
你從近到遠去推,

00:31:08 - 00:31:10
什麼叫殺人的預備行為？

00:31:10 - 00:31:11
你想啊，

00:31:11 - 00:31:14
我拿刀埋伏在被害人家門口，是不是預備？

00:31:14 - 00:31:14
是，

00:31:14 - 00:31:15
對不對？

00:31:15 - 00:31:16
那往前一步呢？

00:31:16 - 00:31:20
我帶著刀走到被害人的家上的那個路上，

00:31:20 - 00:31:20
那是不是預備？

00:31:20 - 00:31:21
那也是。

00:31:21 - 00:31:22
好。

00:31:22 - 00:31:22
再往前呢？

00:31:23 - 00:31:25
我去五金行買刀是不是預備？

00:31:25 - 00:31:25
是。

00:31:25 - 00:31:26
這也是。

00:31:26 - 00:31:27
接著再往前呢？

00:31:27 - 00:31:28
那我買刀前，

00:31:29 - 00:31:32
我在網路上查哪裡賣刀比較便宜，

00:31:33 - 00:31:34
我要網購呢，

00:31:34 - 00:31:35
還是我要去大潤發，

00:31:36 - 00:31:38
還是我要去家裡附近的五金行？

00:31:38 - 00:31:40
這個查詢比較的過程是不是一種預備？

00:31:40 - 00:31:41
是，

00:31:41 - 00:31:41
其實也是。

00:31:41 - 00:31:42
那再往前，

00:31:43 - 00:31:45
我在思考我要怎麼殺人？

00:31:45 - 00:31:46
我要毒殺還是刀殺？

00:31:47 - 00:31:49
於是我去調查被害者的行蹤。

00:31:49 - 00:31:50
這個是不是預備的？

00:31:50 - 00:31:50
對。

00:31:50 - 00:31:50
這也是。

00:31:51 - 00:31:51
所以你會發現,

00:31:52 - 00:31:55
因為預備的定義是指犯罪的準備行為,

00:31:56 - 00:31:57
準備可能有近的,

00:31:57 - 00:31:58
有遠的,

00:31:58 - 00:32:00
當然不是所有

00:32:00 - 00:32:03
所有的準備階段，都要賦予相對人防衛的權利。

00:32:03 - 00:32:04
所以第三說叫什麼呢？

00:32:04 - 00:32:06
預備的最後階段。

00:32:06 - 00:32:08
預備最後階段什麼意思？

00:32:08 - 00:32:13
就是他準備到，下一步就要真的動手了。

00:32:14 - 00:32:19
那個動手前的最後一步，它叫做預備的最後階段，

00:32:19 - 00:32:20
懂這意思哈。

00:32:22 - 00:32:24
好，這個是第三說哈，預備最後階段說。

00:32:25 - 00:32:28
那第四說啊，叫做具體危險說，

00:32:28 - 00:32:28
你看哦。

00:32:29 - 00:32:33
這一說看什麼呢？侵害者的行為是否也變成即將變成侵害？

00:32:33 - 00:32:38
如果遲延防衛，就會呢，讓防衛變得不成功，

00:32:39 - 00:32:41
或防衛者可能要承擔更大的風險，

00:32:41 - 00:32:43
這個叫做具體危險說。

00:32:43 - 00:32:45
它跟有效防衛說有那麼一點點像。

00:32:46 - 00:32:49
但是具體危險說，它會比較強調那個時空上的密切性。

00:32:49 - 00:32:51
這叫具體危險說，那我說了，

00:32:51 - 00:32:56
第四說你不記得沒有關係，因為這是一個比較冷門的，而不能說冷門啦，就是徐志人老師個人的看法。

00:32:57 - 00:33:16
通說跟一般的教科書，

00:33:16 - 00:33:43
比較會介紹的是123這三說。

00:33:43 - 00:33:46
懂嗎？這個比較會介紹的是這個123這三說。

00:34:00 - 00:34:01
爸還在找人的時候啊,

00:34:01 - 00:34:03
大兒子先下手為強,

00:34:03 - 00:34:05
用平底鍋重擊爸爸的後腦勺,

00:34:05 - 00:34:07
把爸爸打倒在地。

00:34:07 - 00:34:08
就是這樣的案例,

00:34:08 - 00:34:09
平底鍋萬。

00:34:10 - 00:34:12
各位，在平底鍋萬當中，

00:34:12 - 00:34:15
你說這個大兒子把爸爸打倒在地的行為，

00:34:15 - 00:34:19
算不算是對現在侵害的正當防衛。

00:34:20 - 00:34:21
來，三說我們跑一遍。

00:34:22 - 00:34:24
用這個案例來講，訴說。

00:34:25 - 00:34:27
著手標準來說，算不算現在侵害？

00:34:28 - 00:34:28
不算。

00:34:29 - 00:34:30
爸爸還在找人啊！

00:34:31 - 00:34:31
哪有著手？

00:34:31 - 00:34:32
對不對？

00:34:32 - 00:34:32
不算。

00:34:33 - 00:34:34
有效防衛理論算不算？

00:34:35 - 00:34:35
算。

00:34:35 - 00:34:36
等找到就被打了嘛。

00:34:37 - 00:34:37
對,當然算。

00:34:38 - 00:34:40
預備最後階段算不算？

00:34:40 - 00:34:41
當然也算。

00:34:42 - 00:34:43
爸爸在找人啊，找到就開打了，

00:34:43 - 00:34:44
所以當然算。

00:34:44 - 00:34:45
差別在這邊，

00:34:45 - 00:34:46
知道吧？

00:34:46 - 00:34:46
好。

00:34:47 - 00:34:48
我們再舉一個例子。

00:34:50 - 00:34:51
家暴殺夫的案件。

00:34:52 - 00:34:53
下面的黑色圈圈二，

00:34:53 - 00:34:54
家暴殺夫的案件。

00:34:55 - 00:34:58
這一種家暴殺夫的案件當中，

00:34:58 - 00:34:59
有一個特徵。

00:35:01 - 00:35:04
通常，通常這種家暴而殺人的案例。

00:35:04 - 00:35:09
應該說被家暴的人忍無可忍，終於把家暴者給殺掉的這一種案例，

00:35:09 - 00:35:10
我跟各位說，

00:35:10 - 00:35:15
這一種案例，通常家暴者是男性，被害者是女性。

00:35:16 - 00:35:20
而且啊，通常雙方的實力往往有很大的差距。

00:35:20 - 00:35:23
不然另外一方不會被打那麼久，通常不是這樣子。

00:35:24 - 00:35:26
所以我們想像一個極端的情境。

00:35:27 - 00:35:30
家暴男是館長那種身材。

00:35:31 - 00:35:33
被家暴的女生是一個

00:35:33 - 00:35:35
身高只有150，

00:35:35 - 00:35:37
體重只有40公斤。

00:35:37 - 00:35:39
非常嬌小的一個女生,

00:35:39 - 00:35:41
假設是這樣的組合,

00:35:41 - 00:35:43
那你們想，這樣的組合之下,

00:35:44 - 00:35:46
那個女生怎麼可能有勝算？

00:35:47 - 00:35:48
遇到老公家暴，永遠就是捱打的份。

00:35:48 - 00:35:49
對不對？

00:35:49 - 00:35:50
好，有一天，

00:35:51 - 00:35:54
這個女生被打很久，忍無可忍了。

00:35:55 - 00:35:59
於是有天這個女生在她老公喝醉酒又熟睡的情況之下，

00:36:00 - 00:36:04
這個女生持刀捅死了她的丈夫。

00:36:04 - 00:36:10
各位,這樣的案例,這個女生算不算是正當防衛。

00:36:12 - 00:36:13
好,我們看一下各方說法。

00:36:14 - 00:36:18
如果採左手標準說,廢話一定不算,對不對,他老公在睡覺。

00:36:20 - 00:36:22
如果採有效防衛說呢?

00:36:23 - 00:36:24
算喔,為什麼?

00:36:25 - 00:36:27
等他老公醒了,

00:36:28 - 00:36:29
那個女的怎麼防衛啊?

00:36:30 - 00:36:32
雙方身材實力差這麼多,對不對?

00:36:32 - 00:36:35
這個女的要有效可以擊退他老公,

00:36:35 - 00:36:37
勢必只能等他老公熟睡嘛。

00:36:38 - 00:36:42
所以採有效防衛說的話，這一種案例是現在侵害喔。

00:36:42 - 00:36:44
所以我說有效防衛說最寬鬆啊。

00:36:44 - 00:36:46
因為他不問時空密接啊。

00:36:46 - 00:36:50
他只問這個時間點是不是最後有效的時點。

00:36:51 - 00:36:53
那如果採預備最後階段說呢？

00:36:53 - 00:36:53
有沒有算現在？

00:36:54 - 00:36:54
不算嘛。

00:36:55 - 00:36:57
對啊，還在睡覺啦，叫預備最後階段，對不對？

00:36:57 - 00:37:01
所以你會發現有效防衛說其實對行為人最有利，但是呢，

00:37:02 - 00:37:05
對於被防衛的人啊，當然也會承擔更大的風險，這個是有效防衛說。

00:37:07 - 00:37:09
這個東西啊,真的是一個歷久不衰的考點。

00:37:09 - 00:37:15
前陣子我在整理轉學考的考題,去年好像輔大還是哪間,也在考這個東西哦,家暴傷人的案件。

00:37:18 - 00:37:19
好,所以這個是我們講啊,

00:37:19 - 00:37:22
各說的判斷差異。

00:37:22 - 00:37:24
接著來我們翻過來144頁。

00:37:25 - 00:37:27
圈圈三哦。

00:37:27 - 00:37:30
一樣是一個古老的問題，跟現在侵害跟將來

00:37:30 - 00:37:31
侵害的界限有關。

00:37:32 - 00:37:35
這個問題是預先設置的防衛設備，

00:37:36 - 00:37:39
算不算是對現在侵害的防衛。

00:37:40 - 00:37:42
非常老的一個問題喔。

00:37:42 - 00:37:44
預先設置的防衛設備，好，這個指的是什麼呢？

00:37:45 - 00:37:52
很多鄉下人的別墅，他們會在圍牆上面放一個通電的蛇籠。

00:37:52 - 00:37:55
一旦有小偷入侵啊，小偷摸到蛇籠，就會觸電，

00:37:56 - 00:37:59
人就會摔下去，受傷甚至死亡。

00:38:00 - 00:38:01
好，那我們講喔。

00:38:02 - 00:38:07
這一種鄉下別墅的通電蛇籠，可能是什麼時候設置的？

00:38:08 - 00:38:12
很久以前，比如說房子蓋好的時候，20年前，對吧，可能是20年前都設置的。

00:38:14 - 00:38:19
那這個20年前就設置的蛇籠，一直都相安無事。

00:38:19 - 00:38:25
直到20年後的一天，小偷入侵，小偷摸到蛇籠，被電到，摔下去受傷了。

00:38:26 - 00:38:27
這樣的情況之下,

00:38:28 - 00:38:32
這個通電的蛇籠，真的是對現在侵害的防衛嗎？

00:38:32 - 00:38:35
還是它指的是一個對將來侵害的防衛呢？

00:38:35 - 00:38:38
各位啊，這個問題沒有疑問，沒有爭議。

00:38:39 - 00:38:45
我不多說，這種預先設置的防衛設備，無礙於現在侵害的認定。

00:38:47 - 00:38:48
知道嗎？無礙於現在侵害的認定喔，為什麼？

00:38:50 - 00:38:57
因為我們會說啊，雖然這個設備可能是很久以前設置的沒有錯，可是重點在於這個設備什麼時候起作用。

00:38:58 - 00:39:00
小偷來爬牆的時候，

00:39:00 - 00:39:06
對吧，那小偷來爬牆的時候，雖然可能還沒有著手一切，但至少已經著手入侵住區了。

00:39:07 - 00:39:11
所以換句話說，當這個設備起作用的時候，那是什麼時候？

00:39:11 - 00:39:13
那就侵害開始的時候嘛

00:39:13 - 00:39:17
所以因此來說呢，他當然是對現在侵害的防衛，這個並沒有反對的意見。

00:39:20 - 00:39:21
我這邊強調哈，

00:39:22 - 00:39:26
這種東西，它只是現在侵害的部分過得了喔。

00:39:27 - 00:39:29
欸，防衛手段過得了過不了，那個不一定喔。

00:39:30 - 00:39:31
你要看個案，你知道嗎？

00:39:31 - 00:39:37
通電的蛇籠你想像，如果通的是我一般的家用電的一種，摸到會抖一下的，OK啦，過得去。

00:39:39 - 00:39:42
但如果它通的是火車的高壓電的一種呢？

00:39:43 - 00:39:45
有沒有看過影片，那印度人在火車上

00:39:45 - 00:39:46
手舞足蹈的時候摸到高壓電。

00:39:46 - 00:39:47
碰一聲，整個人冒煙，

00:39:47 - 00:39:50
倒下去變焦屍，有沒有看過？網路上看過嗎？

00:39:52 - 00:39:57
如果通電時候通的是火車的高壓電，摸到會瞬間變焦屍，

00:39:57 - 00:39:59
那個絕對防衛過當，好嗎？

00:39:59 - 00:39:59
老師問你。

00:40:00 - 00:40:00
說,

00:40:00 - 00:40:01
這一種東西,

00:40:01 - 00:40:05
它只是現在侵害的，那個現在過得去而已。

00:40:06 - 00:40:07
沒有反對意見喔,

00:40:08 - 00:40:08
沒有,

00:40:08 - 00:40:09
這沒有反對意見。

00:40:10 - 00:40:11
所以我也藉此提醒同學，

00:40:12 - 00:40:13
如果一個學說，

00:40:13 - 00:40:14
如果一個概念，

00:40:15 - 00:40:16
它就是基本概念。

00:40:16 - 00:40:17
大家對他沒有反對意見,

00:40:18 - 00:40:21
那你就不要硬去掰一個反對意見出來寫,

00:40:22 - 00:40:23
那對你沒有好處,

00:40:23 - 00:40:23
知道嗎?

00:40:25 - 00:40:28
我以前幫其他老師改考卷,

00:40:28 - 00:40:29
十年前,

00:40:29 - 00:40:30
我剛出來教沒多久的時候,

00:40:30 - 00:40:31
我幫其他老師改考卷。

00:40:32 - 00:40:36
當時的題目就是這一種預先設置的防禦設備。

00:40:36 - 00:40:37
你知道嗎?

00:40:37 - 00:40:39
竟然很多同學啊,

00:40:39 - 00:40:40
寫否定說。

00:40:41 - 00:40:41
寫否定說,

00:40:41 - 00:40:43
說這裡有反對意見。

00:40:43 - 00:40:44
那我就覺得奇怪,

00:40:45 - 00:40:46
第一份小否定說亂寫，

00:40:46 - 00:40:47
打叉。

00:40:48 - 00:40:49
當時我沒有印章啦，

00:40:49 - 00:40:51
所以當時我就說不要自創學說。

00:40:51 - 00:40:52
那現在我有印章啊。

00:40:53 - 00:40:55
現在我的印章叫法律不是胡亂,

00:40:55 - 00:40:57
那幾屆的同學們幾乎都被蓋過。

00:40:57 - 00:41:18
實體版的法律不是胡亂

00:41:18 - 00:41:42
是少女字的法律不是胡亂

00:41:42 - 00:41:43
加一隻豬,

00:41:43 - 00:41:43
很可愛,

00:41:43 - 00:41:44
很多同學都很喜歡。

00:41:45 - 00:41:47
電子版也有法律不是胡亂。

00:41:48 - 00:41:49
電子版的法律不是胡亂是，

00:41:50 - 00:41:51
一隻豬，

00:41:51 - 00:41:55
那個豬的眼神看起來責任能力有缺陷。

00:41:55 - 00:41:56
舌頭還掉出來

00:41:56 - 00:41:57
上面寫法律不是胡亂

00:41:58 - 00:41:59
這個大家很喜歡

00:41:59 - 00:42:00
很多人也都被我蓋過。

00:42:00 - 00:42:01
看這個問題有沒有爭議說

00:42:01 - 00:42:05
我翻閱七八本覺得很生氣，這根本沒有否定說嘛，為什麼同學要浪費我的時間。

00:42:06 - 00:42:07
所以同學你們想喔，

00:42:08 - 00:42:11
考試考一個東西，它純粹是這同學的基本觀念。

00:42:12 - 00:42:17
這個東西就是基本觀念，在學說、在食物、在德國、在日本、在我國都沒有爭議。

00:42:17 - 00:42:20
結果考生竟然說這裡有否定說。

00:42:20 - 00:42:25
然後還振振有詞地批評否定說，說否定說違反罪刑法定原則不可採。

00:42:25 - 00:42:27
你覺得這個會加分還扣分？

00:42:27 - 00:42:28
一定扣分。

00:42:28 - 00:42:31
對吧，廢話，這沒有否定說你掰出來這個說法當然扣分嘛。

00:42:32 - 00:42:34
所以各位啊，你不要相信一種奇怪的說法。

00:42:34 - 00:42:37
國考考生之間有很多的都市傳說。

00:42:38 - 00:42:41
其中一個都市傳說就是肯否兩說。

00:42:42 - 00:42:47
就是如果一個問題你不會的話，那你就肯否兩說各掰一說，最後再採一說。

00:42:48 - 00:42:49
我大學的時候就聽過這個說法。

00:42:50 - 00:42:51
人家說肯否兩說各掰一說之後採一說。

00:42:52 - 00:42:55
我以前也信啊，後來出來教書越想越覺得不對勁。

00:42:56 - 00:42:57
哪有什麼亂掰一說啊，萬一沒有怎麼辦？

00:42:58 - 00:43:01
所以不要亂掰喔，亂掰的話對各位來說不會有什麼好的效果啦。

00:43:01 - 00:43:06
OK，所以這個是我們講的，過去跟現在跟將來侵害的區分。

00:43:07 - 00:43:08
接著來喔。

00:43:10 - 00:43:10
來,有些人會問,

00:43:11 - 00:43:14
為什麼是將來現在過去,箭頭還往右。

00:43:14 - 00:43:16
為什麼不是過去現在將來?

00:43:17 - 00:43:18
你想像這個畫面,

00:43:19 - 00:43:19
有個人要打我,

00:43:20 - 00:43:21
有個人要打我啊。

00:43:22 - 00:43:25
他走在路上，正要前往我家，

00:43:25 - 00:43:27
這叫將來侵害，對吧？

00:43:28 - 00:43:31
我出現了，他痛打我一頓，這叫現在侵害。

00:43:32 - 00:43:36
打完了，騎馬揚長而去，這叫過去侵害。

00:43:36 - 00:43:37
瞭解這個時序吧,

00:43:38 - 00:43:42
所以是先將來，再現在，接著才過去,

00:43:42 - 00:43:44
我沒有畫反，知道嗎，真的是這樣喔。

00:43:44 - 00:43:50
好，接著往下看喔，那過去侵害跟現在侵害，我們怎麼區分呢？

00:43:52 - 00:43:53
來，各位啊，

00:43:54 - 00:44:00
這邊我再畫好，比如說我畫紅線喔，過去跟現在怎麼區分？

00:44:00 - 00:44:01
分，這邊沒有疑問。

00:44:02 - 00:44:03
我寫，

00:44:04 - 00:44:05
這個區分點叫做，

00:44:06 - 00:44:09
行為的終了，行為的終了。

00:44:12 - 00:44:15
這個區分點，我們看的是行為的終了，

00:44:16 - 00:44:19
請注意，不是既遂，也不是完成，

00:44:19 - 00:44:21
它叫終了。

00:44:21 - 00:44:23
這件事我前面有跟各位講過了，

00:44:24 - 00:44:28
行為的終了，終了就是終了，不是既遂也不是完成。

00:44:28 - 00:44:29
不一樣啊,

00:44:29 - 00:44:33
終了是什麼意思？法益侵害的結束。

00:44:33 - 00:44:38
同學你一定要記得喔，行為終了跟行為的完成不一樣喔。

00:44:39 - 00:44:45
因為我再講一次，你終了跟完成沒有搞懂的話，你以後學相續的共同正犯，一定會卡住。

00:44:46 - 00:44:48
它們不一樣，知道嗎？終了就是法益侵害的結束。

00:44:49 - 00:44:50
它不是行為的完成。

00:44:51 - 00:44:54
好，所以我講，現在侵害跟過去侵害的區分，

00:44:54 - 00:45:01
我們看的並不是行為的既遂，也不是行為的完成，而是行為的終了。

00:45:02 - 00:45:06
當然啦，在大多數的狀態犯，既遂就是終了，

00:45:06 - 00:45:08
沒有什麼區分的意義。

00:45:08 - 00:45:11
對不對，殺人罪、傷害罪那一種就是嘛，既遂就是終了。

00:45:11 - 00:45:14
什麼樣的犯罪，既遂跟終了的時間點會不一樣？

00:45:14 - 00:45:17
第一個像什麼呢？繼續犯，對不對？繼續犯。

00:45:17 - 00:45:21
所以比如說，我把同事鎖在倉庫裡面，

00:45:22 - 00:45:25
鎖進去的瞬間，302既遂。

00:45:26 - 00:45:27
可是302要什麼時候才終了？

00:45:27 - 00:45:29
還要等他被放出來嗎？

00:45:29 - 00:45:32
所以我把它鎖進去之後，接著我出來上課了。

00:45:33 - 00:45:34
這時候他可不可以正當防衛？

00:45:35 - 00:45:35
可以。

00:45:36 - 00:45:37
終了前都可以正當防衛,

00:45:37 - 00:45:38
知道嗎？

00:45:38 - 00:45:39
這是一個例子。

00:45:39 - 00:45:40
好。

00:45:40 - 00:45:44
再來啊，還有什麼犯罪的既遂跟中止是可以拉出來的？

00:45:44 - 00:45:47
財產犯罪，像竊盜那一種。

00:45:47 - 00:45:48
這很特別喔，

00:45:48 - 00:45:50
竊盜它不是繼續犯，

00:45:50 - 00:45:54
但是竊盜罪的既遂跟終了是拉得出來分得開的。

00:45:55 - 00:45:57
這個觀念很重要喔，我會講很多次喔。

00:45:58 - 00:46:00
來各位啊，竊盜罪什麼時候既遂？

00:46:01 - 00:46:04
持有關係的改變，好嗎？

00:46:04 - 00:46:10
持有關係改變的瞬間，就是竊盜的既遂，OK哦？

00:46:10 - 00:46:15
持有關係改變的瞬間，就是竊盜的既遂。

00:46:17 - 00:46:18
所以持有關係什麼時候會改變？

00:46:19 - 00:46:21
當然跟物體的體積大小有關。

00:46:22 - 00:46:25
比如說我偷走同學的手機，你手機放桌上，那手機那麼小。

00:46:26 - 00:46:29
我把你的手機拿起來，拿到我手上的瞬間，

00:46:29 - 00:46:30
持有就改變了。

00:46:30 - 00:46:31
改變了。

00:46:31 - 00:46:33
瞭解吧，這時候持有就改變了，就既遂了。

00:46:34 - 00:46:35
竊盜什麼時候終了？

00:46:36 - 00:46:41
竊盜要等到行為人對這個財產建立穩固的持有，

00:46:42 - 00:46:43
這才終了喔。

00:46:43 - 00:46:44
知道嗎？持有要穩固。

00:46:44 - 00:46:50
所以你想那個畫面喔，下課的時候，我拿走同學放在桌上的手機。

00:46:51 - 00:46:56
我一拿走啊，同學發現了，同學超傻眼，什麼啊，來上課手機被老師偷。

00:46:56 - 00:46:57
同學追了出去。

00:46:58 - 00:46:59
同學一邊追，我在後面跑。

00:47:00 - 00:47:02
同學喝斥我：老師啊，快把手機放下。

00:47:02 - 00:47:04
這個過程，

00:47:04 - 00:47:05
竊盜終止了嗎？

00:47:05 - 00:47:06
還沒。

00:47:06 - 00:47:08
因為同學在後面追著我。

00:47:08 - 00:47:10
我對這個手機的持有還不穩固。

00:47:11 - 00:47:12
要什麼時候才穩固？

00:47:13 - 00:47:14
假設你們想喔。

00:47:15 - 00:47:16
我在跑，同學在追。

00:47:17 - 00:47:19
我跑投身地下去，

00:47:19 - 00:47:20
同學一起追不捨。

00:47:21 - 00:47:22
追著到了樓下的騎樓

00:47:23 - 00:47:26
我看到啊，快要變綠燈了。

00:47:26 - 00:47:29
剛好有一臺計程車停在那邊。

00:47:29 - 00:47:31
我趕緊打開計程車的門，跳了上去。

00:47:32 - 00:47:34
跳上去的瞬間，綠燈，計程車起步了。

00:47:35 - 00:47:37
那麼當我跳上計程車的瞬間，竊盜就終了。

00:47:38 - 00:47:39
因為車子開走了，

00:47:40 - 00:47:41
我對這個持有也穩固了，知道吧？

00:47:42 - 00:47:42
所以我們講喔，

00:47:44 - 00:47:46
正當防衛的最後時點是什麼時候？

00:47:47 - 00:47:49
行為終了前喔。

00:47:49 - 00:47:53
所以我拿著手機在前面跑，同學在後面追。

00:47:53 - 00:47:58
這個時候啊，同學或第三人，[redacted]　不可以幫我達成，進而奪回手機正當防衛？

00:47:58 - 00:47:59
可以。

00:47:59 - 00:47:59
終

00:48:00 - 00:48:01
兩千都可以,

00:48:01 - 00:48:01
知道嗎,

00:48:01 - 00:48:01
記得。

00:48:01 - 00:48:03
中兩千都可以哦。

00:48:04 - 00:48:07
好,所以這個是我們講現在跟過去的區分。

00:48:07 - 00:48:09
來，右邊這一題我們看一下。

00:48:36 - 00:48:36
你看喔，

00:48:36 - 00:48:37
好久以前的題目了，

00:48:37 - 00:48:39
101,2012，

00:48:39 - 00:48:42
13年前，歷史非常的悠久。

00:48:43 - 00:48:45
我一般會跟同學說,

00:48:45 - 00:48:47
我們寫題目,寫新不寫舊。

00:48:48 - 00:48:52
那種十幾年前以上的考題,絕大多數是喪失參考價值的,

00:48:52 - 00:48:53
不用去鑽研它,

00:48:53 - 00:48:54
知道嗎,

00:48:54 - 00:48:55
我們寫新不寫舊。

00:48:56 - 00:48:58
你在我的課本上會看到這種十幾年以上的題目，

00:48:59 - 00:49:40
我會留到現在，

00:49:41 - 00:49:42
不是我捨不得刪，

00:49:42 - 00:49:43
也不是我懶得刪。

00:49:43 - 00:49:45
而是它真的很經典很重要。

00:49:45 - 00:49:48
它的重要性沒有隨著時間的經過而消滅，

00:49:48 - 00:49:49
知道吧？

00:49:49 - 00:49:51
否則其他的題目，

00:49:51 - 00:49:52
十幾年前的題目，

00:49:52 - 00:49:53
我們沒有專業的意義。

00:49:54 - 00:49:55
真的記得這個原則，

00:49:55 - 00:49:56
寫新不寫舊。

00:49:57 - 00:49:57
換句話說，

00:49:57 - 00:50:00
如果你去買一本解題書，

00:50:00 - 00:50:01
2008年、2009年的時候啊

00:50:01 - 00:50:09
當時我在網路上看到有人在討論一個民國89年的司法考題。

00:50:10 - 00:50:12
在探討那個題目到底要怎麼去解。

00:50:13 - 00:50:14
當時我沒有特別去回應。

00:50:15 - 00:50:17
但當時我心想是這樣。

00:50:17 - 00:50:18
我想說奇怪。

00:50:19 - 00:50:21
我們為什麼要研究一個19年前的題目？

00:50:22 - 00:50:25
對啊，19年前，你去研究那麼久以前的題目幹什麼？

00:50:25 - 00:50:27
我們講一個很現實的問題。

00:50:28 - 00:50:32
19年前，當時出這個題目的老師

00:50:32 - 00:50:35
19年，現在是不是很可能已經退休了？

00:50:35 - 00:50:36
幾率很高，對吧？

00:50:37 - 00:50:45
再來，現在會出題的老師，19年前可能還在唸博士，甚至還是個大學生，也是有可能，對不對？

00:50:47 - 00:50:49
所以那種太久的題目真的沒有練習的意義。

00:50:49 - 00:50:55
所以如果你遇到一個什麼民國90幾年的題目，你覺得很難懂，就算了放它去啦。

00:50:55 - 00:50:57
那個沒有什麼參考價值的啊，知道吧？

00:50:57 - 00:50:58
寫新不寫舊啊。

00:50:58 - 00:51:00
所以你們下禮拜會拿到的題目呢

00:51:00 - 00:51:01
也是

00:51:01 - 00:51:04
我題目本選的題目就是以十年為限。

00:51:04 - 00:51:08
太多沒有意義，因為太多那本書會變得太厚，而且太久以前的題目

00:51:08 - 00:51:10
真的也沒有什麼價值，所以我從有確認

00:51:10 - 00:51:11
我就只放進十年的。

00:51:11 - 00:51:13
那我就說了，這一題1.1我會放到現在

00:51:13 - 00:51:15
因為這題很經典，這一題所涉及的事實

00:51:16 - 00:51:19
並沒有隨著時間的情況而消滅。

00:51:19 - 00:51:20
這一題的

00:51:20 - 00:51:22
內容有沒有感覺，你稍微瀏覽一下。

00:51:24 - 00:51:25
有沒有感覺

00:51:25 - 00:51:27
它所涉及的考點，其實就是前面的平地建國案啊。

00:51:28 - 00:51:29
就是啊

00:51:29 - 00:51:29
一模一樣啊。

00:51:30 - 00:51:30
我簡單說了

00:51:31 - 00:51:35
持槍的歹徒進入KTV，在找包廂。

00:51:37 - 00:51:38
他要去殺人

00:51:38 - 00:51:39
他在找包廂。

00:51:40 - 00:51:46
而KTV的服務生在歹徒還在走廊上找包廂的時候

00:51:47 - 00:51:49
就先發制人，把這個歹徒打倒在地。

00:51:50 - 00:51:51
簡單講這個的事實就這樣。

00:51:52 - 00:51:55
問說這個服務生有沒有機會主張正當防衛。

00:51:56 - 00:51:57
對，就在問這個東西。

00:51:57 - 00:52:00
問說這個服務生有沒有機會主張正當

00:52:00 - 00:52:00
防衛。

00:52:01 - 00:52:01
好。

00:52:03 - 00:52:05
各位，前面三說我們再跑一遍。

00:52:05 - 00:52:07
就是非常經典的題目，就類似這種平底鍋相關的題目，前面三說我們再跑一遍。

00:52:10 - 00:52:14
來，如果採左手標準說的話，可不可以正當防衛？

00:52:14 - 00:52:15
當然不可以啊。

00:52:16 - 00:52:18
還在找包廂，哪有左手。

00:52:18 - 00:52:19
對吧，當然不可以喔。

00:52:20 - 00:52:22
那如果採有效防衛說可不可以？

00:52:23 - 00:52:23
可以。

00:52:24 - 00:52:29
當然啊，對啊，可以啊，不然等他找到包廂再進去，人就被打死了，對不對？

00:52:29 - 00:52:31
那如果採預備最後階段說呢？

00:52:32 - 00:52:33
可不可以現在侵害？

00:52:33 - 00:52:34
也可以。

00:52:34 - 00:52:39
找包廂，確實是左手前，幾乎是最後的一步了。

00:52:39 - 00:52:40
應該也認為可以，知道嗎？

00:52:40 - 00:52:45
所以採預備最後階段來說呢，應該也會採認正當防衛的成立，應該也可以。

00:52:46 - 00:52:46
所以啊。

00:52:48 - 00:52:54
這個是左手標準，預備最後階段，還有有效防衛手段，在這個題目裡面當中具體的運用。

00:52:55 - 00:52:58
因為你要想一件事啦，KTV的門是不能鎖的。

00:52:59 - 00:53:00
一推就開了。

00:53:00 - 00:53:03
那如果包廂就在他的斜前方呢？

00:53:03 - 00:53:05
那是不是再過幾秒子彈就打下去了，對不對？

00:53:05 - 00:53:10
所以這一題當中,除非你採左手標準說,否則應該都可以正當防衛喔。

00:53:11 - 00:53:11
好。

00:53:11 - 00:53:13
接下來我們再往下看喔，完號二。

00:53:14 - 00:53:17
第二個前提叫做不法侵害。

00:53:17 - 00:53:19
我們講啊，第一個叫做現在侵害，侵害要具有現在性。

00:53:21 - 00:53:22
過去的將來的不算。

00:53:23 - 00:53:25
再來第二個叫做不法侵害，侵害要具有不法性。

00:53:27 - 00:53:31
反過來講的意思是，如果這個侵害是合法行為的話，那你要記得。

00:53:33 - 00:53:37
合法行為的相對人，富有忍受的義務，瞭解嗎？

00:53:37 - 00:53:40
合法行為的相對人富有忍受的義務喔，所以合法行為的相對人

00:53:42 - 00:53:46
不可以主張正當防衛，知道嗎？不可以主張正當防衛，哎呀很簡單嘛。

00:53:50 - 00:53:51
你涉嫌酒駕，警察逮捕你。

00:53:52 - 00:53:54
然後你揍警察還宣稱說你正當防衛。

00:53:54 - 00:53:55
這哪裡正當啊，知道吧？

00:53:55 - 00:53:58
所以合法行為的相對人呢，是不能正當防衛的。

00:53:58 - 00:53:59
好。

00:53:59 - 00:54:00
那我們就來看。

00:54:00 - 00:54:00
好，關於不法行為的認定。

00:54:02 - 00:54:04
首先第一個是形式不法。

00:54:05 - 00:54:07
這邊我們講通說的看法。

00:54:07 - 00:54:10
通說認為所謂的形式不法呢,

00:54:10 - 00:54:12
只要該當違法,

00:54:12 - 00:54:13
就夠了。

00:54:14 - 00:54:15
要不要具有罪責?

00:54:15 - 00:54:16
不用。

00:54:16 - 00:54:17
因為他是，他寫的是不法侵害，

00:54:18 - 00:54:20
他寫的並不是一個犯罪形態，

00:54:20 - 00:54:21
他寫不法侵害，

00:54:21 - 00:54:23
所以呢，從形式不法來講，

00:54:24 - 00:54:27
只要這個行為具有該當性、違法性，

00:54:27 - 00:54:27
就夠了。

00:54:28 - 00:54:30
有沒有罪責，不重要。

00:54:30 - 00:54:34
至於啊，對無罪責的人可不可以正當防衛？

00:54:34 - 00:54:37
通說的說法是可以，可以，但防衛權會被限制，這個我們下回再說。

00:54:40 - 00:54:42
好，接下來我們翻過來146頁。

00:54:44 - 00:54:47
第二個問題，那對民事不法，可不可以正當防衛？

00:54:49 - 00:54:50
我們講的是純民事不法喔。

00:54:51 - 00:54:54
對於純民事不法，可不可以正當防衛？

00:54:55 - 00:55:00
比如說如果有一天我在教修室遇到，比如說遇到陸伯言，

00:55:00 - 00:55:07
陸伯言看到我之後啊，他就把那個教修室的門關起來，然後在耳邊用氣罵我五字經。

00:55:08 - 00:55:10
那我聽得很不爽，揍他一拳，

00:55:10 - 00:55:12
造成他的光頭瘀青。

00:55:12 - 00:55:14
這樣的情況，我可不可以主張正當防衛？

00:55:15 - 00:55:17
對於純民事不法。

00:55:17 - 00:55:19
純民事不法。

00:55:19 - 00:55:20
還有還有什麼是純民事不法？

00:55:22 - 00:55:24
用肉眼偷窺別人的隱私。

00:55:25 - 00:55:27
因為法律上是這樣,

00:55:27 - 00:55:30
你偷看別人的隱私，要315之一,

00:55:30 - 00:55:32
你要用工具設備。

00:55:33 - 00:55:34
純肉眼不算啊,

00:55:35 - 00:55:35
所以你想嘛,

00:55:36 - 00:55:38
我在廁所尿尿的時候,

00:55:38 - 00:55:40
如果陸伯言在我旁邊尿,

00:55:40 - 00:55:41
然後他一直這樣,

00:55:41 - 00:55:42
我小一就這樣，一直在那邊看。

00:55:43 - 00:55:44
看什麼看啊，揍他一拳。

00:55:46 - 00:55:47
這樣的話，可不可以正當防衛？

00:55:48 - 00:55:49
一樣的問題，這樣可不可以正當防衛？

00:55:49 - 00:55:50
純民事不法。

00:55:51 - 00:55:52
多數說認為可以。

00:55:53 - 00:55:54
多數說認為可以，為什麼？

00:55:55 - 00:55:56
法秩序的一體性。

00:55:57 - 00:55:57
對啊，這是什麼意思？

00:56:00 - 00:56:02
我們都學過民法。

00:56:03 - 00:56:04
從民法的角度來講，

00:56:06 - 00:56:06
你想喔，

00:56:07 - 00:56:12
路博言一直用肉眼偷看我尿尿，我不爽，我揍他一拳，造成他臉頰瘀青。

00:56:13 - 00:56:17
在民法上，我要不要對他負侵權行為的損害賠償責任？

00:56:17 - 00:56:19
不用，為什麼？因為民法也有正當防衛。

00:56:20 - 00:56:20
對吧？

00:56:21 - 00:56:23
民法那個150幾條嘛，148、149還是150？對不對？

00:56:24 - 00:56:25
民法也有正當防衛。

00:56:25 - 00:56:28
對啊，所以這樣的案例在民法上可以用正當防衛阻卻違法。

00:56:29 - 00:56:30
那到刑法上呢？

00:56:31 - 00:56:33
如果到刑法上你卻跟我說,

00:56:33 - 00:56:36
哎,很抱歉哦,純民事不法,不準正當防衛,

00:56:37 - 00:56:38
你還是成立傷害罪。

00:56:38 - 00:56:40
有沒有感覺法秩序超矛盾?

00:56:41 - 00:56:44
民法上這個是合法行為,不負損害賠償責任哦,而怎麼到刑法上變犯罪?

00:56:45 - 00:56:49
所以多數說在這裡認為，基於法秩序的一體性，

00:56:50 - 00:56:54
民事不法、刑事不法，一樣是正當防衛的對象，這多數說。

00:56:55 - 00:56:57
好，那少數說的話，

00:56:58 - 00:57:01
也有人認為說啊，民事不法不行，為什麼呢？

00:57:01 - 00:57:03
因為也有人會說，

00:57:03 - 00:57:07
假設民事不法可以正當防衛的話，

00:57:08 - 00:57:12
那會造成一個結果，叫做刑法侵犯到其他的法領域。

00:57:12 - 00:57:13
什麼意思呢？

00:57:13 - 00:57:16
你們想喔，剛剛那個路博彥的案例，

00:57:17 - 00:57:20
如果啊，路博彥去告我傷害，

00:57:21 - 00:57:25
那這個傷害案件,是不是會有地方法院的刑事庭來審理?

00:57:25 - 00:57:26
對嘛,一定是嘛。

00:57:27 - 00:57:28
那在這個刑事庭當中,我是被告,

00:57:29 - 00:57:32
我跟法官說,法官啊,我要主張正當防衛。

00:57:33 - 00:57:36
如果法官要審酌我的正當防衛成不成立的話,

00:57:36 - 00:57:38
那法官這個刑事庭的法官,

00:57:38 - 00:57:41
是不是要偷偷判斷這裡在民法上有沒有構成侵權行為?

00:57:42 - 00:57:48
所以等於就是,刑事庭在審查正當防衛的時候,要去偷偷判斷這裡的民事侵權行為存不存在。

00:57:49 - 00:57:53
所以這裡就會說,什麼叫刑法侵犯到其他法領域,就是指這種狀況,懂嗎?

00:57:53 - 00:57:57
所以有人說,我們這裡的不法,專指刑事不法而言,

00:57:57 - 00:58:00
刑事不算,但這個少數說,多數說。

00:58:00 - 00:58:00
都認為

00:58:02 - 00:58:05
刑事不法跟民事不法都算,民事不法也算

00:58:05 - 00:58:09
所以那個純民事不法還有一個更常見的例子了,使用竊盜

00:58:10 - 00:58:12
偷騎別人的腳踏車

00:58:13 - 00:58:17
聽說這個在很多大學校園裡面都會遇到，偷騎別人的腳踏車

00:58:17 - 00:58:21
這一段我無從體會，我覺得很遺憾，無從體會

00:58:21 - 00:58:25
我大一念文化，文化在陽明山上怎麼騎腳踏車

00:58:26 - 00:58:31
大二之後我念東吳，東吳城中校區，那麼小

00:58:31 - 00:58:33
有什麼好騎腳踏車的

00:58:33 - 00:58:33
所以我一直沒有體會到這一段

00:58:33 - 00:58:38
我每次去一些比較大的學校,比如說我每次去中正大學,我就想說這才是大學吧

00:58:38 - 00:58:40
那麼大,還有臺大也是啊,對啊

00:58:40 - 00:58:44
這時候我才覺得說,這才是大學,才有這種騎腳踏車的經驗

00:58:44 - 00:58:49
9月份我臺北大博士班開學,臺北大會不會騎腳踏車啊,我不知道

00:58:49 - 00:58:52
到時候再去體驗看看，在大學裡面騎腳踏車

00:58:52 - 00:58:55
這個人生一直沒有這一段體驗，感覺蠻遺憾的

00:58:57 - 00:58:58
好，所以這個是我們講

00:58:58 - 00:59:00
肯定說，還有否定說

00:59:00 - 00:59:01
接下來第二點

00:59:02 - 00:59:03
第二點

00:59:03 - 00:59:04
我們講不法形態

00:59:06 - 00:59:06
不法形態

00:59:07 - 00:59:10
人類的行為才有不法形態

00:59:10 - 00:59:15
純粹的動物的行為，純粹的自然力

00:59:15 - 00:59:17
那不會有不法的問題

00:59:18 - 00:59:19
對啊，當然不會啊，什麼意思

00:59:22 - 00:59:23
野狗偷喝你的汽油

00:59:24 - 00:59:27
你說狗喝你的汽油，那隻狗有不法行為

00:59:27 - 00:59:28
聽起來超怪，對吧

00:59:30 - 00:59:31
流浪狗咬你

00:59:31 - 00:59:33
你說那個狗的行為具有不法性

00:59:34 - 00:59:37
不會吧，那狗又不會判斷是非，那個怎麼有不法可言，對不對

00:59:37 - 00:59:40
所以只有人的行為呢，才有不法可言

00:59:40 - 00:59:45
所以我們說啊，針對純粹的動物攻擊，純粹的自然力

00:59:45 - 00:59:47
不會有正當防衛的空間

00:59:48 - 00:59:49
可是

00:59:49 - 00:59:50
我也跟各位講喔

00:59:50 - 00:59:53
並不是說對動物的攻擊永遠不能正當防衛喔

00:59:53 - 00:59:56
如果動物的攻擊背後有人為故意或過失的話

00:59:57 - 00:59:58
可不可以正當防衛？

00:59:58 - 00:59:59
當然可以啊。

00:59:59 - 01:00:00
所以比如說我跟各位

01:00:00 - 01:00:00
會講過。

01:00:00 - 01:00:02
我朋友有一隻狗，美國惡霸犬，牠的名字叫尼哥。

01:00:04 - 01:00:05
我是不是講過這件事？

01:00:05 - 01:00:06
有嗎，那個

01:00:08 - 01:00:09
長得非常可愛。

01:00:09 - 01:00:09
呃

01:00:11 - 01:00:13
我牽著這一隻在路上。

01:00:13 - 01:00:17
牠是一隻很兇猛的狗，因為牠有二分之一比特犬的血統。

01:00:17 - 01:00:20
如果我牽著這隻狗在路上，看到我的仇人出現。

01:00:21 - 01:00:25
我馬上把狗丟下去放開，還講了一句話：「你過去咬他。」

01:00:26 - 01:00:28
這時候對方可不可以反擊把這隻狗打死？

01:00:28 - 01:00:30
當然可以啊，因為那是什麼？

01:00:30 - 01:00:32
我的故意行為的延伸嘛，對不對？

01:00:32 - 01:00:33
所以這種情況可以當防衛。

01:00:33 - 01:00:36
還有，如果我溜狗根本沒有繫狗鍊呢？

01:00:37 - 01:00:38
結果這個狗去咬人了。

01:00:38 - 01:00:40
對方可不可以反擊請求正當防衛？

01:00:40 - 01:00:43
可以啊，六哥氣不氣？狗鍊是我的過失啊。

01:00:43 - 01:00:44
當然可以當防衛，知道嗎？

01:00:45 - 01:00:49
所以動物的攻擊如果背後有人為的故意過失的話，當然有正當防衛的空間。

01:00:50 - 01:00:53
好，最後啊，第三點，侵害是否存在。

01:00:54 - 01:00:58
理論上來說會有兩個判斷的標準，當下或事後。

01:00:58 - 01:00:59
你看這個例子。

01:01:00 - 01:01:00
詼

01:01:00 - 01:01:04
持槍搶銀行，用槍抵著行員的頭部。

01:01:05 - 01:01:10
這個時候呢，建議有為的B啊，持刀刺向A的背部，造成A一時過度死亡。

01:01:10 - 01:01:13
事後才知道，原來這個是防搶演練。

01:01:13 - 01:01:16
為了求逼真呢,所以沒有告知顧客,導致這樣的悲劇發生。

01:01:17 - 01:01:17
各位

01:01:18 - 01:01:20
這個案例是正當防衛還是誤想防衛？

01:01:22 - 01:01:23
不一定。

01:01:23 - 01:01:24
看你從哪個視角，對不對？

01:01:26 - 01:01:27
你從當下的視角來判斷。

01:01:28 - 01:01:30
誰知道啊，看起來就是搶銀行照。

01:01:30 - 01:01:30
啊？

01:01:30 - 01:01:32
所以當下的視角那個叫正當防衛。

01:01:33 - 01:01:34
但如果你從事後的視角呢？

01:01:35 - 01:01:36
誤傷，對不對？

01:01:36 - 01:01:37
因為他就不是侵害嘛，看你從哪個視角。

01:01:38 - 01:01:41
這個東西國內學說只有點到為止，我們就不深究了，你只要知道說有兩個視角，會有不同的結論就OK。

01:01:45 - 01:01:47
好，那我們就先在這裡中場休息一下。

01:01:47 - 01:01:49
等一下呢，我們再來看後面的這些要件。

01:01:55 - 01:01:59
好,接下來147頁這邊,我們來看括號三。

01:02:00 - 01:02:00
括號三,第三個前提是,要有權利被侵害,我們講現在不法侵害。

01:02:05 - 01:02:07
第三個是要有權利被侵害。

01:02:08 - 01:02:09
第一個來,第一點這邊。

01:02:10 - 01:02:17
這裡我們講到,這個侵害行為必須要有一定的威脅性存在。

01:02:17 - 01:02:21
那如果這個侵害行為根本自始至終不存在任何的威脅性的話。

01:02:22 - 01:02:25
這邊有一個專有名詞叫做假侵害，這個是許澤天老師的書上有提到的，這個叫做假侵害。

01:02:29 - 01:02:33
最典型的假侵害是什麼呢？不能未遂，就是不能未遂。

01:02:34 - 01:02:36
不能未遂在26條啦。

01:02:36 - 01:02:37
就是說吼。

01:02:38 - 01:02:47
如果有人想透過一個顯然客觀上不可能實現犯罪的手法來實現犯罪，這個叫做不能未遂。

01:02:48 - 01:02:53
如果是一個不能未遂的行為的話，他就是我們所說的假想侵害。

01:02:54 - 01:02:58
而假想侵害的話呢，不是正當防衛的對象。

01:02:58 - 01:03:00
假想侵害這個東西，他不是正當防衛的對象。

01:03:01 - 01:03:09
所以呢，這個東西，他並不是，他這個東西吼，就不是我們講防衛的前提，如果有人把它當作真的侵害呢，他會構成誤想防衛。

01:03:13 - 01:03:15
我講一個多年前考過的題目。

01:03:15 - 01:03:17
這個沒有題目有點麻煩，但沒關係，那個題目我腦中都記得。

01:03:20 - 01:03:21
這題目是這樣吼。

01:03:22 - 01:03:22
啊

01:03:23 - 01:03:24
我講它部分敘述的紀錄。

01:03:25 - 01:03:26
這一題我沒有記錯的話，應該是109年調工組那一題吼。

01:03:30 - 01:03:36
應該是，我記得應該是109年啦，就是109年那個行政執行官跟調查局調工組那一份，應該是那一份。

01:03:36 - 01:03:38
題目的事實是這樣。

01:03:38 - 01:03:38
有個人啊。

01:03:39 - 01:03:40
要去暴力討債。

01:03:41 - 01:03:43
這個人怎麼暴力討債呢？拿水槍。

01:03:44 - 01:03:45
水槍吼，小朋友玩的彩色的會噴水那一種。

01:03:47 - 01:03:50
他拿那個水槍要去別人家暴力討債。

01:03:50 - 01:03:55
而被害人的太太情急之下沒有發現那個是水槍，還以為那是真槍。

01:03:58 - 01:03:59
就把那個傢伙給捅死了。

01:04:00 - 01:04:00
事實大概是這樣。

01:04:01 - 01:04:03
對啊,拿那個小朋友的水槍去討債,被誤以為是真槍。

01:04:05 - 01:04:07
然後那個討債的傢伙就被捅死了。

01:04:07 - 01:04:10
最賤是什麼?

01:04:10 - 01:04:10
這就誤想防衛,知道嗎?

01:04:10 - 01:04:13
因為水槍根本不構成侵害啊。

01:04:14 - 01:04:19
那水槍拿去打人搞不好還打沒辦法打得怎麼樣,那水槍打下去搞不好水槍會破掉,對不對?

01:04:21 - 01:04:26
對啊,所以這樣的案例當中,客觀上根本不構成一個侵害。

01:04:26 - 01:04:32
這就是我們所謂的假侵害,可是相對人情急之下以為那是真的侵害。

01:04:32 - 01:04:33
這個就變誤想防衛,OK嗎?

01:04:33 - 01:04:34
這以前考試有考過哈。

01:04:35 - 01:04:37
那個刁公主那一份的刑法,經常考很難。

01:04:39 - 01:04:43
好,接下來,王老師的第二點這邊。

01:04:43 - 01:04:46
我們講,假侵害不算,還有什麼不算呢?

01:04:47 - 01:04:50
純粹的國家社會法益的犯罪。

01:04:50 - 01:04:51
這也不算。

01:04:52 - 01:04:54
純粹的國家社會法益的犯罪。

01:04:55 - 01:04:58
這也不算是正當防衛的對象。

01:05:00 - 01:05:00
我們記得哈。

01:05:00 - 01:05:02
只有個人法益受害。

01:05:03 - 01:05:06
或者是這個犯罪找得到具體被害人的時候。

01:05:07 - 01:05:09
這時候才有正當防衛的空間。

01:05:10 - 01:05:14
如果一個人所實施的違法行為，純粹侵害的是國家社會利益的話。

01:05:15 - 01:05:17
這時候沒有正當防衛的空間。

01:05:17 - 01:05:19
我想林山田老師講得很對。

01:05:19 - 01:05:21
因為林老師說呢。

01:05:21 - 01:05:24
維護國家社會的秩序，那是警察的任務。

01:05:25 - 01:05:28
如果一般的平民也覺得自己想當警察，大家都想挺身

01:05:29 - 01:05:31
出來維護社會秩序的話，

01:05:32 - 01:05:33
那社會只會更亂。

01:05:33 - 01:05:33
不會比較好，知道嗎？

01:05:35 - 01:05:35
所以呢。

01:05:36 - 01:05:36
國家社會法益的犯罪。

01:05:38 - 01:05:40
不是正當防衛的對象喔。

01:05:41 - 01:05:42
因此喔，如果你在路上看到有人在露鳥。

01:05:44 - 01:05:47
你可以怎麼做？踹他的懶叫逼他收起來。

01:05:48 - 01:05:50
那你報警就好了啦。

01:05:50 - 01:05:50
你不用做這種事，知道嗎？

01:05:51 - 01:05:52
我們報警就好啦。

01:05:53 - 01:05:56
同樣的，如果你是個這種護家盟的衛道人士。

01:05:57 - 01:05:59
你看到路邊有人在擺攤賣A片。

01:06:00 - 01:06:00
你是衛道人士，你看到覺得很生氣啊。

01:06:02 - 01:06:03
你可以怎麼做？

01:06:04 - 01:06:05
就報警抓他就好了啊。

01:06:06 - 01:06:07
你沒有必要拿刀捅死他，知道吧？

01:06:07 - 01:06:09
所以這個是

01:06:09 - 01:06:12
我本講關於不法侵害，這個侵害行為呢，必須要是一個個人法益的犯罪。

01:06:15 - 01:06:16
接下來，第三點。

01:06:18 - 01:06:21
正當防衛，可以為第三人為之。

01:06:23 - 01:06:24
可以為第三人為之喔。

01:06:24 - 01:06:30
當你看到有個流浪漢被欺負，而那個流浪漢不敢吭聲的時候，你可以挺身而出。

01:06:30 - 01:06:31
為那個流浪漢防衛。

01:06:31 - 01:06:32
這是可以的喔。

01:06:32 - 01:06:35
正當防衛，確實可以為第三人為之。

01:06:35 - 01:06:37
只是我們這邊強調。

01:06:38 - 01:06:41
為第三人正當防衛有一個最低限度。

01:06:41 - 01:06:44
就是這個第三人不能明確的反對。

01:06:45 - 01:06:52
也就是說，當你看到有屁孩在欺負流浪漢的時候，你原則上可以為這個流浪漢反擊，沒有錯。

01:06:53 - 01:06:56
可是如果流浪漢講了一句話，說你不要管我，

01:06:57 - 01:06:59
這是我跟他們私人的事。

01:06:59 - 01:06:59
不干你的事。

01:06:59 - 01:07:00
你不要管我。

01:07:00 - 01:07:02
這時候你的防衛權就不見了，懂嗎？

01:07:02 - 01:07:08
所以為第三人侵害的時候，為第三人防衛的時候，最低限度是第三人不能為反對的意思。

01:07:09 - 01:07:12
我跟你們說啊，這種為第三人的正當防衛。

01:07:13 - 01:07:15
他有一個專有名詞叫緊急救助。

01:07:16 - 01:07:18
他有一個新的名詞叫緊急救助。

01:07:18 - 01:07:21
這個是臺大周揚儀老師最近的文章。

01:07:21 - 01:07:22
發表了沒有，我不確定。

01:07:22 - 01:07:24
但今年三月我有去聽研討會，周揚儀老師在那個研討會裡面發表了一篇文章叫做緊急救助。

01:07:29 - 01:07:30
就在講

01:07:30 - 01:07:32
這一種對第三人的正當防衛。

01:07:32 - 01:07:33
所以這個東西

01:07:33 - 01:07:35
如果你看到名詞叫做緊急救助,翟澤天老師

01:07:37 - 01:07:39
好像翻譯成有點忘記叫什麼,但也是類似的名詞啊。

01:07:41 - 01:07:44
就是在指這一種為第三人的正當防衛。

01:07:46 - 01:07:47
好。

01:07:47 - 01:07:48
接下來

01:07:48 - 01:07:49
我們來看到光號是防衛行為。（應為：我們來看到，關於防衛行為。）

01:07:51 - 01:07:52
好。

01:07:52 - 01:07:53
防衛行為這個東西啊

01:07:53 - 01:07:56
就是我們剛剛講違法性的第二格。

01:07:56 - 01:07:57
第一個我們講完了。

01:07:58 - 01:07:59
防衛情狀是

01:08:00 - 01:08:01
是我們講完的喔。

01:08:01 - 01:08:04
接著第二個叫做防衛行為。

01:08:04 - 01:08:07
防衛行為就是手段適當的部分啊。

01:08:08 - 01:08:10
手段適當我們主要看兩個東西。

01:08:10 - 01:08:15
第一個是，防衛行為要符合適當性跟必要性。

01:08:17 - 01:08:18
適當加必要。

01:08:18 - 01:08:21
適當指的是說這個防衛行為要有效。

01:08:21 - 01:08:28
必要的意思是，這個防衛行為要是所有有效手段當中，損害最小的。

01:08:29 - 01:08:30
適當加必要。

01:08:31 - 01:08:32
欸，沒有衡量喔。

01:08:33 - 01:08:36
你不要比例原則講得很順，適當必要衡量我知道。

01:08:36 - 01:08:37
沒有，沒有衡平。

01:08:37 - 01:08:38
只有適當加必要。

01:08:39 - 01:08:42
所以你在寫考題的時候，

01:08:43 - 01:08:47
你不能說正當防衛的防衛手段的判斷就是比例原則，

01:08:47 - 01:08:50
不對，因為比例原則是適當必要且衡平。

01:08:50 - 01:08:53
但正當防衛不做衡量性的判斷,

01:08:53 - 01:08:55
它只判斷適當且必要。

01:08:56 - 01:08:57
為什麼我等一下會說。

01:08:57 - 01:08:58
第一個來，適當性喔。

01:08:59 - 01:09:01
適當性指的是這個防衛行為要有效。

01:09:02 - 01:09:05
它是一個要有效可以擊退侵害的手段。

01:09:06 - 01:09:12
所以如果防衛者選擇一個無效的手段來防衛的話，那他就不符合適當性的要求。

01:09:13 - 01:09:14
有效的手段。

01:09:15 - 01:09:16
各位啊，有效是什麼意思？

01:09:18 - 01:09:19
所謂的有效，

01:09:20 - 01:09:23
沒有說要真的成功擊退侵害。

01:09:23 - 01:09:24
沒有，沒那麼嚴格喔。

01:09:25 - 01:09:27
不用到真的成功擊退侵害。

01:09:28 - 01:09:31
所以各位，防衛失敗可不可以認正當防衛？

01:09:31 - 01:09:32
可以喔。

01:09:32 - 01:09:34
路伯言要對我強制猥褻，

01:09:35 - 01:09:36
我要試圖痛打他一頓，

01:09:36 - 01:09:41
過程當中我造成路伯言的手部受傷，可是最後我還是被猥褻了，

01:09:41 - 01:09:42
這樣我可不可以算正當防衛？

01:09:42 - 01:09:43
可以喔。

01:09:43 - 01:09:45
防衛失敗是可以認定正當防衛的喔，知道吧？

01:09:46 - 01:09:48
所以我們講的有效，是指什麼？

01:09:49 - 01:09:53
一般客觀上來講，有可能可以把侵害消滅掉，

01:09:54 - 01:09:54
這就是有效，

01:09:54 - 01:09:55
知道嗎？

01:09:55 - 01:09:56
有可能可以把侵害消滅掉,

01:09:56 - 01:09:57
這就是有效。

01:09:58 - 01:10:00
不需要這個行為實際上真的

01:10:00 - 01:10:04
的小米的侵害,不用,有可能,這就是符合有效的要件的。

01:10:04 - 01:10:05
好,那除此之外啊。

01:10:08 - 01:10:09
除此之外吼，我們講這個有效。

01:10:11 - 01:10:12
所以反過來講什麼是無效的手段。

01:10:13 - 01:10:14
什麼叫無效手段，很多啊。

01:10:16 - 01:10:19
比如說，有人在你的私人土地上面停車。

01:10:19 - 01:10:23
他沒有經過你的同意，他沒有經過你的同意停在你的私人土地上。

01:10:24 - 01:10:25
而你的做法是，拿尖銳的東西。

01:10:26 - 01:10:29
把它四顆輪胎全部刺破。

01:10:30 - 01:10:32
這就叫無效的防衛手段。

01:10:32 - 01:10:33
可以理解嗎？

01:10:33 - 01:10:36
他在你的土地上停車，結果你把人家輪胎全部都刺破。

01:10:36 - 01:10:38
輪胎刺破他想開反而開不走。

01:10:39 - 01:10:40
這反而延展了侵害。

01:10:40 - 01:10:41
這個不叫防衛啦。

01:10:41 - 01:10:42
這個叫報復。

01:10:42 - 01:10:45
所以這種情況的話，就不能主張正當防衛，這個會變防衛過當。

01:10:47 - 01:10:49
好，除此之外，第一個我們講適當性嘛。

01:10:50 - 01:10:52
再來第二個叫做必要性。

01:10:54 - 01:10:55
第二個叫必要性。

01:10:56 - 01:10:57
必要性是什麼意思？

01:10:59 - 01:11:04
所有有效的防衛手段當中，損害最小的，這個叫必要性，知道嗎？

01:11:06 - 01:11:11
所有有效的防禦手段當中,損害要是最小的喔。

01:11:12 - 01:11:13
聽清楚啊。

01:11:13 - 01:11:15
不是純粹的損害最小喔。

01:11:15 - 01:11:20
因為你講純粹損害最小的話,那就逃跑不要防衛啊,那就報警不就好了。

01:11:20 - 01:11:22
那個不是我們的考慮選項,知道嗎?

01:11:22 - 01:11:29
我講的正當防衛，他就是賦予人民在被歹徒侵害的時候，有權力直接反擊。

01:11:29 - 01:11:30
逃跑報警。

01:11:30 - 01:11:32
那不是要考慮的對象，OK，他不叫考慮的對象喔。

01:11:34 - 01:11:35
所以我們講什麼叫做什麼叫必要性？

01:11:38 - 01:11:43
所有有效的手段當中，損害最小的。

01:11:44 - 01:11:44
所以舉例來說是這樣。

01:11:45 - 01:11:46
這個其實很取決於個案啊。

01:11:47 - 01:11:49
我舉一個比較極端好判斷的案例。

01:11:49 - 01:11:55
有個80歲的老人，拄著枴杖，有氣無力地說我想打死你。

01:11:55 - 01:11:56
這時候你可以怎麼做啊？

01:11:58 - 01:11:58
踹倒他。

01:11:59 - 01:11:59
OK。

01:12:00 - 01:12:00
可以。

01:12:01 - 01:12:02
拿刀捅他肚子，不可以，

01:12:03 - 01:12:04
過當了，大概是這個意思。

01:12:04 - 01:12:07
好吧，同等有效的手段當中，損害最小的。

01:12:07 - 01:12:10
當然這件事，我們通常還要參酌什麼呢？

01:12:10 - 01:12:15
雙方的年齡、性別、體力、彼此有沒有武器等等，

01:12:15 - 01:12:16
那個都是我們要考量的對象，

01:12:16 - 01:12:18
所以我說這個東西很取決於個案的判斷。

01:12:20 - 01:12:24
接著我們說，正當防衛不考慮衡平性。

01:12:25 - 01:12:26
記得喔，不考慮衡平性喔。

01:12:27 - 01:12:34
所以如果你為了保全很微小的利益，而犧牲對方很大的利益，

01:12:35 - 01:12:37
比如說，你的手機被偷了，

01:12:38 - 01:12:39
你為了奪回手機，

01:12:40 - 01:12:41
你把小偷絆倒,

01:12:42 - 01:12:46
小偷被絆倒之後啊，頭撞到牆壁上的尖銳物，

01:12:47 - 01:12:49
小偷的頭後來送醫縫了好幾針，

01:12:50 - 01:12:51
這種情況你可以正當防衛？

01:12:52 - 01:12:52
可以喔。

01:12:53 - 01:12:54
正當防衛是不看法律衡平性的喔,

01:12:55 - 01:12:59
所以你為了奪回財產,而讓小偷受傷,OK,完全可以喔,

01:12:59 - 01:13:11
所以記得,

01:13:11 - 01:13:42
正當防衛沒有衡平性的要件。

01:13:44 - 01:13:46
好,下面這一題,我們來看一下,

01:13:47 - 01:13:51
下面這個題目啊,我覺得設計的很好,它是一個正當防衛非常典型的考題。

01:13:53 - 01:13:56
好,這一題當中,我們要分成兩個部分去看,

01:13:57 - 01:13:59
第一個是把乙撲倒,

01:13:59 - 01:13:59
所以各位,

01:14:00 - 01:14:00
你在寫這題的時候,你下標要分兩個標。

01:14:00 - 01:14:00
第一個是甲把乙撲倒。

01:14:06 - 01:14:11
第二個是什麼呢，假如有人打斷你的手臂。

01:14:11 - 01:14:13
那是兩個明顯可分的行為，知道嗎？

01:14:13 - 01:14:14
第一個是把人撲倒。

01:14:15 - 01:14:16
第二個呢，是把人家的手臂打斷，右邊這邊有寫。

01:14:18 - 01:14:21
來，撲倒的部分，可不可以做到正當防衛？

01:14:22 - 01:14:23
那所以我們來想喔。

01:14:24 - 01:14:25
那個人偷了他的錢包。

01:14:26 - 01:14:27
錢包很小，所以錢包是不是拿起來之後持有關係就改變了？

01:14:30 - 01:14:30
變了。

01:14:31 - 01:14:31
對啊，沒有錯啊。

01:14:32 - 01:14:33
拿起來持有關係都改變了，所以確實竊盜已經既遂了。

01:14:35 - 01:14:36
可是我們講了。

01:14:37 - 01:14:41
正當防衛的最後時點，不是犯罪的既遂，而是犯罪的終了。

01:14:44 - 01:14:50
很顯然的，這個小偷對皮包的持有，雖然改變了沒有錯，可是這個持有穩固嗎？

01:14:50 - 01:14:50
沒有，對不對？

01:14:50 - 01:14:52
他持有皮包穩固,所以這題當中,確實,在前端的部分,可以認為是對於現在侵害的防衛。

01:14:59 - 01:14:59
OK,這個沒有問題哦。

01:15:00 - 01:15:00
來,那後面。

01:15:02 - 01:15:04
他把乙打傷的部分了。

01:15:06 - 01:15:07
他把乙打傷。

01:15:08 - 01:15:08
那我們會說了。

01:15:09 - 01:15:11
這裡確實一樣，它是一個現在侵害。

01:15:11 - 01:15:14
因為這個小偷就一直握著這個皮包不願意返還嘛，所以這裡確實有一個現在侵害沒有錯。

01:15:17 - 01:15:19
這裡可不可以認為是防衛過當啊？

01:15:19 - 01:15:21
對了，這邊補一個點，構成要件的部分。

01:15:22 - 01:15:24
把人家打到骨折有沒有算重傷？

01:15:24 - 01:15:25
沒有喔，這考過超多次喔。

01:15:26 - 01:15:28
骨折原則上不會是重傷啦。

01:15:28 - 01:15:34
因為我們講重傷要毀敗或嚴重減損或其他的重大不治難治的傷害。

01:15:34 - 01:15:37
骨折打石膏接得回去。

01:15:37 - 01:15:39
那個並不是一個不可逆的傷害，知道嗎？

01:15:39 - 01:15:40
所以骨折不算重傷喔。

01:15:41 - 01:15:42
那這一題我們回來講。

01:15:42 - 01:15:45
正當防衛來說，這裡是不是一個有效的防衛手段？

01:15:46 - 01:15:48
這裡是不是一個最小侵害的手段？

01:15:48 - 01:15:49
我會覺得是啦。

01:15:49 - 01:15:56
因為在這個題目當中,除了打對方的手臂之外,還有什麼溫和而更有效的防衛手段嗎?

01:15:57 - 01:15:58
我恐怕是想不到。

01:15:58 - 01:15:59
我恐怕想不到,所以這題

01:16:00 - 01:16:05
當中呢，我會覺得前段還有後端的部分，都有機會主張正當防衛。

01:16:06 - 01:16:07
前段涉及什麼問題？

01:16:09 - 01:16:11
防衛的時間，這個侵害還不具有現在性。

01:16:12 - 01:16:13
後段涉及什麼問題呢？

01:16:13 - 01:16:15
防衛手段的強度，有沒有過當。

01:16:15 - 01:16:18
所以這個題，我覺得這個題目設計得還不錯。

01:16:19 - 01:16:22
防衛的前提還有防衛的手段都考得出來。

01:16:23 - 01:16:24
好，接著來第二大點。

01:16:25 - 01:16:26
可不可以濫用防衛權？

01:16:26 - 01:16:32
括號有寫，這個東西又叫做正當防衛的社會倫理限制。

01:16:33 - 01:16:36
這個東西是從德國法那邊來的啦。

01:16:36 - 01:16:38
這個是德國通說有承認的。

01:16:38 - 01:16:42
所以這一段的內容，你在劉日老師的教授文章裡面應該不會看到。

01:16:42 - 01:16:44
因為這個是很德國的東西。

01:16:44 - 01:16:46
正當防衛的社會倫理限制。

01:16:47 - 01:16:50
他又叫做權力濫用禁止原則。

01:16:51 - 01:16:53
其實權力濫用這個東西，它是從民法來的啦。

01:16:55 - 01:16:56
我們講民法上的權用什麼意思？

01:16:57 - 01:16:58
就是說，權利人有這個權利。

01:16:59 - 01:17:02
權利人行使這個權利，他也沒有違反法律的規定。

01:17:03 - 01:17:08
可是我們從社會道德的觀點來講，總覺得這樣行使權力好像哪裡怪怪的。

01:17:08 - 01:17:09
那個叫權力濫用，知道嗎？

01:17:09 - 01:17:12
所以它是有一個道德評價在內。

01:17:12 - 01:17:14
他是有權力，對，有權力沒有錯。

01:17:14 - 01:17:17
只是我們總覺得這樣行使權力真的好嗎？

01:17:17 - 01:17:18
會不會有點奇怪？

01:17:19 - 01:17:23
像比如說我記得以前我在學那個民法學相鄰關係的時候。

01:17:24 - 01:17:28
相鄰關係裡面有一些條文，其實就是從權力禁止原則來的。

01:17:29 - 01:17:30
比如說那個

01:17:30 - 01:17:33
越界建築，如果只越界一點點。

01:17:33 - 01:17:35
你不能叫人家把它拆掉，民法請求權在這個附近。

01:17:35 - 01:17:36
對啊,那個就跟權力用盡有關啊。

01:17:37 - 01:17:40
還有在民法上我們學過一個概念叫權利失效。

01:17:41 - 01:17:43
我還記得這個,權利失效。

01:17:43 - 01:17:45
權利失效,他也跟權力濫用的性質有關。

01:17:46 - 01:17:51
有權力,但如果對方做出一個外觀,讓人相信他不再行使權力的話。

01:17:52 - 01:17:53
那可能會產生權力失靈的問題。

01:17:53 - 01:17:56
這個是我們在民法上所學的啦。

01:17:56 - 01:18:00
在刑法當中，有學者普遍認為。

01:18:00 - 01:18:02
為刑法的正當防衛的判斷，也要考慮到權力濫用進取的問題。

01:18:08 - 01:18:10
我這邊先講一件進階的事。

01:18:10 - 01:18:12
這個很法理啦，這個很學理。

01:18:12 - 01:18:13
各位啊，你們想一想啊。

01:18:15 - 01:18:17
權力濫用進取原則的意思是說，當你碰到下列的這些情況，

01:18:19 - 01:18:21
防衛權會被限縮，

01:18:22 - 01:18:24
甚至會根本被否定。

01:18:24 - 01:18:25
瞭解嗎？結論是這個意思。

01:18:26 - 01:18:30
當你碰到下面的情況，防衛權會被限縮，

01:18:30 - 01:18:31
甚至會被否定。

01:18:31 - 01:18:36
比如說你看到第一個，保全侵害法益的極端失衡。

01:18:38 - 01:18:41
這種情況會直接否定行為人的防衛權。

01:18:43 - 01:18:44
這個原則是什麼意思？

01:18:45 - 01:18:50
有些人看到這個原則覺得很怪，會想說奇怪，你剛不是說正當防衛不考慮法益衡量嗎？

01:18:50 - 01:18:52
結果怎麼這邊就來了一個法益衡量性呢？

01:18:52 - 01:18:52
所以各位，

01:18:53 - 01:18:55
那個我這邊寫極端有沒有，極端你把它圈起來。

01:18:58 - 01:19:00
重點是極端的失衡。

01:19:01 - 01:19:04
為了要保護很微小的利益，

01:19:05 - 01:19:08
而犧牲的被害人很嚴重的利益，

01:19:08 - 01:19:09
這個叫做極端失衡。

01:19:11 - 01:19:11
舉例來說，

01:19:12 - 01:19:17
如果有人要偷我桌上這瓶喝到大概剩三成的礦泉水，

01:19:19 - 01:19:20
他要偷我這個礦泉水，

01:19:21 - 01:19:23
我為了奪回這個礦泉水，

01:19:23 - 01:19:24
所以我追了出去。

01:19:25 - 01:19:26
追出去之後啊，

01:19:26 - 01:19:29
眼看著偷水的同學跑到逃生梯了,

01:19:30 - 01:19:33
我為了奪回這瓶礦泉水,

01:19:33 - 01:19:37
我把同學絆倒，讓同學從七樓滾到六樓，渾身擦傷還腦震盪。

01:19:38 - 01:19:39
這就叫做極端失衡。

01:19:41 - 01:19:44
這一瓶水被我喝到剩下不到一半,

01:19:44 - 01:19:47
它的財產價值趨近於零。

01:19:47 - 01:19:52
我為了保護這個沒有什麼財產價值的東西，犧牲的小偷很嚴重的法益，

01:19:52 - 01:19:53
這叫做極端失衡。

01:19:54 - 01:19:55
這種情況會怎麼樣？

01:19:56 - 01:19:58
直接不準正當防衛喔。

01:19:58 - 01:19:59
知道嗎？他會直接

01:20:00 - 01:20:03
不準這當防衛喔，否定權人的防衛權。

01:20:03 - 01:20:05
好，所以這個叫極端失衡，再講一次是極端喔。

01:20:06 - 01:20:08
不是一般的違反衡平性喔。

01:20:09 - 01:20:12
一般這當防衛我們就說怎麼樣，不看衡平性嘛，對不對，所以這裡講的是這種極端失衡的狀態。

01:20:15 - 01:20:18
來，那回到我剛剛所說的，學理性的問題。

01:20:20 - 01:20:23
你看喔，正當防衛的權力濫用進去，下面的1234這四個字原則。

01:20:27 - 01:20:32
這些東西是我們的法條有規定的，或者是從我們的法條推導出來的東西嗎？

01:20:33 - 01:20:35
其實沒有，對不對？其實沒有。

01:20:36 - 01:20:37
所以各位你想一件事。

01:20:39 - 01:20:42
我們在正當防衛附加這些原則。

01:20:44 - 01:20:47
然後說違反這些原則，要麼防衛變過當。

01:20:47 - 01:20:49
要麼防衛權直接給你否定。

01:20:51 - 01:20:52
這個有沒有罪刑法定的問題？

01:20:53 - 01:20:54
對啊，這個很學理。

01:20:55 - 01:20:56
法研所就有可能會考，對啊，你覺得

01:20:59 - 01:21:01
承認正當防衛

01:21:01 - 01:21:01
的是為人限制。

01:21:01 - 01:21:03
這個東西是法無明文的哦。

01:21:03 - 01:21:05
你承認這個東西會不會違反罪刑法定原則？

01:21:06 - 01:21:07
其實這個有人討論，你知道嗎？

01:21:08 - 01:21:08
對啊，就是

01:21:09 - 01:21:10
因為我們這樣說哈。

01:21:11 - 01:21:13
正當防衛是一條無罪的規定。

01:21:14 - 01:21:15
它是一條讓行為人無罪的規定。

01:21:16 - 01:21:20
你在一個讓行為人無罪的規定之上，添加法律所沒有的限制。

01:21:21 - 01:21:22
是不是讓這個規定更難成立？

01:21:23 - 01:21:23
懂我的意思吧？

01:21:24 - 01:21:25
會讓這個規定更難成立。

01:21:25 - 01:21:30
那這種在法無明文的情況之下，限縮對行為人有利的規定。

01:21:30 - 01:21:33
難道不會有罪刑法定的問題嗎？

01:21:33 - 01:21:33
懂我的意思吧？

01:21:33 - 01:21:34
這是一個討論的點。

01:21:36 - 01:21:39
所以像有些學者他們切入的角度就會覺得說

01:21:40 - 01:21:41
他們會說沒有，為什麼？

01:21:41 - 01:21:43
因為他們會說權力濫用進去。

01:21:44 - 01:21:48
它是所有法律裡面的原則，甚至可以上溯到憲法的層次。

01:21:49 - 01:21:51
它就是所有法律裡面的共同原則。

01:21:51 - 01:21:55
所以我們在這當防衛裡面加入這個原則就是OK的。

01:21:55 - 01:21:57
因為這個原則它有更高的地位。

01:21:57 - 01:21:58
你也只能這樣論述嘛,不然怎麼辦？

01:21:58 - 01:21:59
對不對,所以

01:22:00 - 01:22:02
這個東西確實會有一些爭議吼,只是

01:22:03 - 01:22:04
多數還是承認他的

01:22:05 - 01:22:08
好,所以我說這是第一個,我們講的極端虛擬還這些型

01:22:09 - 01:22:11
再來,我們翻到下一頁,150頁

01:22:12 - 01:22:16
再來第二個叫做對無責任利己者的攻擊行為

01:22:18 - 01:22:20
我們這邊特別講,是攻擊喔

01:22:20 - 01:22:22
請你把攻擊兩個字圈起來

01:22:23 - 01:22:26
對於無責任利己者的攻擊行為

01:22:27 - 01:22:30
也會面臨到社會的倫理限制

01:22:31 - 01:22:36
對於這個小孩、精神病患、智能障礙者之類的

01:22:36 - 01:22:39
對於無責任能力者的攻擊行為呢

01:22:40 - 01:22:41
我們應該怎麼做？

01:22:42 - 01:22:44
各位，三階段防衛，請你標上123

01:22:45 - 01:22:45
來看到這邊

01:22:46 - 01:22:49
第一個，要先採取迴避措施

01:22:49 - 01:22:50
這個你標上一

01:22:50 - 01:22:52
迴避措施，你要先逃跑

01:22:54 - 01:22:58
第二個，沒辦法的話呢，要採取保護性的防禦措施

01:22:58 - 01:23:00
你標上二號，保護性

01:23:00 - 01:23:00
最後

01:23:00 - 01:23:05
不得已的時候呢，你不要上三，攻擊性的防衛措施

01:23:06 - 01:23:07
123

01:23:07 - 01:23:08
三個步驟

01:23:08 - 01:23:08
先試著逃跑

01:23:10 - 01:23:13
再採取保護性的防禦措施

01:23:14 - 01:23:17
最後呢,才可以採取攻擊性的防衛措施

01:23:18 - 01:23:20
一二三三個步驟

01:23:20 - 01:23:20
所以各位啊

01:23:21 - 01:23:25
如果今天晚上我回到家，從捷運站經過我家附近的小巷的時候

01:23:26 - 01:23:28
遇到有一個小學生要無故攻擊我

01:23:29 - 01:23:32
我可以怎麼做，直接反擊他，不可以

01:23:32 - 01:23:33
我要先怎麼做，先試著逃跑

01:23:35 - 01:23:36
先試著逃跑

01:23:37 - 01:23:38
逃不掉怎麼辦

01:23:38 - 01:23:41
小學生是田徑隊的，跑得比我還快，怎麼辦

01:23:41 - 01:23:44
這時候呢，要採取保護性的防禦措施

01:23:44 - 01:23:47
我要拿我的後揹包抵擋看看

01:23:47 - 01:23:48
最後

01:23:48 - 01:23:50
不得已，後揹包擋不住

01:23:50 - 01:23:50
小學生有刀

01:23:51 - 01:23:52
我才可以拿石頭去丟他

01:23:52 - 01:23:53
知道嗎

01:23:53 - 01:23:55
123，三階段防衛

01:23:56 - 01:23:59
所以我們講，對無責任力者的攻擊

01:24:00 - 01:24:02
要採取一二三，三階段防衛喔。

01:24:02 - 01:24:05
那為什麼要同學特別把「攻擊」兩個字圈起來？

01:24:06 - 01:24:07
哎呀，很簡單啦。

01:24:07 - 01:24:12
因為只有這種具有攻擊性、具有暴力性的行為，才有可能做三階段防衛。

01:24:13 - 01:24:18
否則你想嘛,如果是對無責任能力人那種不具攻擊性的侵害,什麼意思?

01:24:18 - 01:24:24
我在早餐店吃早餐滑手機的時候,有小學生當著我的面搶走我的手機。

01:24:25 - 01:24:27
然後你跟我說我要三階段防衛,我要先逃跑。

01:24:28 - 01:24:29
有沒有感覺超莫名其妙?

01:24:29 - 01:24:32
小學生偷我手機,然後你跟我說我要先逃跑,我怎麼逃跑?

01:24:32 - 01:24:33
沒有意義嘛,

01:24:33 - 01:24:36
或者小學生罵我五字經，我要先試著逃跑。

01:24:36 - 01:24:37
不可能，好嗎？

01:24:37 - 01:24:42
所以只有這種攻擊性的行為，才有可能，才有可能。

01:24:43 - 01:24:46
這個東西，上禮拜的普考法廉才剛考過。

01:24:46 - 01:24:48
所以這個東西,我不知道有沒有同學去考,應該沒有啊。

01:24:48 - 01:24:50
上禮拜我記得你們都來。

01:24:51 - 01:24:52
上禮拜普考就考這個東西。

01:24:53 - 01:24:56
他考說,有個爸爸帶兒子去公園玩,

01:24:56 - 01:24:57
兒子年紀很小。

01:24:57 - 01:24:58
幼童。

01:24:58 - 01:25:02
結果呢,有另外一個幼童啊,狂奔向他兒子。

01:25:03 - 01:25:04
眼看著就要撞上了。

01:25:05 - 01:25:09
爸爸在還來得及把他的兒子抱走的情況之下,

01:25:09 - 01:25:11
爸爸不把兒子抱走喔,

01:25:11 - 01:25:14
反而把那個屁孩絆倒，讓那個屁孩受傷。

01:25:15 - 01:25:15
說這個東西啊，

01:25:16 - 01:25:17
是不是你見識啊，對不對？

01:25:17 - 01:25:20
對於無責任能力人的侵害，

01:25:21 - 01:25:21
我們應該怎麼樣？

01:25:22 - 01:25:22
123。

01:25:23 - 01:25:26
可以把兒子抱走,為什麼不抱走,為什麼直接給他給人家絆倒?

01:25:26 - 01:25:28
他考這個東西啊,知道哦。

01:25:30 - 01:25:32
好,接下來我們來看到圈圈三。

01:25:33 - 01:25:35
生活上具有密切信賴關係的親屬,

01:25:36 - 01:25:37
家庭成員之間啊。

01:25:38 - 01:25:40
所以如果你被家庭成員攻擊的話，

01:25:41 - 01:25:41
要怎麼樣？

01:25:42 - 01:25:44
一樣喔，123。

01:25:44 - 01:25:50
先試著逃跑，再做保護性，再做攻擊性，試著做123。

01:25:51 - 01:25:53
那我跟你們說，這個原則，

01:25:53 - 01:25:57
圈圈三這個原則，其實會有一些反對的意見。

01:25:58 - 01:26:00
說來太學理，所以我沒有把

01:26:00 - 01:26:00
拿整理上來。

01:26:01 - 01:26:06
那個臺大的兩位老師，區志仁老師，還有周揚儀老師，都有對這個部分提出一些反對的看法。

01:26:07 - 01:26:08
為什麼說這個原則有問題喔。

01:26:09 - 01:26:10
我就講最淺顯的兩個論點。

01:26:12 - 01:26:14
講太深不需要，講最淺顯的兩個論點。

01:26:15 - 01:26:15
第一個吼。

01:26:16 - 01:26:19
你說對家庭成員的攻擊要採123。

01:26:19 - 01:26:20
這是不是在助長家暴？

01:26:21 - 01:26:23
被家暴的人不應該忍受吧。

01:26:23 - 01:26:24
為什麼他要先跑，對吧？這第一個問題喔。

01:26:26 - 01:26:27
第二個問題，比較學裡面。

01:26:29 - 01:26:30
第二個問題是？

01:26:31 - 01:26:32
那你要想一想。

01:26:33 - 01:26:34
這背後的道理到底是什麼。

01:26:35 - 01:26:39
為什麼對家庭成員的攻擊，我們反而要多一分容忍。

01:26:40 - 01:26:41
這樣你不覺得很奇怪嗎。

01:26:42 - 01:26:47
我們被生在這個家，家庭成員有誰，這不是我們能決定的吧。

01:26:48 - 01:26:50
尤其是原生家庭，對不對。

01:26:50 - 01:26:53
你誕生在這個家庭，你出生就在這個家，家裡有誰你怎麼決定？

01:26:54 - 01:26:56
對啊，那為什麼對這種不能決定的事，

01:26:57 - 01:26:59
我們反而要多承擔義務？

01:27:00 - 01:27:05
因為從我們現在的法律思想來講，我們人要負義務，前提是這個義務有經過我們的同意。

01:27:06 - 01:27:08
可以瞭解這意思吧，我們民法上講契約自由。

01:27:08 - 01:27:09
背後就這個想法。

01:27:09 - 01:27:13
我們要負義務的前提是這個義務有辦法經過，有經過本人同意，或者我們有辦法說不。

01:27:14 - 01:27:16
可是家庭成員，我們就誕生在這個家。

01:27:17 - 01:27:18
我們怎麼選？

01:27:19 - 01:27:20
你說你可以搬家喔。

01:27:20 - 01:27:21
可是。

01:27:22 - 01:27:23
萬一這個人經濟還沒有獨立呢？

01:27:23 - 01:27:25
對不對，我們沒有辦法選擇家庭成員啊。

01:27:26 - 01:27:27
所以。

01:27:27 - 01:27:28
這個就讓我想到了另外一件事。

01:27:29 - 01:27:33
每到過年前啊，都有人說，親戚是一種惹人厭的生物。

01:27:34 - 01:27:36
尤其是對國考的考生來講更是如此。

01:27:36 - 01:27:38
因為親戚很喜歡問你一些討厭的問題。

01:27:39 - 01:27:40
比如說。

01:27:40 - 01:27:41
你還在備考的時候。

01:27:41 - 01:27:42
親戚要問你啦。

01:27:42 - 01:27:44
你什麼時候才考上啊。

01:27:44 - 01:27:46
你怎麼考那麼多年了，你真的會上嗎？

01:27:46 - 01:27:47
擺爛，對不對。

01:27:47 - 01:27:48
好，等你考上了，親戚要問了。

01:27:48 - 01:27:52
那你考上了，什麼時候要結婚啊？如果你真的結婚了，

01:27:52 - 01:27:55
要問你，那你什麼時候要生小孩啊？那假設你真的生了，要問你，

01:27:55 - 01:27:59
那什麼時候生第二胎啊？很好，你。

01:28:00 - 01:28:01
對嘛，對不對？很多人會問，為什麼親戚這麼討厭？

01:28:03 - 01:28:07
那我的回答是，其實不是親戚這個身分討厭，我們也是別人的親戚。

01:28:08 - 01:28:11
你會覺得親戚討厭是因為你沒有辦法選擇你的親戚。

01:28:13 - 01:28:14
對啊，你自己想的，難道不是嗎？

01:28:15 - 01:28:19
在日常的社交場合當中，比如說你討厭你旁邊的同學。

01:28:19 - 01:28:23
那你就不要坐他旁邊嘛，你就不要跟他講話，問題就解決了嘛。

01:28:24 - 01:28:25
可是親戚不是啊。

01:28:26 - 01:28:27
你很討厭你嬸嬸。

01:28:27 - 01:28:30
可是你討厭他沒有用啊，你叔叔就愛他啊。

01:28:30 - 01:28:31
不然他怎麼會是你嬸嬸？

01:28:32 - 01:28:33
所以親戚你沒辦法選啊，對不對？

01:28:34 - 01:28:38
所以我就說啊，回到這問題也是，家庭成員不是我們一般人可以選擇的。

01:28:39 - 01:28:43
那對於這種沒有選擇的事，為什麼我們要莫名其妙承擔這種義務？

01:28:43 - 01:28:44
懂我的意思吧？

01:28:44 - 01:28:46
所以有些學者會認為說這個原則有問題啦。

01:28:47 - 01:28:49
助長家暴，還有它沒有實質上的依據，所以這個東西可能有一些討論的空間。

01:28:52 - 01:28:54
再來最後一個叫做挑唆防衛。

01:28:55 - 01:28:56
挑唆防衛什麼意思？

01:28:57 - 01:28:59
之所以需要正當防衛，

01:28:59 - 01:29:02
是來自於防衛者的挑釁行為。

01:29:03 - 01:29:04
這個叫挑唆防衛。

01:29:04 - 01:29:06
先去挑釁人家。

01:29:07 - 01:29:09
等對方被激怒了，你再藉機防衛。

01:29:09 - 01:29:10
這個叫挑唆防衛。

01:29:11 - 01:29:14
那你看喔，挑唆防衛分成下面兩類，意圖式跟非意圖式。

01:29:16 - 01:29:18
我們先講這兩類怎麼區分。

01:29:19 - 01:29:22
所謂意圖式跟非意圖式的意思是。

01:29:23 - 01:29:24
我們要看。

01:29:24 - 01:29:30
這個防衛的人，他有沒有想假借正當防衛之名

01:29:31 - 01:29:33
進行攻擊之實，看的是這個，知道嗎？

01:29:35 - 01:29:40
看防衛者有沒有想假借防衛之名，進行攻擊之實，看的是這個東西。

01:29:42 - 01:29:44
所以啊,什麼叫意圖式,什麼叫非意圖式?

01:29:45 - 01:29:47
意圖式是那種很陰險,他就是為了要攻擊對方。

01:29:49 - 01:29:52
所以故意激怒對方,設這個局,等對方被激怒再來一拳打下去說我正當防衛。

01:29:55 - 01:29:57
這叫做意圖式,所以舉個例來說啊。

01:30:00 - 01:30:04
如果我一直看一個學弟不爽,想揍他。

01:30:05 - 01:30:09
可是我又想說，身為法律人，我們這樣動手動腳，給人家傳出去不好聽喔。

01:30:09 - 01:30:10
那我該怎麼做呢？

01:30:10 - 01:30:13
我想說，我知道了，就約學弟出來吃飯。

01:30:13 - 01:30:15
啊約學弟出來吃飯之後呢？

01:30:16 - 01:30:19
我就開始關心這個學弟的近況啦，說學弟啊，好久不見喔。

01:30:20 - 01:30:24
啊為什麼你每年考律師考試都沒有什麼起色啊？

01:30:24 - 01:30:25
為什麼啊？好奇怪喔。

01:30:26 - 01:30:28
你每年考醫師好像都沒有過欸。

01:30:28 - 01:30:33
醫師滿分600，為什麼你每年拿到的分數連200都不到啊？

01:30:33 - 01:30:34
瞎猜可能都比你高欸。

01:30:35 - 01:30:36
你智商正不正常啊？

01:30:37 - 01:30:40
你以前國小念哪一間？你是不是那個啟智學校畢業的？

01:30:40 - 01:30:41
這樣問他。

01:30:42 - 01:30:43
學弟被問得很不爽啊。

01:30:44 - 01:30:46
其實我就繼續跟學弟說啦，所以學弟啊，我跟你說啊，

01:30:47 - 01:30:50
你就算考得上律師啊，你也接不到案件啊。

01:30:51 - 01:30:54
你做人這麼失敗，不要得罪客戶就不錯了，你怎麼可能會有案子呢？

01:30:55 - 01:30:56
我跟你說你去賣雞排啦，

01:30:56 - 01:31:00
在東吳這邊賣雞排生意不錯啦，不要考律師去賣雞排啦。

01:31:01 - 01:31:02
假設我這樣跟學弟講。

01:31:02 - 01:31:06
學弟聽得很火啊，想說天啊，學長把我找來吃飯，竟然是羞辱我啊。

01:31:06 - 01:31:07
捲起袖子就要打我。

01:31:08 - 01:31:10
我想，笨蛋，果然中計了吧。

01:31:10 - 01:31:12
他要打我啊，趕快一拳揍下去。

01:31:13 - 01:31:15
這就叫什麼呢？意圖式的挑釁防衛。

01:31:17 - 01:31:20
假借正當防衛之名，行攻擊之實。

01:31:20 - 01:31:22
這種比較惡劣的會怎麼樣？

01:31:22 - 01:31:23
否定防衛權。

01:31:23 - 01:31:24
懂嗎？這會否定防衛權喔。

01:31:25 - 01:31:26
相對的什麼叫非意圖式？

01:31:28 - 01:31:31
剛剛同樣的飯局，但假設我沒有那麼惡質，

01:31:32 - 01:31:36
我啊，原本就只是真的想跟學弟說，

01:31:36 - 01:31:38
你不適合考國考。

01:31:39 - 01:31:42
你手藝還不錯啊，那手藝還不錯的話，為什麼不去賣雞排呢？

01:31:42 - 01:31:45
你賣雞排生意好，搞不好賺得比你當律師還多欸。

01:31:46 - 01:31:51
我原本只是想這樣講，然後可能講話的語氣比較尖酸刻薄，甚至帶點髒話，讓對方聽得不太高興，

01:31:52 - 01:31:53
對方就想打我了。

01:31:53 - 01:31:55
這個叫什麼？非意圖式。

01:31:55 - 01:31:57
瞭解嗎？這個叫非意圖式喔。

01:31:57 - 01:31:59
非意圖式的話應該怎麼樣？

01:31:59 - 01:32:00
欸。

01:32:00 - 01:32:01
你要做123，

01:32:02 - 01:32:03
先試著逃跑，

01:32:03 - 01:32:05
逃不掉的話，保護性，

01:32:05 - 01:32:07
最後不得已才可以攻擊性。

01:32:08 - 01:32:11
好，所以這個是我們講四種的社會的限制。

01:32:11 - 01:32:13
所以同學你有沒有發現，

01:32:13 - 01:32:18
落入正當防衛的社會的限制，有可能會有兩種不同的後果。

01:32:20 - 01:32:23
第一種後果是最嚴重的，直接否定防衛權。

01:32:24 - 01:32:26
第二種後果是，你又要作123。

01:32:26 - 01:32:28
來，我們這樣記，我們記一種就好。

01:32:29 - 01:32:31
你兩組都記到最後就會亂掉。

01:32:31 - 01:32:36
我們記得有兩種情況是最嚴重會直接否定防衛權的。

01:32:37 - 01:32:38
有沒有發現哪兩種？

01:32:38 - 01:32:40
第一個叫極端失衡。

01:32:40 - 01:32:42
第二個叫做意圖式的挑釁防衛。

01:32:43 - 01:32:43
看到了嗎？

01:32:44 - 01:32:45
我們前面的體系圖也有喔。

01:32:47 - 01:32:49
那個，第幾頁啊？

01:32:51 - 01:32:52
140頁吧，有沒有看到？

01:32:54 - 01:32:55
最嚴重的兩類,

01:32:56 - 01:32:59
極端失衡，還有意圖式的挑釁防衛。

01:33:00 - 01:33:03
這兩類最嚴重的，我們會怎麼樣？

01:33:03 - 01:33:05
直接否定防衛權。

01:33:06 - 01:33:10
那剩下幾種沒那麼嚴重的話呢，三階段防衛。

01:33:10 - 01:33:10
OK嗎？

01:33:10 - 01:33:11
就這樣記喔。

01:33:11 - 01:33:13
我們只記得兩類最嚴重的，

01:33:13 - 01:33:16
意圖式挑釁防衛，還有極端失衡。

01:33:16 - 01:33:18
這兩種最嚴重的，會否定防衛權。

01:33:18 - 01:33:20
所以剩下的就是什麼呢？

01:33:20 - 01:33:21
要做123，

01:33:21 - 01:33:24
你記一種，那其他的就不是，這樣就好了。

01:33:29 - 01:33:30
好，151頁這一題，

01:33:30 - 01:33:33
十年前的考題，這也是一個很經典的題目，我們來看一下。

01:34:16 - 01:34:17
你看喔,

01:34:17 - 01:34:20
這一題當中,甲把乙推開,

01:34:20 - 01:34:23
乙重心不穩,跌倒摔斷腿,

01:34:23 - 01:34:23
骨折,

01:34:23 - 01:34:25
你看又是那個考點,

01:34:25 - 01:34:27
骨折不是重傷嗎，輕傷嗎？

01:34:27 - 01:34:29
所以甲該當這個普通傷害罪。

01:34:30 - 01:34:32
接下來喔，就正當防衛來說，

01:34:33 - 01:34:34
第一個來，防衛前提有沒有符合？

01:34:35 - 01:34:36
現在不法侵害。

01:34:36 - 01:34:37
有，

01:34:37 - 01:34:37
對吧？

01:34:38 - 01:34:39
確實啊，

01:34:39 - 01:34:42
對不對，對方拿那個木劍要攻擊他。

01:34:43 - 01:34:46
這裡確實有一個現在不法侵害的存在。

01:34:46 - 01:34:46
OK,沒有問題。

01:34:47 - 01:34:48
接著,

01:34:48 - 01:34:52
現在不法侵害具備了,接下來,

01:34:53 - 01:34:57
這邊有沒有那個防衛手段有沒有過當?

01:34:58 - 01:34:59
適當性,必要性,

01:35:00 - 01:35:00
它有沒有效？

01:35:01 - 01:35:02
有啊，有效啊。

01:35:02 - 01:35:05
是不是所有有效的手段當中損害最小的？

01:35:06 - 01:35:06
也是嘛。

01:35:06 - 01:35:07
這個沒有問題嘛。

01:35:08 - 01:35:09
不然還有什麼有效的防衛手段？

01:35:10 - 01:35:10
沒有啊。

01:35:11 - 01:35:13
所以這裡的問題在什麼？挑唆防衛。

01:35:14 - 01:35:15
這裡的問題在挑唆防衛。

01:35:16 - 01:35:18
這裡是意圖式還是非意圖式？

01:35:19 - 01:35:24
你覺得甲是為了要傷害乙，所以故意去嗆他，

01:35:24 - 01:35:27
然後等乙要攻擊甲的時候，甲再把乙推倒，

01:35:27 - 01:35:29
甲是個這麼陰險的人嗎？

01:35:29 - 01:35:30
看起來不是嘛，

01:35:30 - 01:35:32
所以這題是什麼呢？非意圖式。

01:35:32 - 01:35:34
那非意圖式的話我們要怎麼做?

01:35:34 - 01:35:34
要123,

01:35:35 - 01:35:35
其他有沒有?

01:35:35 - 01:35:36
沒有吧。

01:35:36 - 01:35:38
所以我們說,這題會變什麼?防衛過當,

01:35:39 - 01:35:40
知道嗎？這題會變防衛過當。

01:35:40 - 01:35:43
所以啊，我們緊接著來看到152頁。

01:35:47 - 01:35:48
防衛過當有哪些？

01:35:49 - 01:35:49
好，來

01:35:49 - 01:35:51
我們講防衛過當的效果，放在罪責。

01:35:52 - 01:35:52
記得哦,

01:35:53 - 01:35:56
正當防衛一律一旦過當的話,

01:35:56 - 01:35:58
過當就不叫正當防衛了喔,

01:35:58 - 01:36:00
它就不能阻

01:36:00 - 01:36:00
去違法了。

01:36:01 - 01:36:06
所以如果你遇到防衛過當的話，我們只能在罪責做處理。

01:36:07 - 01:36:11
換句話講，23條的但書那個東西我們是放在罪責，

01:36:11 - 01:36:13
不是放在違法性喔，好。

01:36:14 - 01:36:15
那我們看喔，

01:36:15 - 01:36:17
防衛過當的人，

01:36:17 - 01:36:21
他沒辦法阻卻違法，他最多減免罪責。

01:36:22 - 01:36:24
那我們剛剛講，有哪些情況是防衛過當？

01:36:24 - 01:36:26
第一個，違反正當防衛的一般限制，

01:36:27 - 01:36:29
適當性、必要性。

01:36:30 - 01:36:34
防衛行為如果有違反適當性或是必要性的話，

01:36:34 - 01:36:36
OK,這個叫防衛過當,

01:36:36 - 01:36:37
沒有疑問。

01:36:37 - 01:36:38
再來,

01:36:39 - 01:36:42
還有,那違反社會倫理限制,

01:36:43 - 01:36:44
算不算過當?

01:36:45 - 01:36:48
違反社會倫理限制，你要看，又回到剛剛那個類型。

01:36:48 - 01:36:52
我們剛剛不是講嗎？違反社會倫理限制的效果有兩種，

01:36:52 - 01:36:54
第一個是直接否定防衛權，

01:36:54 - 01:36:56
第二個是要做123。

01:36:56 - 01:36:57
好，很簡單，延續這個分類。

01:36:58 - 01:37:03
否定防衛權的那兩種情形，因為權力濫用太過嚴重了，

01:37:03 - 01:37:07
所以那種類型呢，不但直接否定正當防衛，

01:37:07 - 01:37:11
而且啊，也沒有防衛過當適用的空間。

01:37:11 - 01:37:13
OK嗎？最嚴重那兩種，

01:37:13 - 01:37:15
直接否定防衛權的。

01:37:15 - 01:37:15
那會怎麼樣？

01:37:16 - 01:37:17
就否定了喔，

01:37:18 - 01:37:19
也沒有防衛過當適用的空間喔。

01:37:20 - 01:37:22
那反過來說，如果是沒有那麼嚴重的話呢？

01:37:23 - 01:37:24
該做123而沒有做，

01:37:25 - 01:37:26
那有沒有防衛過當的空間？

01:37:26 - 01:37:27
有。

01:37:27 - 01:37:30
所以上面那一題，合氣道老師的那一題，

01:37:30 - 01:37:34
那一題當中是怎麼樣？該做123而沒有做，

01:37:34 - 01:37:35
所以這個叫什麼？

01:37:36 - 01:37:37
這叫做防衛過當。

01:37:37 - 01:37:41
他還是可以減免，懂嗎？那個效果沒那麼嚴厲，還是可以減免。

01:37:42 - 01:37:44
好，所以我們說，這是一般的強度型的過當，

01:37:45 - 01:37:47
像我們剛剛說的情況呢，通通都是。

01:37:48 - 01:37:52
接下來啊，第二個叫做延展型的防衛過當。

01:37:52 - 01:37:54
這是一個從德文翻譯過來的名詞啦,

01:37:55 - 01:37:57
所以同學可能會覺得不知所云，啊什麼叫延展型？

01:37:58 - 01:38:00
我跟各位說，延展型

01:38:00 - 01:38:02
那個延展就是指時間的意思。

01:38:03 - 01:38:10
所以啊，延展型防衛過當，指的就是呢，防衛的時間不適當，防衛的時間不適當，好，我這邊畫一個圖。

01:40:13 - 01:40:13
好，我來舉個例子喔。

01:40:13 - 01:40:13
這個例子很簡單，我們看喔。

01:40:14 - 01:40:14
假設晚上回家的時候，我走出捷運站在我家附近的小巷。

01:40:14 - 01:40:14
突然有一個歹徒要對我性侵犯。

01:40:14 - 01:40:14
那我為了防衛自己的性自主，所以呢，我拿石頭丟了這個歹徒。

01:40:15 - 01:40:15
歹徒被我擊中之後啊，當場倒在地上，疼痛不已。

01:40:15 - 01:40:15
來，就這個部分來說，

01:40:15 - 01:40:16
我

01:42:00 - 01:42:02
該當傷害罪，可不可以主張阻卻違法？

01:42:02 - 01:42:04
絕對可以，這個沒有疑問，對不對？

01:42:04 - 01:42:04
好，所以喔，

01:42:05 - 01:42:08
歹徒要對我性侵，我拿石頭丟他，

01:42:08 - 01:42:12
這個歹徒被丟了之後啊，當場倒在地上，

01:42:12 - 01:42:15
這時候，我可以主張正當防衛，這個沒有問題，

01:42:16 - 01:42:17
好，請各位想。

01:42:18 - 01:42:20
歹徒倒地之後,

01:42:21 - 01:42:22
我沒有這樣走了喔,

01:42:22 - 01:42:24
歹徒倒地之後啊,

01:42:25 - 01:42:25
我想想,

01:42:26 - 01:42:28
這個人是真的倒了嗎?

01:42:28 - 01:42:30
會不會他只是假死啊?

01:42:31 - 01:42:32
我覺得不甘心,

01:42:33 - 01:42:36
於是啊,我再拿石頭丟他好幾下,

01:42:36 - 01:42:38
讓他肋骨斷掉好幾根,

01:42:39 - 01:42:41
後面這個部分,還有沒有正當防衛的空間?

01:42:42 - 01:42:43
沒有？

01:42:43 - 01:42:43
為什麼？

01:42:43 - 01:42:44
因為歹徒倒地了。

01:42:45 - 01:42:49
歹徒倒地的話，是不是代表侵害已經過去了？

01:42:49 - 01:42:51
我不再有防衛權了，對不對？

01:42:51 - 01:42:55
所以喔，後面這個階段，我再拿

01:42:56 - 01:42:58
這個石頭去丟這個歹徒，

01:42:58 - 01:43:00
造成他肋骨斷掉好幾根，

01:43:00 - 01:43:03
這時候啊，因為已經沒有防衛權了，

01:43:03 - 01:43:03
所以怎麼辦呢？

01:43:04 - 01:43:07
傳統見解就區分情形而論,

01:43:07 - 01:43:07
區分說,

01:43:08 - 01:43:10
看我是誤認識事實，或是誤認法律,

01:43:10 - 01:43:11
什麼意思呢?

01:43:12 - 01:43:14
其實當下歹徒已經倒了,

01:43:14 - 01:43:17
他已經沒有能力要侵犯我了,

01:43:17 - 01:43:19
但是我以為他是裝死,

01:43:20 - 01:43:21
這個叫誤認事實,

01:43:21 - 01:43:23
誤認事實的情形,很簡單,

01:43:23 - 01:43:24
誤想防衛啊,對不對?

01:43:24 - 01:43:27
客觀上那個侵害結束了，但我以為他還在啊，是誤想防衛啊。

01:43:29 - 01:43:30
相對的，

01:43:30 - 01:43:32
那如果是誤認法律呢？

01:43:32 - 01:43:33
什麼叫誤認法律？

01:43:33 - 01:43:36
我知道歹徒倒了，沒有能力侵犯我了。

01:43:37 - 01:43:38
但我法律讀得不好,

01:43:38 - 01:43:39
我想說,

01:43:40 - 01:43:42
我應該有權力自力救濟吧,

01:43:42 - 01:43:44
我把他肋骨打斷幾根,

01:43:45 - 01:43:45
合理吧,

01:43:45 - 01:43:47
誰叫他要性侵我，罪有應得嘛。

01:43:47 - 01:43:49
我覺得我在法律上有報復的權限。

01:43:49 - 01:43:52
這種情況，當然我們走16條處理，容許錯誤，這個以後我會說。

01:43:54 - 01:43:56
所以啊，傳統講解的話，

01:43:56 - 01:44:00
在這種侵害已過，已沒有能力。

01:44:00 - 01:44:03
容許錯誤的情況呢,我們會再去做區分喔。

01:44:03 - 01:44:06
看行為人到底是誤認事實,還是誤認法律,而有不同的想法,

01:44:06 - 01:44:08
而有不同的處理。

01:44:08 - 01:44:14
而後來的學說呢,像許恆達老師,他們就有提出一個說法叫做延展型防衛過當。

01:44:15 - 01:44:19
其實這個東西也不是憑空冒出來的啦,因為德國刑法有規定。

01:44:19 - 01:44:25
在德國刑法之下的防衛過當，除了這種強度型的過當之外，

01:44:25 - 01:44:28
也包括這一種延展型的過當。

01:44:29 - 01:44:32
這種延展型又叫做擴張型，

01:44:32 - 01:44:38
我記得又叫擴張型，林書楷老師的書好像是寫擴張型，又叫做擴張型的防衛過當。

01:44:39 - 01:44:41
這一種類型是這樣喔。

01:44:42 - 01:44:45
學者認為說來，你看到定義這邊，153頁。

01:44:46 - 01:44:48
153頁上面的那個圈圈二，

01:44:48 - 01:44:49
你看一下。

01:44:51 - 01:44:52
他說什麼叫延展型呢？

01:44:53 - 01:44:56
行為人原先面臨不法侵害。

01:44:57 - 01:44:59
那採取必要的手段排除不法侵害之後呢,

01:45:00 - 01:45:06
因為驚恐而在時空不中斷的情況之下,另外攻擊原本的不法侵害者。

01:45:07 - 01:45:09
那雖然後階段沒有明顯的不法侵害存在,

01:45:09 - 01:45:13
但是呢,基於跟前段合法行為的整體關係,

01:45:13 - 01:45:17
我們呢,仍然擴張解釋23條的但書。

01:45:18 - 01:45:21
所以我說嘛,延展型防衛過當是什麼意思?

01:45:22 - 01:45:24
正當防衛的時間不適當,

01:45:25 - 01:45:26
OK嗎?時間不適當。

01:45:26 - 01:45:28
在時間上來講,

01:45:29 - 01:45:34
這個防衛行為已經不適當了,這個叫延展型的防衛過當。

01:45:34 - 01:45:38
所以啊,照延展型防衛過當這個理論的話,

01:45:39 - 01:45:44
我後面再拿石頭去丟這個歹徒,讓他的肋骨斷掉好幾根,

01:45:45 - 01:45:48
如果你採延展型防衛過當這個理論的話,會怎麼樣?

01:45:49 - 01:45:51
讓我後段變防衛過當喔。

01:45:51 - 01:45:52
那個更有利耶。

01:45:52 - 01:45:56
因為你看喔,如果走誤想防衛,誤想防衛就改用過失犯。

01:45:57 - 01:46:00
啊如果你走延展型防衛過當呢,

01:46:00 - 01:46:05
防衛過當是必減,不是必減免,它是減輕或免除哦,它是可以減輕或免除哦。

01:46:06 - 01:46:07
它多了免刑這個選項哦,對行為人更有利,知道嗎？

01:46:07 - 01:46:09
更有利哦,所以

01:46:11 - 01:46:15
學理上確實有人提出延展型防衛過當這個概念。

01:46:15 - 01:46:22
這個概念最早介紹的是許恆達老師的文章，2012，你看現在也有一段時間了。

01:46:23 - 01:46:27
那目前學界的話，這個觀念應該是沒有人明確反對啦。

01:46:27 - 01:46:34
大家應該都有支持，像許玉老師有介紹，還有像林書楷老師的教科書也有介紹到。

01:46:35 - 01:46:37
許澤天老師的書上也有講到。

01:46:37 - 01:46:43
所以這個東西目前中生代的學者們應該都是支持他的，應該沒有什麼太大的反對意見。

01:46:43 - 01:46:48
好，所以我們現在呢都承認這種東西，延展型的防衛過當。

01:46:48 - 01:46:51
好，那接下來啊，括號三下面我們注意喔。

01:46:52 - 01:46:55
承認延展型防衛過當了。

01:46:55 - 01:46:59
就算我們承認它，也要注意下面幾個前提喔，好我們

01:47:00 - 01:47:00
我們來看喔。

01:47:01 - 01:47:02
第一個圈圈一。

01:47:03 - 01:47:10
延展型防衛過當，只能用來處理侵害開始後的不適當防衛。

01:47:11 - 01:47:12
也就是我們黑板上講的。

01:47:13 - 01:47:17
先有一個侵害，侵害開始後歹徒被擊退了。

01:47:18 - 01:47:19
行為人還繼續防衛。

01:47:20 - 01:47:23
這種侵害開始之後的不適當防衛，

01:47:23 - 01:47:27
才能適用延展型防衛過當。

01:47:27 - 01:47:29
侵害開始後才可以喔。

01:47:30 - 01:47:31
喔。

01:47:31 - 01:47:34
所以如果是侵害開始前，比如說我前面舉的例子。

01:47:34 - 01:47:42
你在夜的美食街發現隔壁是詐騙集團，所以你很生氣，你把那些成員痛打一頓，讓他們緊急就醫，沒辦法詐騙。

01:47:43 - 01:47:44
這不叫

01:47:44 - 01:47:45
延展型防衛過當。

01:47:45 - 01:47:49
所以第一個侵害開始之後才有適用的空間。

01:47:49 - 01:47:50
再來第二個啊。

01:47:52 - 01:47:53
圈圈二，這個以前考試考過哈。

01:47:54 - 01:47:59
局勢底定，防衛者處於絕對優勢的時候。

01:48:00 - 01:48:04
這個時候呢，就算承認這個理論，也不會有適用的餘地。

01:48:05 - 01:48:07
所以剛剛我舉的那個例子。

01:48:07 - 01:48:12
如果這個歹徒被我打了之後啊,被我反擊之後。

01:48:12 - 01:48:14
他不是單純的跌在地上喔。

01:48:14 - 01:48:17
他當場昏迷喪失意識喔。

01:48:17 - 01:48:19
如果已經進到這種情況的話。

01:48:19 - 01:48:22
那這個叫做局勢底定，防衛者主義者的優勢。

01:48:22 - 01:48:25
這種情況就算承認這個理論，也不再適用。

01:48:26 - 01:48:26
也不能適用。

01:48:27 - 01:48:28
這以前考試有考過。

01:48:28 - 01:48:30
以後我再帶各位來看。

01:48:30 - 01:48:33
這個應該是考在105年的高考行政類。

01:48:33 - 01:48:35
有一題那個抽戀愛稅那一題。

01:48:35 - 01:48:37
這個我們下禮拜拿到題目之後呢，我再帶各位來看。

01:48:39 - 01:48:39
好。

01:48:40 - 01:48:42
接下來我們來看到這個經濟問題。

01:48:43 - 01:48:46
免除罪責的防衛過當。

01:48:46 - 01:48:48
很特別，許澤天老師介紹的觀念。

01:48:50 - 01:48:52
這個東西喔，我們來看德國刑法的規定。

01:48:54 - 01:48:55
來154頁。

01:48:56 - 01:48:57
德國刑法的規定。

01:48:58 - 01:49:03
其實這篇文章雖然很長，但它就是把德國刑法那個概念引進到臺灣。

01:49:04 - 01:49:07
你看哦，德國刑法33條說，出於慌亂。

01:49:09 - 01:49:13
恐懼、驚嚇而超越防衛行為的尺度的話。

01:49:13 - 01:49:15
不罰，無罪耶。

01:49:16 - 01:49:20
所以德國刑法的防衛過當，有一種情況是根本無罪的。

01:49:21 - 01:49:24
這叫做免除罪責的防衛過當。

01:49:25 - 01:49:26
他的不法不是阻卻違法，不是喔。

01:49:27 - 01:49:29
他是無期待可能性而無罪喔。

01:49:29 - 01:49:31
這一種免除罪責防衛過當是這樣喔。

01:49:32 - 01:49:34
客觀上他的防衛是過當的。

01:49:34 - 01:49:36
不管強度型或延展型都OK。

01:49:36 - 01:49:38
客觀上強度過當。

01:49:38 - 01:49:39
重點是主觀。

01:49:39 - 01:49:40
你看主觀要怎麼樣。

01:49:41 - 01:49:42
慌亂恐懼驚嚇。

01:49:43 - 01:49:44
專有名詞叫做軟弱情緒。

01:49:45 - 01:49:50
出於這種慌亂、恐懼或驚嚇的軟弱情緒之下，是

01:49:51 - 01:49:52
防衛過當。

01:49:53 - 01:49:54
直接免除罪責的無罪。

01:49:55 - 01:49:56
這是德國法的規定。

01:49:57 - 01:49:59
許澤天老師把這個東西介紹進來臺灣。

01:49:59 - 01:49:59
所以我跟你講。

01:50:00 - 01:50:01
叫什麼軟弱情緒？

01:50:02 - 01:50:03
我們這樣說哈。

01:50:04 - 01:50:08
當你面臨到一件對你不好，對你有所打擊的事情的時候。

01:50:09 - 01:50:10
我們人有可能會出現兩種情緒。

01:50:11 - 01:50:13
一個叫強勢情緒。

01:50:13 - 01:50:15
憤怒，想攻擊對方，這個叫強勢情緒。

01:50:17 - 01:50:22
另外一個呢，悲傷、無助，想自己躲起來，那個叫軟弱情緒。

01:50:22 - 01:50:23
可以體會嗎？

01:50:23 - 01:50:23
應該可以喔。

01:50:24 - 01:50:25
我舉個例子來講。

01:50:27 - 01:50:32
我收集很多飛機模型，大概100架左右。

01:50:32 - 01:50:32
我家滿滿的飛機模型。

01:50:32 - 01:50:34
去年403地震的時候啊。

01:50:34 - 01:50:36
地震真的太大。

01:50:37 - 01:50:38
我家那邊震到五級，我住頂樓。

01:50:39 - 01:50:41
所以模型有一些掉下來壞掉，當下真的好難過。

01:50:42 - 01:50:45
有些是絕版，但還好啦，後來大部分有買回來了。

01:50:47 - 01:50:49
當下我看到模型倒在地上。

01:50:49 - 01:50:51
那種感覺，那個就叫軟弱情緒。

01:50:51 - 01:50:52
就覺得啊怎麼會這樣。

01:50:53 - 01:50:55
我都收集模型櫃的，竟然被地震搖出來。

01:50:55 - 01:50:58
那我能怎麼樣，地震嘛，天災嘛，我能怪誰。

01:50:58 - 01:51:00
所以當下那個很沮喪的想法。

01:51:00 - 01:51:02
那個就是所謂的軟弱情緒，知道嗎？

01:51:03 - 01:51:04
那我們試想另外一個情境喔。

01:51:05 - 01:51:09
那假設我的模型飛機掉下來不是被地震搖下來的。

01:51:09 - 01:51:15
而是有一個很討厭的小孩來我家玩模型飛機，每一架都當玩具那樣嚕，然後把我們飛機全部玩壞。

01:51:16 - 01:51:17
你覺得我遇到這種情境我會怎麼樣？

01:51:19 - 01:51:22
直覺上，會想把那個，會想把那個死小孩從樓上往下丟。

01:51:23 - 01:51:24
那個就叫強勢情緒。

01:51:25 - 01:51:26
可以感覺得出來吧。

01:51:26 - 01:51:28
地震要把我的模型飛機摔壞。

01:51:29 - 01:51:30
我難過。

01:51:30 - 01:51:32
我可能奈何不了，天災嘛，我能怎麼樣。

01:51:32 - 01:51:35
可是如果是一個屁孩來我家把我的模型飛機玩壞的話呢，超火大。

01:51:35 - 01:51:38
超想把這個屁孩從樓上往下丟，那個叫強勢情緒。

01:51:38 - 01:51:38
知道吧？

01:51:38 - 01:51:39
感覺不太一樣，應該可以體會吧。

01:51:39 - 01:51:43
日常生活應該有這種感覺，我們記得免除罪責的防衛過當，一定要怎麼樣，軟弱情緒。

01:51:44 - 01:51:44
這才值得同情。

01:51:44 - 01:51:44
知道嗎？

01:51:44 - 01:51:47
如果是強勢情緒的話，那就是一般防衛過當喔。

01:51:47 - 01:51:47
前面而有，就不能無罪了。

01:51:47 - 01:51:47
知道嗎？

01:51:47 - 01:51:50
所以這個東西叫做免除罪名。

01:52:00 - 01:52:00
這種防衛過當

01:52:00 - 01:52:00
客觀要件其實不是很重要

01:52:07 - 01:52:10
就不管是強度過當或延展過當都OK

01:52:11 - 01:52:11
重點是什麼

01:52:12 - 01:52:13
主觀上要人有情趣

01:52:13 - 01:52:14
就這樣

01:52:14 - 01:52:14
知道嗎

01:52:14 - 01:52:15
他沒有很難

01:52:17 - 01:52:20
好，所以這個東西我們就帶各位看到這邊

01:52:20 - 01:52:26
OK,那我們一樣,一個小時到了,我們就先休息一下,等一下呢,我們再來看主觀要件,還有後面的問題

01:52:37 - 01:52:38
好,我們再回來上課

01:52:38 - 01:52:43
來看到正當防衛最後一小段,關於它的主觀要件,155頁

01:52:44 - 01:52:51
在正當防衛當中啊,我們看完了客觀要件之後呢,最後來看到,來看到的是正當防衛的主觀要件

01:52:52 - 01:52:54
好,正當防衛的主觀要件啊,這裡說

01:52:55 - 01:52:56
防衛意思

01:52:56 - 01:52:57
防衛意思

01:52:57 - 01:52:59
來各位，防衛意思很簡單

01:53:00 - 01:53:05
就是要認知到有現在不法侵害的存在

01:53:05 - 01:53:11
所以我在體系圖，不是體系圖，我在表格當中寫違法性的主觀的時候

01:53:11 - 01:53:14
我都寫兩個字叫做認知

01:53:14 - 01:53:19
也就是行為人認知到有這個事實的存在

01:53:19 - 01:53:20
那就夠了

01:53:20 - 01:53:21
認知而已

01:53:21 - 01:53:22
知道嗎

01:53:22 - 01:53:23
只要有認知就夠了

01:53:23 - 01:53:26
要不要有防衛的意欲

01:53:26 - 01:53:27
不用

01:53:27 - 01:53:28
不需要

01:53:28 - 01:53:28
你說什麼意思

01:53:30 - 01:53:31
典型案例就是這樣的

01:53:32 - 01:53:33
我在

01:53:33 - 01:53:35
仇人的車子底盤裝了炸彈

01:53:35 - 01:53:36
我想炸他

01:53:37 - 01:53:38
裝完之後

01:53:38 - 01:53:39
我躲在遠處看

01:53:39 - 01:53:41
我就想看我仇人被炸死

01:53:41 - 01:53:43
結果我裝完這個炸彈之後啊

01:53:43 - 01:53:45
我發現竟然有小偷要來偷車

01:53:46 - 01:53:48
那我心想是我炸小偷幹什麼

01:53:48 - 01:53:50
我就不想炸小偷啊

01:53:50 - 01:53:51
我想看我仇人被炸死啊

01:53:51 - 01:53:55
於是我上去跟小偷發生扭打，不讓小偷偷這個車

01:53:56 - 01:53:57
這樣我這不是正當防衛

01:53:57 - 01:53:58
算喔

01:53:58 - 01:53:58
知道嗎

01:53:58 - 01:53:59
這算喔

01:53:59 - 01:54:00
雖然你

01:54:00 - 01:54:01
我的動機一點都不良善，我真正的目的不是為了保護這臺車，也不是為了保護車主。

01:54:06 - 01:54:10
可是我們知道現在法律的存在，有啊，我知道啊，知道的話就可以正當防衛了，至於行為人是不是真的有保護他人權益的意圖，重不重要，知道嗎？

01:54:15 - 01:54:20
所以這裡的話，我們講只要有認知就夠了，不需要有保護權力的意圖。

01:54:22 - 01:54:28
接著來，括號二，打架互毆跟正當防衛的關係。

01:54:29 - 01:54:35
打架互毆嘛，你一拳，我一腳，這種打架彼此打來打去互毆的情況，可不可以論正當防衛？

01:54:38 - 01:54:41
這個東西啊，牽涉到一個古老的實務見解。

01:54:42 - 01:54:47
你們知道嗎？過去的實務見解說，打架互毆的情況。

01:54:47 - 01:54:54
第一個，能證明誰先動手的話，先動手的一方，不可以正當防衛。

01:54:54 - 01:54:55
這個合理啊，對不對？

01:54:56 - 01:54:57
先動手的一方就是加害者啊。

01:54:58 - 01:55:00
所以先動手的一方，當然不可以正當防衛。

01:55:00 - 01:55:01
OK，這個合理。

01:55:02 - 01:55:05
好問題是，那如果不能證明誰先動手怎麼辦？

01:55:06 - 01:55:08
以前那個年代又沒有監視器。

01:55:09 - 01:55:11
所以不能證明誰先動手的話，我們怎麼辦呢？

01:55:12 - 01:55:17
你知道嗎？過去的說法是，不能證明誰先動手的話，你們都不準正當防衛。

01:55:18 - 01:55:19
就全部都選一項「互毆」罪，這是過去的說法。

01:55:22 - 01:55:25
這個說法學者一直罵他，說他違反罪疑惟輕。

01:55:27 - 01:55:27
你自己想一想不是嗎？

01:55:29 - 01:55:32
兩方都聲稱對方先動手，在場沒有監視器，也沒有第三人。

01:55:35 - 01:55:39
那在不能證明誰先動手的情況之下，原本照理說不是應該講罪疑惟輕，讓雙方都可以正當防衛嗎？

01:55:44 - 01:55:45
對不對？

01:55:45 - 01:55:45
照理說應該這樣子啊。

01:55:45 - 01:55:50
結果過去的食物,反而說啊,因為不能證明誰動手,所以你們都不準知道防衛。

01:55:51 - 01:55:53
那不是變罪為重,不合理。

01:55:54 - 01:55:59
所以學者會認為說,在不能證明誰先動手的情況之下,我們反而

01:56:00 - 01:56:06
應該要依照最以為原則,讓雙方啊都可以正當防衛,這個才是一個合理的做法。

01:56:07 - 01:56:10
好，這一題我們就看，這個東西，我們就看到這邊哈。

01:56:11 - 01:56:12
下面這一題啊。

01:56:13 - 01:56:16
我們，沒關係，我先講一個大概哈。

01:56:16 - 01:56:19
因為下面這一題會牽涉到緊急避難。

01:56:19 - 01:56:21
那我們馬上就要來講緊急避難了。

01:56:21 - 01:56:23
所以我這裡呢，先給同學一個觀念。

01:56:24 - 01:56:29
我們記得，正當防衛，只能對誰主張？

01:56:30 - 01:56:31
不法侵害著。

01:56:31 - 01:56:32
瞭解嗎？

01:56:32 - 01:56:34
對無辜的人，你不可能正當防衛喔。

01:56:34 - 01:56:38
正當防衛，只能對不法侵害著主張。

01:56:38 - 01:56:39
記得這件事。

01:56:40 - 01:56:43
而緊急避難呢，緊急避難沒有什麼限制。

01:56:43 - 01:56:43
瞭解嗎？

01:56:44 - 01:56:45
緊急避難並沒有這樣的限制。

01:56:45 - 01:56:50
所以記得，正當防衛只能對不法侵害著主張。

01:56:50 - 01:56:53
但緊急避難沒有這樣的限制。

01:56:54 - 01:56:58
所以如果為了正當防衛而犧牲無辜的話，

01:56:59 - 01:57:02
對於那個被犧牲的無辜者，只能論什麼呢？

01:57:03 - 01:57:04
緊急避難。

01:57:04 - 01:57:05
知道吧，只能論緊急避難。

01:57:06 - 01:57:06
比如說。

01:57:07 - 01:57:07
我被打。

01:57:09 - 01:57:09
假設。

01:57:10 - 01:57:12
我被路人甲打。

01:57:13 - 01:57:14
那我要反擊嘛。

01:57:15 - 01:57:16
我赤手空拳沒有東西啊。

01:57:16 - 01:57:18
突然看到一谷的LV雨傘。

01:57:19 - 01:57:21
啊我就搶一谷的LV雨傘來反擊。

01:57:21 - 01:57:23
結果把路伯擊退了,但這個雨傘也爛了。

01:57:24 - 01:57:27
這時候，我對一谷所犯的那個毀損罪，

01:57:28 - 01:57:29
只能用什麼？

01:57:29 - 01:57:30
緊急避難。

01:57:31 - 01:57:31
緊急避難。

01:57:32 - 01:57:33
因為他是無辜的。

01:57:33 - 01:57:34
他跟路伯又不是共謀者。

01:57:34 - 01:57:34
對不對，無辜的。

01:57:34 - 01:57:37
所以對無辜的人呢，只能主張緊急避難。

01:57:37 - 01:57:39
下面這一題大概就在講這個觀念，知道嗎，所以我們記得。

01:57:41 - 01:57:45
當行為人用第三人之物作為防衛工具的時候。

01:57:46 - 01:57:48
他就這個第三者之物的毀損。

01:57:48 - 01:57:50
只能論緊急避難。

01:57:50 - 01:57:52
沒有探討正當防衛的空間喔。

01:57:52 - 01:57:54
這個是我們講防衛行為跟第三人的關係。

01:57:56 - 01:57:59
我還記得我那年考東吳法律系的轉學考。

01:58:00 - 01:58:02
第三題的實力題就考這個東西，幾乎一模一樣。

01:58:04 - 01:58:09
為了要這個正當防衛，而搶路人的什麼枴杖還是什麼，好吧，我記得當時都考這個東西，印象深刻，所以記得啊。

01:58:11 - 01:58:14
對第三人只能主張緊急避難，緊急避難哦。

01:58:16 - 01:58:21
好，接下來我們來看到158頁，我們就來看到緊急避難的部分。

01:59:45 - 01:59:48
好，緊急避難跟正當防衛不一樣。

01:59:48 - 01:59:53
雖然他們條文規定的有點像，可是他們適用的情境是完全不一樣的。

01:59:54 - 01:59:56
正當防衛是針對誰？

01:59:57 - 02:00:00
針對歹徒，針對不法的人，我們才可以正當防衛。

02:00:00 - 02:00:00
走吧，我們等一下會講有些情況不是喔。

02:00:02 - 02:00:04
經常是一個無辜的對象。

02:00:04 - 02:00:06
我講一個典型的例子。

02:00:07 - 02:00:09
同學都知道我很喜歡豬。

02:00:09 - 02:00:11
我覺得豬很可愛，真的哦，我很喜歡豬。

02:00:12 - 02:00:18
那十幾年前有一次啊，我在我老家附近的山路慢跑。

02:00:18 - 02:00:21
我老家住在東湖，住在東湖。

02:00:21 - 02:00:23
我跑安泰街的山路。

02:00:23 - 02:00:24
老家要住在安泰街那邊。

02:00:25 - 02:00:27
那個山路啊，春天的時候，夏天不行啊，夏天太熱。

02:00:29 - 02:00:36
不然平常這種天氣沒有熱的時候，跑起來還不錯，空氣很好，跑跑山，還蠻喜歡去那邊慢跑的。

02:00:37 - 02:00:39
十幾年前有一次，那個時候我在唸研究所。

02:00:40 - 02:00:42
當時我去我家後面的山路慢跑。

02:00:43 - 02:00:44
跑到一半，我遇到豬。

02:00:45 - 02:00:48
真的啊，遇到豬，不是山豬喔，麝香豬那種。

02:00:48 - 02:00:53
但很肥很大，目測200公斤，就是跟那個肉柱一樣大，麝香豬。

02:00:54 - 02:00:56
我真的跑到一半遇到豬。

02:00:56 - 02:00:59
我超有點怎麼說啊，很驚喜很意外。

02:00:59 - 02:01:00
哇塞，跑到遇到豬。

02:01:01 - 02:01:02
我很喜歡豬啊。

02:01:02 - 02:01:04
所以我就過去給那隻豬拍照。

02:01:05 - 02:01:06
但我不敢摸牠。

02:01:06 - 02:01:08
因為我不知道牠有沒有兇性，我不敢摸牠。

02:01:08 - 02:01:10
我只敢對牠拍照。

02:01:10 - 02:01:12
看著牠左看右看，上看下看。

02:01:12 - 02:01:13
覺得這豬好可愛，我只敢拍照。

02:01:14 - 02:01:16
拍了幾張照之後，我離開了。

02:01:18 - 02:01:19
後來我再也沒有看到他。

02:01:20 - 02:01:21
後來他哪去了，我不知道。

02:01:22 - 02:01:24
是不是被送進什麼福生院之類的地方，我不清楚。

02:01:25 - 02:01:27
但就是隻看過他這麼一次。

02:01:28 - 02:01:29
當時我就在想。

02:01:30 - 02:01:33
因為我真的不敢摸牠，萬一牠如果有兇性怎麼辦？

02:01:34 - 02:01:38
那看起來很肥很大，我跟牠對決那沒有勝算。

02:01:38 - 02:01:39
所以我不趕快怎麼樣，我只趕拍完照我就走掉。

02:01:41 - 02:01:42
所以我當時在想的是，如果啊

02:01:44 - 02:01:45
我摸牠，結果呢？

02:01:48 - 02:01:49
他有野性。

02:01:49 - 02:01:51
他竟然要攻擊我。

02:01:52 - 02:01:53
假設你想啊，我跑到一半被豬追。

02:01:55 - 02:01:57
我為了躲避豬的攻擊，所以呢

02:01:58 - 02:02:00
我跳到路人身上。

02:02:00 - 02:02:04
的庭院當中,跳到附近鄰居的別墅的庭院當中去做躲避。

02:02:04 - 02:02:07
緊急的情況就是典型的緊急避難。

02:02:07 - 02:02:12
為了要躲避豬的攻擊,所以進入別人住宅。

02:02:12 - 02:02:16
我去別人住宅的庭院,這個叫做侵入住居。

02:02:17 - 02:02:21
而為了躲避豬的攻擊呢,這就叫做緊急避難，阻卻違法。

02:02:21 - 02:02:24
所以緊急避難呢,要處理的通常是這樣的案例。

02:02:24 - 02:02:32
所以你會發現,在緊急避難當中,那個被避難行為所犧牲的對象。

02:02:32 - 02:02:32
經常是無辜的。

02:02:32 - 02:02:33
你會發現。

02:02:33 - 02:02:36
這個對啊,對那個路人來說幹他什麼事。

02:02:37 - 02:02:40
就對那個鄰居來講，幹他什麼事，豬又不是他養的，對不對？

02:02:40 - 02:02:44
還有我剛剛講的例子也是啊，那流氓要打我，所以我反擊拿我的遺產去反擊。

02:02:45 - 02:02:46
對他來說幹他什麼事啊。

02:02:46 - 02:02:47
他們又不是共謀者，對不對？

02:02:48 - 02:02:52
所以緊急避難為什麼可以作為一種阻卻違法事由。

02:02:53 - 02:02:54
其實會有討論的空間。

02:02:55 - 02:02:57
它不像正當防衛那麼理所當然。

02:02:57 - 02:02:57
因為你想嘛。

02:02:59 - 02:03:00
正當防衛當中，

02:03:00 - 02:03:02
被防衛的人是怎麼樣？

02:03:04 - 02:03:06
他就是侵害的來源，他自己有不法在先對不對？

02:03:06 - 02:03:10
所以正當防衛作為一種阻卻違法事由，應該不會有什麼反對。

02:03:10 - 02:03:12
可是緊急避難不太一樣喔。

02:03:13 - 02:03:17
緊急避難當中被犧牲的對象，幾乎都是無辜的。

02:03:17 - 02:03:19
於是有一個比較哲學的問題就來了。

02:03:20 - 02:03:21
那那為什麼那個人要被犧牲啊?

02:03:22 - 02:03:23
你們想哦,就我剛剛講這個躲避豬之的案例來說。

02:03:27 - 02:03:31
假設這個別墅的主人,他是一個很極端的個人主義者。

02:03:31 - 02:03:34
他會說你被豬追幹我什麼事。

02:03:35 - 02:03:36
豬又不是我養的。

02:03:37 - 02:03:38
豬也不是我放的。

02:03:38 - 02:03:41
豬會攻擊你，跟我一點關係都沒有。

02:03:41 - 02:03:45
而且你也不是我什麼依照契約或什麼關係富有保護義務的人。

02:03:46 - 02:03:48
那你被豬撞死，那是你的事啊，我為什麼要救你？

02:03:50 - 02:03:51
他如果這樣講，你能怎麼回應？

02:03:53 - 02:03:55
好像也沒有錯，無法反駁，對不對？

02:03:55 - 02:03:57
雖然覺得這樣講怎麼那麼冷血，可是邏輯上無法反駁啊。

02:03:57 - 02:03:59
對啊，沒有錯啊。

02:04:00 - 02:04:02
我跟這個路人的住宅，

02:04:02 - 02:04:03
我跟這個民宅的主人，

02:04:03 - 02:04:04
非親非故的。

02:04:05 - 02:04:06
祝融會光臨，我不是他害的啊。

02:04:07 - 02:04:08
啊，我對他對我來說，

02:04:08 - 02:04:10
他也不是什麼對我富有保護義務的人啊。

02:04:11 - 02:04:12
那他幹嘛救我？

02:04:12 - 02:04:12
對吧？

02:04:12 - 02:04:14
所以為什麼緊急避難可以主張卻違法？

02:04:15 - 02:04:16
為什麼無辜的人要被犧牲？

02:04:17 - 02:04:18
學理上提出一種說法啦，

02:04:18 - 02:04:19
叫社會連帶。

02:04:19 - 02:04:19
什麼意思？

02:04:20 - 02:04:20
意思就是說，

02:04:21 - 02:04:22
我們社會當中的人，

02:04:23 - 02:04:26
並不是每個人都完全獨立像這種原子式的存在，

02:04:26 - 02:04:26
不是。

02:04:27 - 02:04:28
社會連帶的想法就是，

02:04:29 - 02:04:33
我們社會上的每個人應該發揮一點互助的精神。

02:04:34 - 02:04:35
當有其他人遇到危險的時候，

02:04:36 - 02:04:38
我們就犧牲一點利益去幫助他。

02:04:39 - 02:04:41
這樣如果合作下去，

02:04:41 - 02:04:43
如果以這個社會連帶的觀點合作下去的話,

02:04:43 - 02:04:45
別人遇到危險,

02:04:45 - 02:04:47
雖然他跟我無關沒有錯,

02:04:47 - 02:04:49
可是我犧牲一點點利益去救他,

02:04:49 - 02:04:50
如果每個人都這樣想,

02:04:51 - 02:04:51
對大家會更好，

02:04:52 - 02:04:52
知道嗎？

02:04:52 - 02:04:53
這是背後的想法，

02:04:53 - 02:04:56
所以這是緊急避難背後的法理基礎，

02:04:56 - 02:04:57
叫做社會連帶。

02:04:58 - 02:04:58
那我剛剛說啊,

02:04:59 - 02:05:00
在緊急避難當中,

02:05:01 - 02:05:03
被避難行為所犧牲的對象,

02:05:03 - 02:05:04
通常,

02:05:05 - 02:05:06
通常是一個無辜的對象。

02:05:07 - 02:05:09
但我強調那是通常而已,

02:05:09 - 02:05:10
不是必然。

02:05:11 - 02:05:13
因為有些緊急避難當中被犧牲的對象,

02:05:14 - 02:05:15
其實並不無辜。

02:05:15 - 02:05:16
所以你來看這個體系圖。

02:05:17 - 02:05:19
緊急避難分兩種，

02:05:19 - 02:05:20
攻擊型跟防禦型。

02:05:22 - 02:05:24
通常那種犧牲無辜的緊急避難，

02:05:25 - 02:05:28
就是我們這裡所說的攻擊型。

02:05:28 - 02:05:30
以考試的角度來講，

02:05:30 - 02:05:31
考到緊急避難，

02:05:31 - 02:05:33
九成都是攻擊型。

02:05:34 - 02:05:35
但你不要忘記喔，

02:05:35 - 02:05:37
緊急避難有一種叫防禦型喔。

02:05:38 - 02:05:40
防禦型的緊急避難，

02:05:40 - 02:05:43
被攻擊的對象並不無辜喔。

02:05:44 - 02:05:45
他就是危難的來源喔，

02:05:45 - 02:05:45
知道嗎？

02:05:46 - 02:05:46
你想喔。

02:05:48 - 02:05:49
你去爬山。

02:05:49 - 02:05:51
你被臺灣黑熊盯上了。

02:05:52 - 02:05:53
熊要過來吃你，

02:05:53 - 02:05:55
於是你拿獵槍打死那隻熊。

02:05:56 - 02:05:57
這時候被犧牲的對象是誰？

02:05:58 - 02:05:58
熊嘛。

02:05:59 - 02:05:59
熊是什麼？

02:06:00 - 02:06:01
危難的來源啊，

02:06:01 - 02:06:02
他不是全然無辜的，

02:06:02 - 02:06:03
對不對？

02:06:03 - 02:06:04
但這個依然叫什麼呢？

02:06:04 - 02:06:05
依然叫緊急避難啊,

02:06:05 - 02:06:06
所以我們記得喔,

02:06:06 - 02:06:08
緊急避難不見得一定是對無辜的哦,

02:06:09 - 02:06:10
有些緊急避難是怎麼樣?

02:06:11 - 02:06:12
針對危難來源,

02:06:12 - 02:06:13
那個叫防禦性，

02:06:13 - 02:06:15
懂嗎？這個我們等一下會看到，

02:06:15 - 02:06:18
所以你不要去記說緊急避難是正對正，

02:06:18 - 02:06:19
不見得啦，

02:06:19 - 02:06:20
有防禦性的啦。

02:06:20 - 02:06:21
不見得每個都具攻擊性喔。

02:06:22 - 02:06:24
好，160頁，我們往下看。

02:06:26 - 02:06:29
在緊急避難這邊啊，一樣，我們來看到避難的前提。

02:06:30 - 02:06:33
避難前提的話，第一個叫做急迫危難。

02:06:34 - 02:06:35
或者精確來說，

02:06:35 - 02:06:41
條文講生命、身體、自由、財產，這四種法益的急迫危難。

02:06:42 - 02:06:42
四個喔。

02:06:42 - 02:06:46
生命、身體、自由、財產，這四種法益的急迫危難。

02:06:47 - 02:06:53
這裡會有一個爭執是，生命、身體、自由、財產這四種法益，

02:06:53 - 02:06:58
它到底是例示性的規定，或是列舉性的規定。

02:06:59 - 02:07:01
我想我們學過法律的都知道，

02:07:02 - 02:07:05
例示的意思就是舉例，不以這些為限。

02:07:05 - 02:07:09
而列舉的意思就是就這些了，其他都不算。

02:07:10 - 02:07:11
這個是我們講例示跟列舉的意思。

02:07:12 - 02:07:15
像我們學憲法那個第七條的平等權的規定，

02:07:15 - 02:07:22
他說中華民國人民無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。

02:07:24 - 02:07:27
所以他列的那些男女、宗教、種族、階級、黨派，

02:07:28 - 02:07:29
那個是例示還是列舉？

02:07:29 - 02:07:29
例示嘛，

02:07:30 - 02:07:31
不以這些為限嘛。

02:07:31 - 02:07:33
因為只要差別待遇本身不合理,

02:07:33 - 02:07:34
那還是構成平等權的侵害啊,

02:07:34 - 02:07:35
對不對?

02:07:35 - 02:07:37
比如說有個大學他禁止同性戀者入學,

02:07:37 - 02:07:38
那還是侵害平等權啊,

02:07:38 - 02:07:39
對不對？

02:07:39 - 02:07:42
所以那個東西叫列舉，那個東西叫例示，

02:07:42 - 02:07:43
那個不叫列舉。

02:07:43 - 02:07:45
那緊急避難是例示還列舉？

02:07:46 - 02:07:49
他條文寫生命、身體、自由、財產。

02:07:50 - 02:07:51
個人法益不止這些。

02:07:52 - 02:07:54
個人法益除了生命、身體、自由、財產之外還有什麼？

02:07:54 - 02:07:56
還有隱私跟名譽啊。

02:07:56 - 02:07:58
他沒有寫隱私跟名譽啊，

02:07:58 - 02:07:58
對不對？

02:07:58 - 02:08:00
所以其實這個爭執

02:08:00 - 02:08:01
在於說,

02:08:01 - 02:08:04
那對於隱私或對於名譽權益,

02:08:04 - 02:08:07
有沒有緊急避難的空間。

02:08:08 - 02:08:09
在爭執這個東西,

02:08:09 - 02:08:09
你知道嗎？

02:08:10 - 02:08:12
對於隱私或者對於名譽的法益,

02:08:12 - 02:08:15
有沒有緊急避難的空間？

02:08:18 - 02:08:19
有個例子是這樣，

02:08:19 - 02:08:21
多年前李聖傑老師的例子。

02:08:22 - 02:08:22
他說啊,

02:08:23 - 02:08:25
有人在網咖消費。

02:08:25 - 02:08:27
網咖同學知道吧,現在幾乎不見了,

02:08:27 - 02:08:31
就是一個地方讓大家可以打電腦的地方,網咖,

02:08:31 - 02:08:32
有人在網咖消費。

02:08:32 - 02:08:35
這個人發現，網咖隔壁桌的客人，

02:08:35 - 02:08:41
在網路上正要發一篇妨害他人名譽的文章。

02:08:42 - 02:08:45
眼看著這篇文章就要寫完送出了。

02:08:46 - 02:08:47
這個鄰座見義勇為的客人，

02:08:48 - 02:08:50
不希望第三人的名譽受損。

02:08:50 - 02:08:56
所以呢,他趕緊把這臺電腦的網路線剪斷,讓這個文章無法散播出去。

02:08:57 - 02:08:59
李聖傑老師舉這個例子。

02:09:40 - 02:09:41
這怎麼樣呢？

02:09:42 - 02:09:44
為了維護第三人的名譽,

02:09:45 - 02:09:47
而攻擊誰？攻擊網咖的財產。

02:09:47 - 02:09:49
對不對？網咖是很典型一個避難的案例。

02:09:49 - 02:09:51
可是名譽它不是條文所列的法益啊。

02:09:51 - 02:09:53
所以這個案例可不可以解避難，會有討論的空間。

02:09:54 - 02:09:56
當然這個例子我會覺得它其實有點怪啦。

02:09:57 - 02:09:59
不是法律面怪，是事實面怪。

02:10:00 - 02:10:02
或者是保護某些國家社會法益的話，有沒有緊急避難的空間呢？

02:10:04 - 02:10:05
所以我說，兩種說法都有。

02:10:05 - 02:10:07
有人說他是一個例示性的規定。

02:10:08 - 02:10:09
說其他法益也OK。

02:10:09 - 02:10:11
但有人說他是列舉性的規定，說這四種危險，都有人講。

02:10:14 - 02:10:18
我說了，我比較支持列舉規定的看法。

02:10:19 - 02:10:20
我個人的立場，我講一下我的理由。

02:10:20 - 02:10:23
我覺得列舉規定的說法比較合理，為什麼？

02:10:24 - 02:10:25
體系解釋。

02:10:26 - 02:10:27
你看23跟24就知道。

02:10:29 - 02:10:30
他寫什麼？

02:10:31 - 02:10:34
為保護自己或第三人權益的行為。

02:10:34 - 02:10:36
有沒有？他只寫權益。

02:10:37 - 02:10:39
那明明就在下一個條文。

02:10:39 - 02:10:41
為什麼不寫權益就好？

02:10:41 - 02:10:43
而是生命、身體、自由、財產。

02:10:44 - 02:10:45
立法就有意的區分，對吧？

02:10:45 - 02:10:47
那立法者區分的背後的想法是什麼呢？

02:10:48 - 02:10:50
因為緊急避難經常會犧牲無辜。

02:10:51 - 02:10:53
所以法益不能放寬。

02:10:53 - 02:10:57
放太快的話變成說只要你有一個更大的利益要保護，那無辜的人就要被犧牲。

02:10:58 - 02:11:01
這樣可能會讓社會連帶為擴大的太大，知道嗎？

02:11:01 - 02:11:04
所以立法者才會用法益的方式來做限定。

02:11:04 - 02:11:07
不要讓無辜的人一天到晚被犧牲，瞭解吧？

02:11:07 - 02:11:07
好。

02:11:07 - 02:11:09
所以我透過體系解釋的方式呢,

02:11:09 - 02:11:13
我會覺得列舉規定說應該比較合理。

02:11:13 - 02:11:15
生命、身體、自由、財產這四種才算。

02:11:16 - 02:11:20
所以像名譽、隱私或其他國家社會法益，不可以緊急避難哦。

02:11:22 - 02:11:22
好。

02:11:22 - 02:11:23
前者下面，括號二。

02:11:25 - 02:11:29
要有生命、身體、自由、財產上的什麼呢？要有急迫危難。

02:11:30 - 02:11:32
我們這裡講，什麼叫急迫危難？

02:11:32 - 02:11:33
急迫危難。

02:11:33 - 02:11:36
急迫危難分成下面這兩種不同的情形。

02:11:37 - 02:11:37
第一個。

02:11:38 - 02:11:38
第一個。

02:11:38 - 02:11:41
叫做迫在眼前的危險。

02:11:42 - 02:11:43
這個沒有疑問。

02:11:43 - 02:11:45
臺灣黑熊朝你追得上來。

02:11:45 - 02:11:47
山豬朝你追上來。

02:11:47 - 02:11:50
這一種的話，你的生命有一個迫在眼前的危險。

02:11:51 - 02:11:52
這一種東西叫做急迫危難。

02:11:52 - 02:11:54
迫在眼前的，OK，這個沒有問題。

02:11:56 - 02:11:57
除此之外，還有一種東西算不算急迫？

02:12:00 - 02:12:04
危難，一般認為算，沒有問題，這個叫什麼呢？持續性的危險。

02:12:06 - 02:12:12
這個東西啊，會跟我們剛剛上半堂課講正當防衛的有效防衛理論做一個結合，怎麼說呢？

02:12:14 - 02:12:16
所謂持續性的危險，定義像是這樣。

02:12:17 - 02:12:20
這個東西啊，將來它是個未爆彈。

02:12:21 - 02:12:23
什麼時候爆，不知道。

02:12:23 - 02:12:25
會不會爆，我們也不知道。

02:12:26 - 02:12:29
但它有高度的可能性會變成實害。

02:12:30 - 02:12:32
只是什麼時候，威力多大，我們不知道。

02:12:33 - 02:12:34
這個叫做持續性的危險。

02:12:35 - 02:12:39
比如說我們講地震，傾斜的房屋。

02:12:40 - 02:12:43
我們講喔，地震之後傾斜的房屋。

02:12:44 - 02:12:46
它到底會不會倒，不知道。

02:12:47 - 02:12:50
如果會倒，什麼時候倒，也不知道。

02:12:51 - 02:12:54
好，那如果真的會倒，倒塌會形成多大災害，我們還是不知道。

02:12:55 - 02:12:56
但它就是有可能會倒。

02:12:57 - 02:12:57
持續性的危險。

02:12:58 - 02:13:00
反過來說，他們可能不會倒。

02:13:00 - 02:13:01
也有可能啦，這怎麼說，對不對？

02:13:01 - 02:13:02
所以我們說。

02:13:02 - 02:13:05
如果你家附近遇到地震，旁邊的高樓傾斜了。

02:13:08 - 02:13:10
你希望對方拆除。

02:13:10 - 02:13:11
對方不拆，甚至對方說我才不要拆。

02:13:13 - 02:13:17
說不定這個會是將來臺灣的比薩斜塔，成為觀光聖地，我才不要拆。

02:13:18 - 02:13:20
可是你就很怕，萬一倒了怎麼辦？

02:13:20 - 02:13:22
於是你不怪手把那個房子拆掉。

02:13:22 - 02:13:23
這時候就是什麼呢?

02:13:23 - 02:13:27
對於持續性危險的緊急避難,OK嗎?所以這個是我們講哦,持續性

02:13:30 - 02:13:30
的危險。

02:13:31 - 02:13:35
所以啊,持續性的危險,確實也可以作為緊急避難的危難。

02:13:37 - 02:13:37
確實可以哦。

02:13:38 - 02:13:38
好。

02:13:39 - 02:13:41
回到我們剛剛講的家暴殺夫案例。

02:13:43 - 02:13:45
在家暴而殺夫的案例當中。

02:13:45 - 02:13:51
太太趁著熟睡的先生，熟睡且酒醉的先生，他就是失去意識的時候呢。

02:13:52 - 02:13:54
太太持刀捅死這個先生。

02:13:55 - 02:13:55
我們剛剛講。

02:13:56 - 02:13:59
在正當防衛的部分，依照多數的看法。

02:14:00 - 02:14:01
這個案例有沒有正當防衛的空間？

02:14:02 - 02:14:02
沒有啊。

02:14:03 - 02:14:03
為什麼？

02:14:04 - 02:14:09
因為千身熟睡的狀態下，他沒有在侵害嘛。

02:14:09 - 02:14:11
對不對？除非你才有有效防衛說，

02:14:11 - 02:14:19
否則如果照這個著手標準或預備最後階段說的話，這個不是現在侵害啊，所以沒機會正當防衛。

02:14:20 - 02:14:21
可是學者說了，

02:14:22 - 02:14:24
這種案例雖然沒有機會正當防衛。

02:14:25 - 02:14:30
但是我們有機會轉個彎,讓行為人主張緊急避難。

02:14:30 - 02:14:32
這就是什麼？持續性的危險。

02:14:33 - 02:14:33
瞭解吧？

02:14:33 - 02:14:34
這就是持續的危險。

02:14:35 - 02:14:40
去年好像東吳轉學考跟輔大轉學考都考這個東西，持續性的危險。

02:14:40 - 02:14:42
所以各位啊，你們想，

02:14:43 - 02:14:50
在這一種家暴而殺夫案件當中，通說認為它不構成正當防衛的現在侵害，

02:14:51 - 02:14:58
但是可以轉個彎變成緊急避難當中的持續性的危險，而成為可避免的危難。

02:14:59 - 02:15:40
通說這樣講的，

02:15:41 - 02:15:42
可是啊，請同學你要注意喔！

02:15:43 - 02:15:50
這裡它可以構成緊急避難當中的持續性的危險，而構成急迫的危難沒有錯。

02:15:50 - 02:15:53
可是請同學你一定要注意一件事。

02:15:53 - 02:15:55
避難手段不見得會過。

02:15:56 - 02:15:57
你知道為什麼嗎？

02:15:57 - 02:15:59
因為緊急避難條文寫要不得已。

02:16:00 - 02:16:01
否則一般的情況

02:16:01 - 02:16:02
被家暴的人可以逃跑

02:16:02 - 02:16:03
可以報警

02:16:03 - 02:16:05
他並不是隻能把他老公殺掉

02:16:05 - 02:16:07
所以這種情形的話

02:16:08 - 02:16:10
雖然他處於緊急病況的危難中,

02:16:11 - 02:16:11
但是怎麼樣?

02:16:12 - 02:16:14
替代手段往往會過不去,

02:16:14 - 02:16:15
OK哦。

02:16:17 - 02:16:17
好,

02:16:17 - 02:16:19
所以這個是我們講急迫危難。

02:16:19 - 02:16:20
再來,

02:16:20 - 02:16:22
急迫危難當中的危難,

02:16:23 - 02:16:24
我們要排除一種東西,

02:16:25 - 02:16:26
叫做合法行為。

02:16:27 - 02:16:27
記得喔，

02:16:28 - 02:16:32
合法行為不是緊急避難的對象。

02:16:33 - 02:16:34
記得這件事喔，

02:16:34 - 02:16:36
合法行為不是緊急避難的對象。

02:16:37 - 02:16:37
所以我們說啊，

02:16:38 - 02:16:42
合法行為的相對人不能正當防衛。

02:16:42 - 02:16:43
你酒駕被警察抓,

02:16:44 - 02:16:44
你不能說揍警察,

02:16:45 - 02:16:45
說我要正當防衛,

02:16:45 - 02:16:46
不行。

02:16:47 - 02:16:49
可不可以轉個彎說我要緊急避難？

02:16:49 - 02:16:50
廢話當然也不行啊。

02:16:51 - 02:16:53
合法行為的相對人就要忍受。

02:16:53 - 02:16:54
如果他可以緊急避難，

02:16:55 - 02:16:56
那不是形成法律秩序的矛盾？

02:16:56 - 02:16:57
對不對？

02:16:57 - 02:16:58
所以合法行為的相對人呢，

02:16:59 - 02:17:01
當然也不能緊急避難喔。

02:18:00 - 02:18:04
緊急避難的必要性跟正當防衛不一樣喔。

02:18:05 - 02:18:07
正當防衛要不要考慮逃跑跟報警？

02:18:07 - 02:18:08
不用。

02:18:09 - 02:18:10
可是緊急避難要。

02:18:11 - 02:18:13
緊急避難條文寫不得已。

02:18:13 - 02:18:14
再講一次不得已什麼意思？

02:18:15 - 02:18:17
除此手段，別無他法。

02:18:18 - 02:18:19
瞭解吧，除此手段別無他法。

02:18:20 - 02:18:20
所以各位啊。

02:18:22 - 02:18:29
在緊急避難的案例當中，如果行為人可以用逃跑、報警之類的手段來避免危難的話。

02:18:29 - 02:18:32
他是不能主張緊急避難的喔。

02:18:33 - 02:18:33
所以喔。

02:18:35 - 02:18:39
如果以我剛剛被山豬追的案例來講。

02:18:40 - 02:18:41
被豬追，假設被豬追。

02:18:42 - 02:18:47
正常來說，被豬追之後，跳到附近鄰人的庭院去躲避。

02:18:48 - 02:18:49
OK，合理，對不對？

02:18:49 - 02:18:55
可是如果後來發現，當時正好有一臺計程車路過。

02:18:56 - 02:19:00
那我是否可以選擇坐上計程車，請司機快點走？

02:19:00 - 02:19:02
我幹嘛去侵入人家家？

02:19:02 - 02:19:03
這時候可不可以解除避難？

02:19:03 - 02:19:05
不行喔，這便過當喔，知道吧？

02:19:05 - 02:19:07
所以必須要除此手段別無他法，所以我剛才會說。

02:19:08 - 02:19:12
被家暴的太太殺死家暴她的先生。

02:19:12 - 02:19:16
雖然說這個叫持續性的危險而構成急迫危難，沒有錯。

02:19:17 - 02:19:18
可是什麼地方會出問題？

02:19:18 - 02:19:19
手段啊。

02:19:19 - 02:19:21
誰說一定要把人殺掉，對不對？

02:19:21 - 02:19:22
手段會出問題喔。

02:19:24 - 02:19:24
好。

02:19:24 - 02:19:25
接著我們再往下看。

02:19:27 - 02:19:28
接下來啊，第二點的下面。

02:19:29 - 02:19:30
我們說啊，這個

02:19:30 - 02:19:31
除此手段別無他法。

02:19:32 - 02:19:33
所以像下面這個案例啊。

02:19:33 - 02:19:36
你要把危急的傷患送醫。

02:19:36 - 02:19:40
你強押路人,強取路人的汽車,去把傷患送醫。

02:19:40 - 02:19:41
不行。

02:19:41 - 02:19:43
你可以打119啊，為什麼要去搶人家的車呢，對不對？

02:19:43 - 02:19:46
並不是最後的手段喔，還有像這個案例。

02:19:48 - 02:19:52
被暴力討債的人，侵佔公款而償債，可不可以解避難？

02:19:53 - 02:19:54
不可以。

02:19:55 - 02:19:57
因為一般的說法，被暴力討債的人，

02:19:57 - 02:19:59
或許可以報警，或許可以逃跑。

02:20:00 - 02:20:00
或者是另外借錢，這個侵佔公款啊，當然不是一個最後目的的手段。

02:20:05 - 02:20:06
還有啊，管好三。

02:20:07 - 02:20:14
A被B的惡權攻擊的時候，不搶B的遺產反擊，反而拿C的古董花瓶反擊，這也不行。

02:20:15 - 02:20:18
這並不是除此手段，別無他法。

02:20:18 - 02:20:21
所以緊急避難非常的嚴格。

02:20:21 - 02:20:26
在緊急避難當中，必須要怎麼樣，真的喔，除此手段別無他法，這才可以喔。

02:20:28 - 02:20:30
所以我這邊連接到一個。

02:20:30 - 02:20:31
外解釋。

02:20:31 - 02:20:34
被別人的動物攻擊，比如說你走在路上。

02:20:35 - 02:20:37
被比特犬攻擊。

02:20:39 - 02:20:40
比特犬衝過來要咬你。

02:20:41 - 02:20:44
而這個比特犬，主人沒有繫牽繩。

02:20:44 - 02:20:47
而且也沒有帶嘴套。

02:20:47 - 02:20:49
不對，那個不叫口罩，那個叫嘴套。

02:20:49 - 02:20:54
這一隻比特犬衝擊完的時候，主人沒有繫繩，也沒有帶嘴套。

02:20:55 - 02:20:56
狗就衝過來要咬你。

02:20:57 - 02:20:59
你反擊，打死這隻比特犬。

02:20:59 - 02:21:01
我們說優先適用什麼？

02:21:01 - 02:21:02
正當防衛，對不對？

02:21:02 - 02:21:04
因為這個是他人的故事，不法侵害嘛。

02:21:04 - 02:21:07
所以這樣的行為，我們可以使用正當防衛。

02:21:08 - 02:21:11
這種案例，你不要捨近求遠去用緊急避難喔，你知道為什麼嗎？

02:21:12 - 02:21:15
這種案例，如果你去適用緊急避難的話，緊急避難要不得已。

02:21:17 - 02:21:20
那不得已的話，這時候法官會質疑你啊，你要主張緊急避難對不對？

02:21:21 - 02:21:21
那即便他不得已。

02:21:22 - 02:21:25
旁邊有電線桿啊，你怎麼沒有試著爬上去？

02:21:25 - 02:21:29
旁邊有樹啊，你爬上去的話就不會被咬了，你為什麼要去把人家的狗打死呢？

02:21:30 - 02:21:31
會變成這樣，你知道嗎？

02:21:31 - 02:21:33
所以能用正當防衛的，就優先用喔。

02:21:34 - 02:21:37
緊急避難這個要件更嚴苛,對情不利,知道嗎?

02:21:39 - 02:21:39
好,請起來。

02:21:39 - 02:21:40
謝謝。

02:21:41 - 02:21:43
避難行為啊,兩大謝謝。

02:21:43 - 02:21:46
第一個是公務或業務上的謝謝,好,24條第二項說。

02:21:49 - 02:21:52
前項避免自己為難的規定，在公務或業務上有特別義務者，不適用之。

02:21:57 - 02:22:00
同學可能會想，什麼叫公務或業務？

02:22:00 - 02:22:00
有特別性質的人。

02:22:02 - 02:22:03
請警消保全，就是弄人員，走嗎，最常見的。

02:22:06 - 02:22:08
想像上會不會有其他人，暫時想不到，但最常見的就警消保全。

02:22:11 - 02:22:14
所以你們想喔，有個人第一天當警察了。

02:22:15 - 02:22:17
考上警特啊，去警專受訓的一年，高興啊。

02:22:18 - 02:22:20
第一天掛一線三，第一天當警察。

02:22:20 - 02:22:22
結果當警察第一天，

02:22:24 - 02:22:25
遇到警匪槍戰。

02:22:26 - 02:22:30
而且歹徒的火力非常的強大，有衝鋒槍一種。

02:22:30 - 02:22:32
第一天當警察，嚇都嚇死了。

02:22:32 - 02:22:33
腿都軟了。

02:22:34 - 02:22:36
趕快跑到民家的後陽臺躲一躲。

02:22:36 - 02:22:40
還拜託民家主人，拜託讓我躲一下，第一天當警察超怕，收留我好不好。

02:22:41 - 02:22:41
不可以。

02:22:42 - 02:22:46
這種情況呢,叫做公務上有特別義務,就不能適用緊急避難的規定了。

02:22:47 - 02:22:48
業務上也是喔。

02:22:49 - 02:22:52
銀樓的保全發現有小偷入侵。

02:22:53 - 02:22:54
保全可不能說啊。

02:22:54 - 02:22:58
這個小偷看起來有刀，他攻擊我怎麼辦？

02:22:58 - 02:23:02
所以保全放任小偷亂偷，然後把小偷放走，不可以喔。

02:23:02 - 02:23:05
保全的義務就是擊退這個小偷。

02:23:05 - 02:23:07
或至少協助防竊。

02:23:07 - 02:23:09
保全啊，就不能主張緊急避難。

02:23:10 - 02:23:10
好。

02:23:10 - 02:23:11
所以這個規定呢。

02:23:11 - 02:23:13
主要啊，就是用在這兩大類的人身上。

02:23:13 - 02:23:15
警消還有保全，最常見的這種人。

02:23:18 - 02:23:19
企業主，我再舉一個例子。

02:23:20 - 02:23:22
各位想一下，我以下舉的案例。

02:23:22 - 02:23:25
有沒有適用緊急避難的空間？

02:23:27 - 02:23:27
好，你們想喔。

02:23:28 - 02:23:30
在醫院的手術房當中。

02:23:30 - 02:23:30
房當中。

02:23:30 - 02:23:33
一場全身麻醉的手術正在進行。

02:23:35 - 02:23:35
進行到一半。

02:23:36 - 02:23:37
手術房發生了火災。

02:23:38 - 02:23:40
而且火勢非常的猛烈。

02:23:41 - 02:23:44
這時候醫護可不可以就直接跑掉？

02:23:44 - 02:23:47
放任這個病患在手術房當中被嗆死或燒死。

02:23:48 - 02:23:49
我跟各位說可以。

02:23:50 - 02:23:51
當然可以，為什麼？

02:23:51 - 02:23:56
我常跟各位講一個觀念，法律不會要求人民履行無效的義務。

02:23:57 - 02:23:57
你們想喔。

02:23:58 - 02:24:00
醫護對於手術中的病人，

02:24:00 - 02:24:02
人權對生命的身體安全，確實有保護的義務，沒有錯。

02:24:03 - 02:24:07
可是問題在於這是一場全身麻醉、開腸剖肚的手術。

02:24:08 - 02:24:11
這樣的情況，如果你說醫護不準先走，

02:24:11 - 02:24:14
那結局是什麼呢？就是大家留下來一起死。

02:24:15 - 02:24:16
那沒有意義，知道吧。

02:24:16 - 02:24:19
所以這種情況我就說嘛，你要醫護不準走，幹什麼的。

02:24:21 - 02:24:24
他難道留下來就救得了人嗎？不，留下來不是大家一起死嗎？

02:24:24 - 02:24:26
所以這種情況，醫護是可以走的喔。

02:24:27 - 02:24:27
知道吧。

02:24:27 - 02:24:30
所以我們翻過來，括號二這邊有講。

02:24:30 - 02:24:34
因為法律不會要求人民履行無效的義務。

02:24:34 - 02:24:37
所以在這種特殊的情況呢，醫護當然可以走。

02:24:37 - 02:24:40
我們不會要求他們留下來一起死，當然不會喔。

02:24:41 - 02:24:41
好。

02:24:42 - 02:24:43
再來下面第二點。

02:24:43 - 02:24:45
自找危難。

02:24:48 - 02:24:51
自找危難這種東西，可不可以主張緊急避難？

02:24:51 - 02:24:53
我跟你們講，自找危難的概念喔，

02:24:53 - 02:24:57
跟我們前面所看到的挑唆防衛超像。

02:24:58 - 02:24:59
自招危難什麼意思？

02:25:01 - 02:25:06
之所以需要緊急避難，是可歸責於避難者所導致的。

02:25:06 - 02:25:08
這個叫做自招危難，知道嗎？

02:25:08 - 02:25:11
可歸責於避難者所導致的，這個叫做自招危難。

02:25:12 - 02:25:14
按名詞注意一下喔。

02:25:14 - 02:25:17
正當防衛那邊我們叫做挑唆防衛。

02:25:17 - 02:25:20
緊急避難，我們叫做自招危難。

02:25:20 - 02:25:24
你不要寫錯，寫成什麼挑唆避難。

02:25:24 - 02:25:25
自招防衛，沒有。

02:25:25 - 02:25:28
他就是自招危難跟挑唆防衛，好。

02:25:29 - 02:25:30
我們現在。

02:25:30 - 02:25:32
自招危難，剛剛我們說啊。

02:25:33 - 02:25:38
之所以需要緊急避難，是可歸責於避難者所導致的。

02:25:38 - 02:25:40
這個叫做自招危難。

02:25:41 - 02:25:45
好，那我們會把自招危難，分成這兩大類，各位你看到下面。

02:25:48 - 02:25:50
故意自招，還有過失自招。

02:25:50 - 02:25:52
我們分成這兩類，非常傳統性的考點，故意自招過失自招。

02:25:56 - 02:25:58
我們首先要先來釐清定義。

02:25:59 - 02:26:00
什麼叫故意？

02:26:00 - 02:26:00
過失自招。

02:26:00 - 02:26:00
什麼叫做過失自招？

02:26:03 - 02:26:06
因為這個名詞很容易讓人誤會，所以我要講一下這個名詞的定義。

02:26:09 - 02:26:12
先舉個例子，讓同學感受一下，這是故意的還是過失的。

02:26:13 - 02:26:15
好，如果有一天我經過一戶鄉下的人家前面，

02:26:16 - 02:26:18
我看到這戶人家養的一隻山豬。

02:26:19 - 02:26:25
這一隻山豬放在他的庭院，庭院門口告示牌：山豬兇猛，請勿靠近。

02:26:26 - 02:26:29
但我心想，哎呀，不會吧，那隻山豬看起來那麼可愛，怎麼會兇猛呢？

02:26:30 - 02:26:34
於是我又把目光擺過去，拿竹竿去挑逗這隻山豬。

02:26:34 - 02:26:40
哇，戳戳山豬的肚子，說這是你的五花肉，放在烤爐上會發爐，都是油。

02:26:40 - 02:26:45
接著戳戳山豬的背，說呀，這個叫里肌肉，做豬排一定特別的好吃。

02:26:45 - 02:26:53
最後再拿竹竿戳戳山豬的下巴，說你的清華就在這邊，松阪豬，黃金六兩肉，一直去戳那個豬。

02:26:53 - 02:26:55
豬被我戳到

02:26:55 - 02:26:56
野心大發

02:26:57 - 02:26:57
火氣上來了。

02:26:58 - 02:27:00
突然衝過來要咬我

02:27:00 - 02:27:03
我才發現，天啊，山豬好兇啊，還有獠牙，怎麼辦？

02:27:04 - 02:27:09
於是我趕緊拿石頭丟向山豬的頭部，把這隻山豬給打死。

02:27:10 - 02:27:11
各位

02:27:11 - 02:27:14
這種案例是故意自招還是過失自招？

02:27:15 - 02:27:16
請注意他是過失自招。

02:27:17 - 02:27:18
他不是故意自找。

02:27:19 - 02:27:22
你不能說因為我故意逗豬,所以我故意自找,不行。

02:27:22 - 02:27:25
如果你要講說我故意逗豬,所以我故意自找

02:27:26 - 02:27:27
那哪個自找不是故意的?

02:27:28 - 02:27:30
我們每個人的每個行為都是有意識的啊,對不對?

02:27:31 - 02:27:32
你要這樣講的話，每個都變故意的啊，不是啊。

02:27:33 - 02:27:34
所以來，什麼叫故意自招？

02:27:35 - 02:27:37
他就跟挑唆防衛那個意圖是一樣的意思。

02:27:39 - 02:27:40
故意自招指的是

02:27:41 - 02:27:44
行為人假借，行為人有這個意圖，什麼意圖呢？

02:27:44 - 02:27:49
想要假借其避難之名，去行攻擊他人之事。

02:27:54 - 02:27:55
要有這個意圖，才叫故意自找，知道嗎？

02:27:55 - 02:27:56
再講一次啊。

02:27:57 - 02:28:00
行為人想要假借

02:28:00 - 02:28:02
其避難之名

02:28:02 - 02:28:05
去行，攻擊其他人知識的意圖

02:28:05 - 02:28:09
有這樣的意圖，才叫做故意自找

02:28:09 - 02:28:11
所以我剛剛講的情況頂多是什麼呢

02:28:12 - 02:28:13
過失，我白目，對不對

02:28:13 - 02:28:16
明明寫那個牌子，我還去逗人家的豬啊

02:28:16 - 02:28:18
那個叫做過失自招

02:28:18 - 02:28:19
所以各位

02:28:19 - 02:28:23
剛剛我舉的案例,要怎麼樣才會變故意自招

02:28:25 - 02:28:26
假設變成這樣喔

02:28:27 - 02:28:32
我每次路過這戶人家門口,看著那隻山豬走來走去

02:28:32 - 02:28:34
我都盯著他的下巴在看

02:28:35 - 02:28:38
那個松阪豬不是一種豬的品種，你知道嗎

02:28:38 - 02:28:40
松阪豬就是豬的下巴肉

02:28:41 - 02:28:44
就是脖子下巴那一塊，它是一個豬的部位

02:28:46 - 02:28:50
我之前有一次，我之前有一次吃哪一家，品田牧場還是什麼的

02:28:51 - 02:28:53
我就故意問店員說，松阪豬是哪裡

02:28:54 - 02:28:57
店員就指著自己的下巴，說是豬的下巴肉

02:28:57 - 02:28:59
然後我就反問店員說，你幹嘛指自己的下巴

02:29:00 - 02:29:01
豬啊

02:29:01 - 02:29:03
店員是不是感覺自己被重擊了

02:29:03 - 02:29:06
還記得我做過這樣的無聊的這種問答

02:29:06 - 02:29:09
松阪豬不是品種啦,豬的部位,好

02:29:10 - 02:29:17
如果我每次看到這隻豬的下巴,我都想說哇塞,這個山豬的那個下巴肉啊,動來動去的

02:29:17 - 02:29:18
感覺很美味耶

02:29:19 - 02:29:22
砍下來做松阪豬,嫩煎松阪豬

02:29:22 - 02:29:24
撒點鹽巴,很好吃耶

02:29:24 - 02:29:26
我一直想說,好想吃吃看喔

02:29:27 - 02:29:29
那可是無故上人家豬油行者啊

02:29:29 - 02:29:30
我想說怎麼辦呢

02:29:30 - 02:29:32
那還不簡單

02:29:32 - 02:29:33
先去逗豬啊

02:29:33 - 02:29:36
等豬被我激怒的來攻擊我

02:29:36 - 02:29:37
那我再把豬砍死

02:29:38 - 02:29:39
這樣的話不就師出有名了嗎

02:29:40 - 02:29:41
對方就告不成我啦

02:29:42 - 02:29:43
如果我是基於這樣的意圖

02:29:44 - 02:29:46
為了宰山豬吃豬肉

02:29:46 - 02:29:47
而設這個局

02:29:47 - 02:29:50
先把山豬激怒，等山豬要攻擊我時

02:29:50 - 02:29:51
我再把這隻豬砍死

02:29:51 - 02:29:54
這就是所謂的，這個就是所謂的故意自找

02:29:54 - 02:29:55
對吧，這才是故意自找

02:29:55 - 02:29:56
所以我們再講一次

02:29:57 - 02:30:00
故意自找跟過失自找的不同

02:30:00 - 02:30:00
分界在哪裡。

02:30:01 - 02:30:02
我們看什麼呢？

02:30:03 - 02:30:11
行為人有沒有想要假借其避難之名，去行損害他人之實的意圖，我們看的是這個東西。

02:30:13 - 02:30:19
好，於是啊，我們來看一下，故意自招跟過失自招，各可不可以主張緊急避難。

02:30:20 - 02:30:21
第一個來沒有爭議。

02:30:22 - 02:30:24
故意自招，不可以緊急避難。

02:30:25 - 02:30:26
為什麼？

02:30:27 - 02:30:28
嚴重權利濫用，對不對？

02:30:28 - 02:30:29
所以這個比較沒有爭議。

02:30:30 - 02:30:34
不管趙世武方學說，故意自招都不可以緊急避難。

02:30:35 - 02:30:37
相對的來說，那過失自招可不可以？

02:30:38 - 02:30:40
這個有正反意見。

02:30:40 - 02:30:42
學者大部分說沒差。

02:30:43 - 02:30:46
因為學者會覺得說過失自招，還好吧。

02:30:46 - 02:30:49
他雖然白目但好像沒有到那麼嚴重的權力濫用。

02:30:50 - 02:30:53
所以學者大部分會說呢，過失自招就還好。

02:30:54 - 02:30:57
還是讓他有緊急避難成立的空間。

02:30:58 - 02:30:59
這個是學者多數說，知道嗎？

02:30:59 - 02:31:03
認為過失自招還是讓他有緊急避難成立的空間。

02:31:03 - 02:31:06
不因此而否定緊急避難的成立。

02:31:06 - 02:31:07
好，多數的學者這樣說。

02:31:08 - 02:31:09
食物呢？

02:31:09 - 02:31:09
怎麼說呢？

02:31:10 - 02:31:14
食物說啊，過失自招也不準緊急避難。

02:31:16 - 02:31:17
所以其實食物的結論是怎麼樣的？

02:31:17 - 02:31:20
反正你自招的，管理故意或過失。

02:31:20 - 02:31:24
就算過失自招，也不準緊急避難喔，這是食物的說法喔。

02:31:24 - 02:31:27
就算過失自招也不準緊急避難，為什麼？

02:31:29 - 02:31:32
其實食物的說法背後有幾分道理在。

02:31:32 - 02:31:33
我用白話的方式來講。

02:31:34 - 02:31:36
我剛剛講這個鬥山豬的例子。

02:31:37 - 02:31:38
你想喔。

02:31:39 - 02:31:42
人家就有告示牌，說山豬兇猛切勿靠近。

02:31:42 - 02:31:44
晚去拿竹竿戳摸牠，

02:31:44 - 02:31:45
我是不是很白目？

02:31:45 - 02:31:46
對，沒錯，超白目。

02:31:47 - 02:31:49
結果你說我可以緊急避難。

02:31:49 - 02:31:52
我自己白目，做錯事在先。

02:31:52 - 02:31:56
那然後我還可以把那個無辜的人的豬宰掉，說我緊急避難。

02:31:57 - 02:31:58
好像有點說不過去，對不對？

02:31:59 - 02:32:00
我自己

02:32:00 - 02:32:00
我做錯事在先。

02:32:00 - 02:32:00
那我被攻擊，我被出攻擊，那我應該自己承擔啊。

02:32:06 - 02:32:09
我怎麼把這個損害交給無辜第三人來承擔呢？

02:32:09 - 02:32:19
所以學說見解才會說，如果你讓那種過失自招的行為人可以主張緊急避難的話，學說說會有悖於社會的公平正義，為什麼有悖於公平正義，理由就在這邊，我做錯事，那我引發的為難，我就應該自己承擔，而不是找一個無辜的第三人來扛，懂我的意思吧？

02:32:28 - 02:32:33
所以學說認為說呢，過失自招，不可以緊急避難，理由大概在這邊。

02:32:34 - 02:32:38
好，所以這個是我們講過失自招的部分。

02:32:38 - 02:32:40
接著下面，這個題目我們等一下再說。

02:32:41 - 02:32:45
接著，緊急避難主觀上呢，要去有避難意思，這個我想應該也不會有什麼疑問。

02:32:48 - 02:32:50
來，接著164頁。

02:32:51 - 02:32:54
我們接下來說，緊急避難分成兩大類。

02:32:55 - 02:32:58
攻擊型，還有防禦型，這個我們剛說過。

02:33:00 - 02:33:04
再講一次喔，緊急避難被犧牲的對象不見得一定是無辜喔。

02:33:05 - 02:33:07
那種犧牲無辜的緊急避難，我們叫做攻擊型。

02:33:10 - 02:33:11
叫做攻擊型。

02:33:11 - 02:33:14
相對的，有犧牲的緊急避難。

02:33:15 - 02:33:21
不會犧牲無辜，反而那個被庇護的對象，就是為難的來源本身。

02:33:21 - 02:33:22
那一種叫什麼呢？

02:33:23 - 02:33:24
防禦型，分成兩種。

02:33:24 - 02:33:27
攻擊型，還有防禦型，分成這兩類。

02:33:28 - 02:33:29
好，我們先來看攻擊型這邊。

02:33:32 - 02:33:36
攻擊型的緊急避難，因為他所犧牲的對象是一個無辜的對象。

02:33:37 - 02:33:40
所以在這種攻擊型緊急避難當中，我們嚴格的要求法益的衡平性。

02:33:45 - 02:33:47
攻擊型緊急避難啊，你需要怎麼樣？

02:33:48 - 02:33:51
保全的法益要大於侵害的法益，才可以哦。

02:33:53 - 02:33:55
大於的關係，小於不可以。

02:33:56 - 02:33:58
等於也不可以，要大於的關係。

02:33:59 - 02:33:59
所以啊，

02:34:00 - 02:34:02
我為了避免自己被豬咬，

02:34:03 - 02:34:06
所以我跳到靈元的住宅去躲避。

02:34:06 - 02:34:08
我保覺的是生命。

02:34:08 - 02:34:11
犧牲的是別人的居住專利自由。

02:34:11 - 02:34:13
OK，可以嗎，對不對，這種情況可以。

02:34:14 - 02:34:14
可是喔。

02:34:15 - 02:34:17
如果山豬要咬我。

02:34:17 - 02:34:19
我的避難手段是。

02:34:20 - 02:34:22
看到前面有個小孩，抓那個小孩去餵山豬。

02:34:23 - 02:34:23
不可以。

02:34:24 - 02:34:26
為了保全生命犧牲別人的生命，這個不可以。

02:34:26 - 02:34:27
大於是不可以的。

02:34:28 - 02:34:29
所以必須要大於這個才可以。

02:34:30 - 02:34:32
好，所以我們講第一個。

02:34:34 - 02:34:36
適當性、必要性之外，還要符合「衡平性」。

02:34:36 - 02:34:40
衡平性的判斷就是生命、身體、自由、財產，照這個順序。

02:34:41 - 02:34:46
再來第二點我們說，生命法益具有最高的位階性。

02:34:47 - 02:34:48
這個道理就是這樣。

02:34:49 - 02:34:51
所有的法義碰到生命。

02:34:53 - 02:34:55
我們記得生命永遠至高無上。

02:34:56 - 02:34:58
所以任何的法義碰到生命。

02:34:58 - 02:35:00
任何其他的法義。

02:35:00 - 02:35:03
都會變成一種算哪根蔥的地位。

02:35:03 - 02:35:06
生命是一切價值的根本。

02:35:07 - 02:35:09
對啊，當然啊，沒有生命一切免談嘛。

02:35:09 - 02:35:10
生命是一切價值的根本。

02:35:11 - 02:35:14
所以我們說，生命法義對上其他法義的話。

02:35:14 - 02:35:17
其他法義都會變得不重要。

02:35:18 - 02:35:22
所以各位，生命法義對上國家法義，什麼重要？

02:35:24 - 02:35:25
你不要跟我說國家重要。

02:35:26 - 02:35:27
國家算哪根蔥啊。

02:35:28 - 02:35:29
生命才重要，好嗎？

02:35:30 - 02:35:33
國家沒了，國家沒了，不會怎麼樣，我們人活著就有期望啊。

02:35:33 - 02:35:35
如果你覺得國家比生命重要，你可能是那個極右派法西斯主義。

02:35:35 - 02:35:38
可能是那邊，不要有這種奇怪的信仰，好嗎。

02:35:39 - 02:35:41
國家真的不重要，我們人活著比較重要，生命才是一切的根本。

02:35:45 - 02:35:47
生命對社會才重要。

02:35:48 - 02:35:49
當然是生命啊。

02:35:49 - 02:35:51
我們講生命才是一切的根本。

02:35:51 - 02:35:53
你不要覺得國家社會才是一切的根本。

02:35:54 - 02:35:56
不要有那種集體主義奴性的思想，知道嗎。

02:35:57 - 02:35:58
生命才是一切的根本，所以生命具有最

02:36:00 - 02:36:01
高的價值。

02:36:02 - 02:36:03
好。

02:36:03 - 02:36:04
然後啊。

02:36:05 - 02:36:09
除了我們講生命對上帝的發議都是算跟衝之外。

02:36:10 - 02:36:15
生命跟生命之間，我們說啊，不準量化比較。

02:36:16 - 02:36:17
也就是什麼意思？

02:36:18 - 02:36:22
多數人的生命不會優於少數人的生命。

02:36:23 - 02:36:28
你不能說為了犧牲，為了拯救五個人，所以犧牲一個人是OK的。

02:36:28 - 02:36:30
我們刑法上不採這種觀念。

02:36:31 - 02:36:33
有沒有聽過電車難題？

02:36:33 - 02:36:34
應該很多同學都聽過，對不對？

02:36:34 - 02:36:36
法律系同學應該都聽過嘛，倫理學上有名的例子啊，電車難題。

02:36:38 - 02:36:39
電車難題是這樣子啊。

02:36:40 - 02:36:42
你是鐵道轉轍器的管理員。

02:36:42 - 02:36:46
有一臺失控的電車，朝你的方向往前衝。

02:36:47 - 02:36:50
如果你什麼都不做，它往原本的軌道衝，會撞死軌道末端五個工人。

02:36:53 - 02:36:57
如果你搬動轉轍器,讓電車往另外一道衝的話,

02:36:58 - 02:37:00
電車只會撞死一個工人。

02:37:01 - 02:37:02
你要不要搬動?

02:37:03 - 02:37:03
呃,

02:37:04 - 02:37:05
當下你沒有別的選擇了。

02:37:05 - 02:37:09
你不要說我要打那個1933平交道緊急專線，沒有這個選項。

02:37:10 - 02:37:12
就當下情況很緊急，你就沒有別的選項了。

02:37:12 - 02:37:14
這時候你搬不搬轉轍器？

02:37:15 - 02:37:15
很有趣的問題啊。

02:37:16 - 02:37:16
這個

02:37:17 - 02:37:18
這個沒有什麼對錯。

02:37:20 - 02:37:20
呃,

02:37:20 - 02:37:22
有些人說要搬，大部分人的道德直覺會覺得要搬,

02:37:24 - 02:37:26
覺得犧牲一個救五個很值得。

02:37:26 - 02:37:27
當然有反對的意見。

02:37:28 - 02:37:30
你們知道嗎？電車難題有一個變化版。

02:37:31 - 02:37:32
變化版。

02:37:32 - 02:37:33
變化版是一種，是一本哲普書的書名，

02:37:35 - 02:37:37
叫做《你該殺死那個胖子嗎？》

02:37:38 - 02:37:38
變化版是說啊，

02:37:39 - 02:37:43
你在一個跟鐵路垂直交叉的人行天橋上面。

02:37:44 - 02:37:46
有一臺失控的電車往前衝,

02:37:46 - 02:37:49
如果你什麼都不做，它會撞死軌道末端的五個工人。

02:37:50 - 02:37:51
正巧，

02:37:51 - 02:37:55
鐵道上方人行天橋上有個胖子趴在那邊看風景。

02:37:56 - 02:37:58
你把胖子推下去,

02:37:59 - 02:38:00
胖子會被墊底。

02:38:00 - 02:38:00
把他撞死,

02:38:01 - 02:38:02
但也會擋下這臺電車,

02:38:03 - 02:38:05
阻止那五個人被撞。

02:38:06 - 02:38:07
你要不要把胖子推下去?

02:38:08 - 02:38:11
當然這個例子在物理學上並不合理,

02:38:11 - 02:38:13
胖子要多胖才能擋下一條火車?

02:38:13 - 02:38:14
不合理對不對?

02:38:14 - 02:38:16
好，我們就假設他真的很胖。

02:38:17 - 02:38:18
有沒有聽過一個梗叫什麼你媽超胖？

02:38:19 - 02:38:23
胖到什麼可以把大西洋的海水全部都擠出地球什麼的？

02:38:23 - 02:38:24
有沒有聽過這種東西？

02:38:24 - 02:38:26
這個我們就想像大概這麼胖。

02:38:27 - 02:38:28
對啊。

02:38:28 - 02:38:29
這種情況對不對？

02:38:30 - 02:38:31
人很奇怪喔。

02:38:32 - 02:38:34
有一本書叫《好人總是自以為是》，

02:38:34 - 02:38:35
應該是那本書吧？

02:38:35 - 02:38:36
他就做我們一個調查。

02:38:37 - 02:38:37
第一個

02:38:38 - 02:38:40
鐵道轉轍器搬動的版本

02:38:40 - 02:38:41
大多數的人說

02:38:41 - 02:38:42
要，要搬。

02:38:43 - 02:38:43
為什麼？

02:38:43 - 02:38:44
因為多數的人會說，很合理啊，

02:38:45 - 02:38:47
我犧牲一個救五個也很值得啊，

02:38:47 - 02:38:47
對不對？

02:38:47 - 02:38:49
那部分人會說要搬。

02:38:50 - 02:38:51
可是胖子的版本，

02:38:52 - 02:38:52
大部分的人卻說，

02:38:53 - 02:38:54
我不應該把胖子推下去。

02:38:55 - 02:38:56
人多矛盾。

02:38:57 - 02:38:59
其實這兩個例子的答案應該要是一樣的啊。

02:39:40 - 02:39:42
因為這兩個例子我們都在問同一件事。

02:39:42 - 02:39:45
你要不要犧牲一個無辜的人去救另外五個人?

02:39:46 - 02:39:47
其實是一樣的問題,對不對?

02:39:47 - 02:39:49
那為什麼轉轍器的版本大家會說要搬?

02:39:49 - 02:39:50
胖子的版本大家說不搬。

02:39:51 - 02:39:53
這就是人的道德直覺不合理的地方。

02:39:54 - 02:39:56
因為道德心理學的研究者說,

02:39:58 - 02:39:59
轉轍器的版本,

02:40:00 - 02:40:03
功利主義者會說可以，義務論者一定會說不可以，這個是必然的。

02:40:04 - 02:40:08
而我們刑法這邊，比較傾向這種康德義務論的想法。

02:40:08 - 02:40:11
所以覺得犧牲一個救五個，不可以。

02:40:12 - 02:40:14
刑法上就說，生命不可能量化比較。

02:40:15 - 02:40:16
每一條命都一樣重要。

02:40:17 - 02:40:21
所以我們不能為了拯救多數人，而犧牲少數人，不可以。

02:40:22 - 02:40:26
我們也不能為了拯救一個天才，而犧牲另外一個智障，也不可以。

02:40:27 - 02:40:29
大家的命都是等價的，這個是我們刑法上的。

02:40:30 - 02:40:30
說法。

02:40:31 - 02:40:35
當然我會說啦，這種東西是不是就是定論，還會有討論的空間。

02:40:35 - 02:40:36
社會上有些不同的討論。

02:40:36 - 02:40:39
但我們刑法選擇的是，這種康德主義式的思想。

02:40:40 - 02:40:44
社會認為說呢，犧牲少數救多數，犧牲智能障礙者去救聰明人，這個都不可以。

02:40:45 - 02:40:47
好，所以這個是目前多數的說法，生命法義不可以量化比較。

02:40:48 - 02:40:50
這個東西我們就先看到這邊。

02:40:50 - 02:40:52
好，那我們今天就上到這邊囉。

02:40:52 - 02:40:54
剩下的話我們就下個禮拜再說啊。